課程名稱：刑法07

00:00:06 - 00:00:07
跟大家說個，剛剛稍微晚了一點點，抱歉，因為那個

00:00:11 - 00:00:12
去路易莎買的奶茶，我買了之後才發現他給我做錯，就是

00:00:15 - 00:00:18
我喝奶茶我一定要喝那個奶精，我覺得奶精的味道才對，那結果他給我做成鮮奶茶，我喝下去就覺得怎麼有一股奶的臭味，我覺得鮮奶很臭啊，我就想說奇怪他給我做錯，我們去換，所以稍微浪費了一點時間了。

00:00:31 - 00:00:33
好，我們來看到113頁這邊，我們上一次跟各位講到了雙重具體化錯誤這個概念，上一次我們跟各位講說啊

00:00:39 - 00:00:41
這個概念是用在什麼時候？

00:00:42 - 00:00:46
我們跟說啊，打擊錯誤是指行為人手段方法上面的偏差，而客體錯誤指的是行為人對行為客體的人別、物別的誤認，那我們說啊

00:00:52 - 00:00:57
當這個行為人跟被害人兩人沒有面對面，而結果卻作用在意外的客體之上的時候

00:01:01 - 00:01:06
這種情形你到底要說他是打擊錯誤，是客體錯誤，可能在定性上會產生一些困難，所以啊，學者就提出了雙重具體化錯誤這個概念，進而說了這個東西

00:01:13 - 00:01:14
要怎麼去處理啊，那關於學理上面的看法啊

00:01:17 - 00:01:22
113頁的下面這邊，我們先講啊，上次只跟各位講結論，那為什麼他這個名字叫做雙重具體化錯誤呢？

00:01:26 - 00:01:28
我這邊大概來說一下啊，我這裡啊，畫一個圖

00:01:31 - 00:01:32
這個圖呢

00:01:34 - 00:01:34
嗯

00:01:43 - 00:01:45
是一個真實的案例，應該說是一個真實的考題了

00:01:47 - 00:01:50
這個考題我沒有放在課本裡面，但它是前幾年政大轉學考的題目，很難

00:01:54 - 00:01:56
那個應該是洪老師出的,真的很難啊

00:01:56 - 00:02:00
我就把它畫出來,跟各位講一下,他在講什麼東西。

00:02:00 - 00:02:01
Hello.

00:04:22 - 00:04:24
好,這個故事是這樣子了,

00:04:24 - 00:04:25
我們來看喔。

00:04:26 - 00:04:27
假想殺A，

00:04:27 - 00:04:31
於是假在A的汽車裡面，裝了一顆炸彈。

00:04:31 - 00:04:35
假的設定是，當天早上A會來開車，

00:04:35 - 00:04:39
A一來開車，一發動車，汽車炸彈會被引爆，

00:04:39 - 00:04:41
A就會被炸死，這個是假的設定。

00:04:42 - 00:04:44
結果事情不如假所料。

00:04:44 - 00:04:48
假裝完了炸彈之後啊,事情的演變成這樣子喔,

00:04:48 - 00:04:50
事情變成這樣。

00:04:50 - 00:04:51
假裝完炸彈之後啊,

00:04:53 - 00:04:54
當天A沒有開車

00:04:55 - 00:05:00
A把汽車鑰匙給了他的朋友B，要這個B去開車。

00:05:00 - 00:05:04
而A呢，原本他沒有要去開車嘛，

00:05:04 - 00:05:05
所以這個A呢，

00:05:06 - 00:05:07
就突發奇想，

00:05:07 - 00:05:10
來到這個A車停放的大樓啊。

00:05:10 - 00:05:15
A車停放的，應該說A車停車處旁邊的大樓的樓頂。

00:05:15 - 00:05:17
A坐在女兒牆上面，

00:05:18 - 00:05:20
眺望著整個城市美好的景象，

00:05:20 - 00:05:25
因為這個大樓可能很高，那時候還沒有日出，是清晨的景象，

00:05:25 - 00:05:28
A就坐在那個大樓頂樓的女兒牆呢，眺望這一切。

00:05:29 - 00:05:30
A覺得心情很好。

00:05:30 - 00:05:32
這時候啊，B來開車了。

00:05:33 - 00:05:37
B來開車，發動汽車的瞬間，炸彈引爆了。

00:05:38 - 00:05:42
炸彈引爆的時候啊，威力很大，甚至產生了震波。

00:05:43 - 00:05:44
B當場被炸死。

00:05:45 - 00:05:51
而在頂樓女兒牆坐著眺望遠方的A呢,也因為震波的關係,重心不穩,

00:05:51 - 00:05:53
整個人往下墜落。

00:05:53 - 00:05:58
墜落之後啊,也好巧不巧,A的頭撞到他的車的引擎蓋,

00:05:58 - 00:05:59
A也掛了。

00:05:59 - 00:06:00
這個是

00:06:00 - 00:06:00
是政大轉學考的題目。

00:06:01 - 00:06:02
那哪一年呢，三年前吧，我記得2022。

00:06:05 - 00:06:06
這應該是洪老師出的啦。

00:06:07 - 00:06:12
因為政大的題目，我記得洪老師的題目的特色就是敘述超長。

00:06:12 - 00:06:17
就是看完那個故事，那個故事大概就1000字，看完那個故事大概10分鐘就過了，洪老師的題目特色都這樣。

00:06:19 - 00:06:21
好，這題很難啦。

00:06:21 - 00:06:23
拿去考法言所可能大家也不會啦。

00:06:23 - 00:06:27
所以那時候我想說，考轉學考，能寫出來的同學應該不多。

00:06:27 - 00:06:30
好，我們講為什麼這種錯誤叫做

00:06:30 - 00:06:31
雙重具體化錯誤，你看喔。

00:06:33 - 00:06:36
先講假的B的部分，我們先講假的B的部分。

00:06:38 - 00:06:42
假的B的部分來說，為什麼說這個叫雙重具體化錯誤。

00:06:42 - 00:06:44
因為在假的想像當中。

00:06:45 - 00:06:46
假腦中有兩個想法。

00:06:47 - 00:06:49
第一個是假想殺的人叫做A。

00:06:50 - 00:06:51
然後假設未良殺A。

00:06:52 - 00:06:54
所以假設定的一條因果鏈。

00:06:55 - 00:07:00
這個因果鏈是來發動這臺車的原因,就會被炸彈給炸死,這是假設第二個想像。

00:07:02 - 00:07:05
所以為什麼叫雙重具體化錯誤。

00:07:05 - 00:07:09
因為假的腦中有這兩個不同具體化的想像,知道嗎,有這兩個想像。

00:07:10 - 00:07:12
那所以我們上次跟各位說的。

00:07:12 - 00:07:15
在多數說，也就是許老師他所代表的見解。

00:07:15 - 00:07:20
許老師認為說，在這種雙重具體化錯誤當中，只要結果發生的方式

00:07:21 - 00:07:23
符合行為人對

00:07:24 - 00:07:25
因果。

00:07:25 - 00:07:26
鏈的想像。

00:07:26 - 00:07:31
也就是隻要結果發生的方式符合原本因果鏈的設定的話。

00:07:31 - 00:07:33
那我們在此當中是怎麼樣呢？

00:07:33 - 00:07:37
行為人搞錯了來觸發因果鏈的人，我們上次講過這個，還記得吧？

00:07:37 - 00:07:40
上次講過，所以如果我們依照這一種說法的話，來跟我們來看喔。

00:07:44 - 00:07:46
我們依照這種說法的話。

00:07:47 - 00:07:49
首先第一個，我們接到假對B的部分。

00:07:51 - 00:07:52
好。

00:07:52 - 00:07:53
就假對B的部分來說。

00:07:54 - 00:07:55
假。

00:07:56 - 00:07:58
它的部分，這個部分怎麼說呢？

00:07:59 - 00:08:00
這個B的。

00:08:00 - 00:08:00
是吧。

00:08:01 - 00:08:04
B確實是一個拿鑰匙來發動汽車然後被炸死的人，對不對？

00:08:04 - 00:08:07
所以就對B的死亡來說，確實是什麼呢？

00:08:09 - 00:08:12
B的死亡符合假對因果鏈的設定嗎?

00:08:12 - 00:08:14
所以假對B的死亡來講是怎麼樣?

00:08:15 - 00:08:17
不願意的來發動車的人。

00:08:18 - 00:08:19
所以以此來講是什麼錯誤?

00:08:20 - 00:08:22
他就只是客體錯誤,OK嗎?

00:08:22 - 00:08:24
這個是第一段，假對B的部分。

00:08:25 - 00:08:27
來，重點是假對A這一段。

00:08:28 - 00:08:30
假對A這一段。

00:08:30 - 00:08:31
這個很多人就會搞錯了。

00:08:32 - 00:08:36
很多人會想說，假原本想殺A啊，可是A最後也死掉了。

00:08:36 - 00:08:40
就對A來說的話，應該就是殺人既遂吧。

00:08:40 - 00:08:41
不對喔，為什麼？

00:08:42 - 00:08:44
因為假定的因果鏈是什麼呢？

00:08:45 - 00:08:48
來發動車的人會被炸彈給炸死。

00:08:49 - 00:08:50
這是假定的因果鏈。

00:08:50 - 00:08:51
那結果那個A怎麼死？

00:08:52 - 00:09:00
汽車炸彈引爆之後，因為有劇烈的震動，A不慎墜樓，頭部敲到引擎蓋最後死掉。

00:09:00 - 00:09:02
這是假設定的因果鏈嗎？

00:09:02 - 00:09:04
不是，所以假對那個變什麼錯誤？

00:09:05 - 00:09:05
打擊錯誤。

00:09:05 - 00:09:06
知道吧？

00:09:06 - 00:09:07
假扣押被打擊錯誤啊。

00:09:07 - 00:09:10
所以假扣押的部分，他是打擊錯誤啊。

00:09:11 - 00:09:13
如果照多數的看法，頂多論過失喔。

00:09:14 - 00:09:14
瞭解吧？

00:09:14 - 00:09:15
所以這個是假對A，還有假對B這兩個部分。

00:09:19 - 00:09:21
所以同學啊，黑板上這個案例，你知道它的原始版本是什麼嗎？

00:09:25 - 00:09:27
它的原始版本就是113頁上面的關換事例啊。

00:09:28 - 00:09:30
打擊錯誤跟客體錯誤的競合，你再看一下。

00:09:31 - 00:09:31
一下。

00:09:31 - 00:09:32
這個題我們上次講過。

00:09:33 - 00:09:34
A想殺B，後來那個，不是，就那個Y打正當防衛嘛。

00:09:39 - 00:09:40
108頁啊，A想殺B，來到行兇現場的時候，誤將C認為是B，對C開槍。

00:09:44 - 00:09:47
結果子彈打偏，這時候剛好B路過，B還是被打死了。

00:09:48 - 00:09:49
那不就一樣？

00:09:49 - 00:09:50
對啊。

00:09:50 - 00:09:53
所以各位，這個正當防衛逃逸的題目，它其實就是剛剛我們看到那個Y黨正當防衛案例的複雜化版本。

00:09:59 - 00:09:59
所以我們記住。

00:10:00 - 00:10:01
再講一次，什麼判斷？

00:10:02 - 00:10:04
行為人對B的部分，因為B的死亡方式符合假定因果的設定，所以假定此是可歸責，不阻卻故意。

00:10:12 - 00:10:20
可是A呢,雖然A是假扮原本想殺的人沒有錯,可是A的死亡方式沒有符合假的因果設定,所以這個部分叫做打擊錯誤,OK喔,三年級的大轉學考,就在考這個東西,很難,真的很難。

00:10:25 - 00:10:26
大一的同學。

00:10:27 - 00:10:28
我覺得應該不會吧。

00:10:28 - 00:10:30
對啊,我覺得啦,因為

00:10:30 - 00:10:34
會去考這大轉學考就是臺政不可能嘛,那就北大以下嘛,對啊,那

00:10:35 - 00:10:38
這個一般大一的同學真的會唸到這麼深嗎?

00:10:38 - 00:10:40
假設我大一的時候,很可能不會吧,所以

00:10:41 - 00:10:43
這真的出還蠻有水準的哦。

00:10:44 - 00:10:46
好,我們接著來往下看。

00:10:47 - 00:10:51
雙重距離錯誤啊,在德國有不同的說法,114頁寫明。

00:10:52 - 00:10:54
客體錯誤說是主流的說法啦。

00:10:55 - 00:10:57
那在德國也有打擊錯誤的說法。

00:10:57 - 00:11:02
所以這個東西,如果你把它寫成打擊錯誤,也不能說不對。

00:11:02 - 00:11:03
因為在德國有人這麼說啊。

00:11:03 - 00:11:04
那你想想啊。

00:11:05 - 00:11:10
那個有恐怖分子要刺殺一位政府官員，假設這樣，恐怖分子他想用狙擊的方式，刺殺一位政府官員。

00:11:14 - 00:11:21
那恐怖分子他持續舉槍，瞄準了政府官員，而且也扣下板機之後，子彈飛出來了。

00:11:21 - 00:11:25
這時候維安人員為了避免這個政府官員中彈。

00:11:25 - 00:11:30
所以維安人員呢，趕快讓自己跳入子彈的射程範圍之內。

00:11:30 - 00:11:33
最後維安人員中彈，那個維安人員死掉了。

00:11:34 - 00:11:36
這種案例我們會說是什麼錯誤？

00:11:37 - 00:11:37
打擊錯誤。

00:11:37 - 00:11:40
對吧，這案例我們一般會說是打擊錯嘛，好。

00:11:40 - 00:11:44
所以這個德國學者就說了，這種案例是打擊錯誤的話。

00:11:46 - 00:11:48
那我們前面講的什麼蛋糕案啊。

00:11:49 - 00:11:50
或者是汽車炸彈案啊。

00:11:51 - 00:11:52
它不是也是一樣的情況嗎？

00:11:53 - 00:11:54
行為人

00:11:55 - 00:11:56
在左手之後，

00:11:56 - 00:12:00
那因為某些事實的改變，導致結果發生在

00:12:00 - 00:12:01
意外的課題之上,

00:12:01 - 00:12:02
那個結構不是一樣嗎,

00:12:02 - 00:12:02
對不對?

00:12:02 - 00:12:05
那那一種案例你可以說是打擊錯誤的話,那這種不也是嗎?

00:12:05 - 00:12:09
所以在德國也有人認為說它應該是一種打擊錯誤,

00:12:09 - 00:12:11
也有，只是國內比較沒有人採這個說法。

00:12:11 - 00:12:14
然後啊，這裡還有另外一說叫做不區分說。

00:12:14 - 00:12:17
不區分說那個，我通常不會去細講它啦。

00:12:18 - 00:12:21
因為這一說的前提啊，其實跟通說不太一樣。

00:12:21 - 00:12:25
這一說會覺得打擊錯誤跟課題錯誤根本沒有區分的意義。

00:12:25 - 00:12:26
它的前提就已經跟通說不一樣了,

00:12:27 - 00:12:29
所以這一說我比較不會建議同學去採,(採用)

00:12:29 - 00:12:31
因為那是另外一個體系,

00:12:31 - 00:12:32
OK嗎?

00:12:32 - 00:12:34
所以這個是目前的三種說法,

00:12:35 - 00:12:38
所以總而言之呢,在國內來講的話,

00:12:38 - 00:12:42
主流的意見還是課題錯誤的說法,

00:12:42 - 00:12:42
OK嗎?

00:12:42 - 00:12:43
課題錯誤的說法,

00:12:43 - 00:12:44
再講一次判斷的公式,

00:12:45 - 00:12:47
我們看什麼呢？結果作用的方式，

00:12:48 - 00:12:51
有沒有符合行為人對因果面的設定？

00:12:51 - 00:12:53
如果有的話，

00:12:53 - 00:12:57
那我們就當作呢，行為人只是誤認了被害人的人別而已，

00:12:57 - 00:12:57
OK啊？

00:12:57 - 00:12:59
這東西考試超常出現。

00:13:40 - 00:13:42
題目本你們下個禮拜會拿到，

00:13:43 - 00:13:44
下個禮拜我再帶同學去看，

00:13:44 - 00:13:47
因為題目的部分我昨天很快就整理完了，

00:13:47 - 00:13:49
因為昨天高考的題目才出來嘛。

00:13:50 - 00:13:53
所以我昨天中午在高鐵上，我就迅速把它整理完，

00:13:54 - 00:13:56
就丟給講義組，但講義組那邊需要一些時間，

00:13:56 - 00:13:58
所以下個禮拜的話呢，同學才會拿到題目本。

00:14:00 - 00:14:03
是以前蔡聖偉老師在德國的博士論文寫的問題之一。

00:14:04 - 00:14:05
你們看喔，

00:14:05 - 00:14:09
左邊那個雙重體關係是許玉安老師當年德國的博士論文寫的,

00:14:10 - 00:14:12
右邊這個構成要件選擇要素的問題,

00:14:12 - 00:14:14
那個是蔡聖偉老師當年德國的博士論文寫的,

00:14:15 - 00:14:16
所以你們可以知道,

00:14:16 - 00:14:17
它具有一定的深度,

00:14:17 - 00:14:18
但就國考來講，

00:14:18 - 00:14:20
我們講最基本的操作就OK了。

00:14:21 - 00:14:21
這裡來，

00:14:21 - 00:14:22
我們先講，

00:14:22 - 00:14:25
什麼叫做構成要件的選擇要素。

00:14:26 - 00:14:28
所謂選擇要素的意思是，

00:14:28 - 00:14:30
在這一條構成要件當中，

00:14:31 - 00:14:33
有好幾個要素，

00:14:33 - 00:14:36
他們是用「或」的方式來連接的。

00:14:37 - 00:14:37
也就是啊，

00:14:37 - 00:14:39
在這一條罪的構成要件當中，

00:14:39 - 00:14:41
裡面可能有ABCD這幾個要素，

00:14:42 - 00:14:44
ABCD不用全部滿足喔，

00:14:44 - 00:14:46
只要有實現任何一個，

00:14:46 - 00:14:47
那它就該當。

00:14:48 - 00:14:51
這一種立法模式叫做構成要件的選擇要素。

00:14:51 - 00:14:53
像比如說我課本上的舉例,

00:14:54 - 00:14:54
306條,

00:14:55 - 00:14:55
你們看啊,

00:14:56 - 00:14:57
306條它侵入什麼東西?

00:14:59 - 00:14:59
住宅、

00:14:59 - 00:15:05
建築物或附連圍繞的土地或船艦。

00:15:06 - 00:15:06
來四個東西啊，

00:15:07 - 00:15:07
住宅、

00:15:08 - 00:15:08
建築物。

00:15:09 - 00:15:10
他們附連圍繞的土地，

00:15:11 - 00:15:12
或者是船艦。

00:15:13 - 00:15:14
四個不用都侵入啊，

00:15:15 - 00:15:15
對不對？

00:15:15 - 00:15:16
你侵入一個就符合啦。

00:15:17 - 00:15:18
所以這個叫做選擇要素

00:15:18 - 00:15:19
有符合任一個

00:15:19 - 00:15:21
任何一個就會中

00:15:21 - 00:15:22
那個叫選擇要素。

00:15:22 - 00:15:25
還有195條的偽造貨幣紙幣罪也是

00:15:26 - 00:15:27
這一條罪列了三個東西，

00:15:27 - 00:15:28
貨幣、

00:15:28 - 00:15:29
紙幣、

00:15:29 - 00:15:30
銀行券，

00:15:31 - 00:15:32
它列了這三個東西。

00:15:32 - 00:15:33
貨幣、

00:15:33 - 00:15:33
紙幣、

00:15:33 - 00:15:34
銀行券。

00:15:35 - 00:15:36
這三個東西，

00:15:36 - 00:15:38
你也不需要同時都去偽造。

00:15:38 - 00:15:39
不用,

00:15:39 - 00:15:41
你偽造其中一個,

00:15:41 - 00:15:42
犯罪就會成立了,

00:15:42 - 00:15:43
所以我們說,

00:15:43 - 00:15:44
多擇一

00:15:44 - 00:15:46
只要符合其中一個，

00:15:46 - 00:15:48
犯罪就會成立的這一種立法模式，

00:15:48 - 00:15:50
我們叫做構成要件選擇要素。

00:15:51 - 00:15:51
好，

00:15:52 - 00:15:56
為什麼立法者會用這種選擇要素的方式來做立法呢？

00:15:57 - 00:15:58
理由是這樣子啦,

00:15:59 - 00:16:00
通常

00:16:00 - 00:16:02
啊,比較常見的一個叫做語言困難,語言困難,什麼意思?

00:16:05 - 00:16:07
我們以306為例,各位想一件事哦。

00:16:07 - 00:16:09
306條他列了四個東西。

00:16:10 - 00:16:13
住宅、建築物、附連圍繞的土地及環境。

00:16:15 - 00:16:15
各位啊。

00:16:16 - 00:16:17
這四個東西，

00:16:17 - 00:16:19
你們在中文上，

00:16:19 - 00:16:21
能不能找到一個名詞，

00:16:21 - 00:16:25
可以同時涵蓋到這四個東西，

00:16:25 - 00:16:27
又不會涵蓋到其他的。

00:16:28 - 00:16:29
有這個名詞嗎？

00:16:30 - 00:16:31
可能暫時想不到，對吧？

00:16:31 - 00:16:34
如果你想說一個裡面會有非常多人的空間。

00:16:35 - 00:16:38
如果你這樣講，那這個定義是不是會包含到飛機？

00:16:39 - 00:16:40
可是飛機沒有在裡面啊。

00:16:40 - 00:16:44
而且如果你講裡面有很多人的空間，那土地不算，對不對？

00:16:45 - 00:16:52
所以我們會發現，這四個東西，因為我們真的找不到他們一個可以共同包含的上位概念，就找不到，所以沒辦法，我們只好並列。

00:16:55 - 00:16:59
他的立法模式，他的立法理由主要是這樣來的，知道嗎？

00:16:59 - 00:17:00
所以只是這個我們講語言困難嘛。

00:17:01 - 00:17:05
因為找不到共同上位概念，所以只好用這種方式來做個立法。

00:17:05 - 00:17:06
好。

00:17:06 - 00:17:08
那選擇要式會發生什麼問題呢？

00:17:09 - 00:17:12
行為人如果對事實誤認怎麼辦？

00:17:13 - 00:17:14
那行為人對事實誤認怎麼辦？

00:17:15 - 00:17:16
我舉個例子。

00:17:18 - 00:17:20
不知道同學去過澎湖，或者是澎湖人。

00:17:20 - 00:17:22
你可能很多人都去過啊。

00:17:22 - 00:17:25
這個以後同學有機會去澎湖的話。

00:17:26 - 00:17:27
一定要去看一個東西。

00:17:27 - 00:17:29
在馬公港的旁邊叫做菊島之星。

00:17:30 - 00:17:31
請你去。

00:17:31 - 00:17:33
你不用進去沒關係，但你一定要去看。

00:17:33 - 00:17:37
菊島之星，遠看像新造遊輪。

00:17:37 - 00:17:39
請你靠近看會發現。

00:17:39 - 00:17:43
它其實是一艘水泥打造的船型建築物，它根本就不是船。

00:17:43 - 00:17:46
真的啦，有空去澎湖一定要去看它。

00:17:46 - 00:17:49
我第一次去澎湖，看到菊島之星啊。

00:17:49 - 00:17:52
我馬上想到這個問題，構成要件要素的選擇要式錯誤。

00:17:53 - 00:17:53
你知道為什麼嗎？

00:17:54 - 00:18:00
假設在半夜有一個外地人，他侵入那個菊島之星，他以為這是一艘遊輪。

00:18:00 - 00:18:00
去玩，

00:18:00 - 00:18:03
結果進去之後想說奇怪這個船怎麼這麼穩，都不會晃啊。

00:18:03 - 00:18:05
晃了才發現，我對欸，這不是船欸，

00:18:05 - 00:18:06
這根本是建築物。

00:18:07 - 00:18:08
那這是錯誤的問題啊。

00:18:09 - 00:18:11
客觀上行為人侵入的是建築物，

00:18:11 - 00:18:11
對不對？

00:18:12 - 00:18:15
他行為人主觀上呢,以為他在侵入船艦。

00:18:16 - 00:18:17
有空可以到那邊去看,

00:18:17 - 00:18:18
好嗎?

00:18:18 - 00:18:21
舉島之親，聽說對婆婆來說是一個很冷門的景點。

00:18:21 - 00:18:22
那我都要去看。

00:18:22 - 00:18:24
我去過好幾次，我都會去看。

00:18:24 - 00:18:26
複習一下構成要件，選擇要素的錯誤。

00:18:26 - 00:18:28
下次去看，下次去的話，記得去看它。

00:18:28 - 00:18:29
舉手之勞。

00:18:30 - 00:18:30
好。

00:18:30 - 00:18:31
你想喔,

00:18:31 - 00:18:34
客觀上行為人侵入的是建築物,

00:18:35 - 00:18:40
可是主觀上行為人覺得他在侵入船艦。

00:18:40 - 00:18:43
這樣的案例當中,我們會怎麼論罪?

00:18:45 - 00:18:47
這一種選擇要件的錯誤會怎麼論罪?

00:18:47 - 00:18:49
會不會像不等價客體錯誤一樣？

00:18:49 - 00:18:51
對實際侵入的對象論罪，故意，

00:18:52 - 00:18:55
然後對那個原本想侵入的對象論未遂，

00:18:55 - 00:18:56
會嗎？

00:18:56 - 00:18:56
不會。

00:18:57 - 00:18:57
為什麼？

00:18:58 - 00:19:13
因為我們會講，

00:19:13 - 00:19:30
像306的這一種

00:19:30 - 00:19:41
選擇要素。

00:19:41 - 00:19:41
來，

00:19:42 - 00:19:43
下面的，我們翻過來116頁。

00:19:44 - 00:19:47
這一種立法，我們叫做語言困難的選擇要素。

00:19:49 - 00:19:49
我這樣說的嘛,

00:19:50 - 00:19:57
這四個東西,如果在中文上能有一個名詞同時包含它們,又不會包到其他的的話,

00:19:57 - 00:19:58
那立法者不用分列這四個啊,

00:19:59 - 00:19:59
對不對?

00:20:00 - 00:20:02
叫做任意性的選擇要素。

00:20:03 - 00:20:06
再來第二個，叫做立法經濟的選擇要素。

00:20:07 - 00:20:09
所謂立法經濟的選擇要素的意思就是說，

00:20:10 - 00:20:11
這些選擇要素，

00:20:12 - 00:20:14
其實它們之間的關聯是不強，

00:20:15 - 00:20:17
立法者只是基於方便的考量。

00:20:17 - 00:20:19
把他們全部列在同一個條文

00:20:20 - 00:20:21
這個叫立法經濟。

00:20:21 - 00:20:24
所以這種立法經濟的選擇要素當中

00:20:24 - 00:20:27
他們的法律評價其實是不相同的喔

00:20:27 - 00:20:28
知道嗎？

00:20:28 - 00:20:28
其實是不相同的喔。

00:20:29 - 00:20:30
好，我這邊再畫一個例子。

00:21:54 - 00:21:55
大家覺得很不知所云，對不對？

00:21:56 - 00:21:57
我跟各位講這圖什麼意思。

00:21:58 - 00:21:58
甲

00:21:59 - 00:22:00
他對他的仇人下毒。

00:22:00 - 00:22:01
在這個地方當中，

00:22:01 - 00:22:02
行為人應該怎麼對待？

00:22:03 - 00:22:03
學者會認為說，

00:22:04 - 00:22:06
重傷罪的各款事由。

00:22:06 - 00:22:09
他們的法律評價其實並沒有相等喔。

00:22:10 - 00:22:12
他不像什麼住宅建築物什麼的本質上差不多，

00:22:12 - 00:22:12
不是哈。

00:22:13 - 00:22:14
各款不同重傷事由，

00:22:15 - 00:22:17
眼睛、鼻子、嘴巴、四肢、生殖器什麼的，

00:22:18 - 00:22:19
他們在法律上的評價

00:22:20 - 00:22:21
並不是等

00:22:22 - 00:22:22
並不是等同的。

00:22:23 - 00:22:25
所以這個東西並不是語言困難的選擇要素。

00:22:26 - 00:22:30
立法者會把這些東西放在同一個刑法第19條第4項

00:22:30 - 00:22:33
立法者只是為了方便的考量而已,

00:22:33 - 00:22:35
所以這個東西叫做立法經濟的選擇要素。

00:22:36 - 00:22:37
這一種立法經濟的選擇要素,

00:22:38 - 00:22:40
如果行為人有發生誤認的話,

00:22:40 - 00:22:44
因為各款之間的法律評價是不相等的,

00:22:45 - 00:22:46
所以這個時候會怎麼樣？

00:22:46 - 00:22:48
回歸一般錯誤論的法律處理。

00:22:48 - 00:22:48
所以啊，

00:22:49 - 00:22:53
行為人對原本想實現的意境這一塊呢，

00:22:54 - 00:22:55
會變成是未遂。

00:22:56 - 00:22:59
對於實際上所實現的生殖機能這一塊呢,

00:23:00 - 00:23:01
他會具體故意,

00:23:01 - 00:23:03
改論行為人過失犯,

00:23:04 - 00:23:04
完全不同的處理方式,

00:23:05 - 00:23:05
懂嗎?

00:23:05 - 00:23:07
所以這個是我們的處理方法,

00:23:07 - 00:23:11
看到底是立法、經濟或者是語言困難的選擇要素。

00:23:12 - 00:23:12
當然啦,

00:23:13 - 00:23:15
各位如果還要往下追,

00:23:15 - 00:23:17
說刑法那麼多條文都有選擇要素,

00:23:18 - 00:23:19
哪些是立法經濟？

00:23:19 - 00:23:20
哪些是語言困難？

00:23:21 - 00:23:22
這個有在學術研討會提過，

00:23:22 - 00:23:22
知道嗎？

00:23:22 - 00:23:23
這個寫下來。

00:23:23 - 00:23:24
這個講下去，

00:23:24 - 00:23:25
就變博士論文的議題了。

00:23:25 - 00:23:26
所以這裡的話，

00:23:26 - 00:23:27
你大概就知道一個代表性，

00:23:27 - 00:23:28
306那一種。

00:23:29 - 00:23:31
它就是純粹語言困難的選擇要素,

00:23:31 - 00:23:33
而像重傷這種事由呢,

00:23:33 - 00:23:35
它就是立法經濟的選擇要素,

00:23:35 - 00:23:36
同學大概有這個概念呢,

00:23:37 - 00:23:37
就OK了。

00:23:39 - 00:23:40
好,

00:23:40 - 00:23:41
接下來,

00:23:41 - 00:23:42
116頁,

00:23:43 - 00:23:44
我們又要來看一個錯誤的問題。

00:23:45 - 00:23:47
排他互斥構成要件的錯誤。

00:23:48 - 00:23:50
我不是說我們今天會講一系列的錯誤。

00:23:50 - 00:23:53
我們早上講完了構成要件系列的錯誤之後，

00:23:53 - 00:23:55
下午會講那個違法性裡面的錯誤，

00:23:56 - 00:23:57
容許構成要件錯誤，

00:23:57 - 00:23:58
所以今天啊，

00:23:59 - 00:24:00
課程內容

00:24:00 - 00:24:01
對各位的腦袋來說,

00:24:01 - 00:24:02
負擔會比較大，

00:24:02 - 00:24:05
如果覺得精神不好的話，喝杯咖啡之類的，

00:24:05 - 00:24:06
這個

00:24:06 - 00:24:08
今天的課程啊，在考試都還蠻重要的。

00:24:09 - 00:24:11
請翻到116頁，

00:24:11 - 00:24:13
排他互斥構成要件錯誤。

00:24:14 - 00:24:17
其實，這個東西不是一種獨立的錯誤類型。

00:24:18 - 00:24:22
這個主題在講的是，那如果行為人的構成要件錯誤，

00:24:23 - 00:24:27
發生在哪一種彼此排他互斥的構成要件之間，

00:24:28 - 00:24:29
那應該怎麼辦？

00:24:29 - 00:24:31
他在談的就是這個問題。

00:24:31 - 00:24:33
好，我們先講一種條文作為代表。

00:24:34 - 00:24:37
這個東西，我後面註釋有引。

00:24:39 - 00:24:42
這個是蔡聖偉老師在2010年的一篇文章

00:24:42 - 00:24:45
2010年蔡聖偉老師發表了一篇文章，專門談這個東西。

00:24:46 - 00:24:48
在老師發表這篇文章前，

00:24:49 - 00:24:51
其實我大一就講到這個問題。

00:24:52 - 00:24:55
只是當時翻遍的所有行銷教科書，

00:24:55 - 00:24:57
當時都沒有想到應該要怎麼去處理。

00:24:58 - 00:24:59
我當時想到問題是這樣子,

00:25:40 - 00:25:40
來,

00:25:41 - 00:25:42
我們講放火罪,

00:25:42 - 00:25:43
放火罪。

00:25:44 - 00:25:46
173跟174,

00:25:46 - 00:25:49
我們來看一下這一組條文,放火罪173還有174。

00:26:00 - 00:26:00
建築物,公眾使用工具。

00:26:00 - 00:26:00
可是這兩條的規定不一樣,173是什麼呢?

00:26:06 - 00:26:09
現供人使用的住宅,現有人所在的建築物等等。

00:26:10 - 00:26:11
174是什麼呢?

00:26:11 - 00:26:16
現非供人使用的住宅,現未有人所在的建築物。

00:26:17 - 00:26:18
他這樣規定嘛,對不對?

00:26:18 - 00:26:18
好。

00:26:19 - 00:26:23
各位,那如果行為人在這兩條之間發生了事實誤認怎麼辦呢?

00:26:23 - 00:26:27
比如說有個人，他去燒一間廢棄的工廠。

00:26:27 - 00:26:30
點火之後，廢棄的工廠嘛。

00:26:30 - 00:26:31
看起來裡面就不會有人喔。

00:26:32 - 00:26:36
結果行為人點火之後，火勢開始燃燒了。

00:26:36 - 00:26:39
這時候啊，有個流浪漢從裡面逃出來。

00:26:39 - 00:26:41
原來裡面其實有人在。

00:26:42 - 00:26:43
對啊，這個時候怎麼辦？

00:26:44 - 00:26:47
可以關上行為人燒的事，是一七三的課題，對不對？

00:26:47 - 00:26:50
那行為人主觀上以為他燒的是什麼呢？

00:26:50 - 00:26:51
一七四啊。

00:26:51 - 00:26:51
這個時候怎麼辦？

00:26:52 - 00:26:53
那我大一的時候想這個問題啊。

00:26:53 - 00:26:55
大一的時候我想到，我想說對啊，所以

00:26:56 - 00:26:57
這個要怎麼做啊？

00:26:57 - 00:26:58
疑問一過時啊。

00:26:58 - 00:27:00
可是怎麼感覺上覺得怪怪的。

00:27:01 - 00:27:02
當時我覺得很怪，然後

00:27:03 - 00:27:04
也百思不解，翻了課本啊什麼的

00:27:04 - 00:27:06
也找不到答案，後來大二我轉學到東吳嘛。

00:27:08 - 00:27:09
我講過我是轉學生嘛，我大一讀文化，大二轉學東吳嘛。

00:27:11 - 00:27:15
大二轉去東吳之後，我修蔡聖偉老師的刑分。

00:27:15 - 00:27:17
蔡老師當時在講墮胎罪，因為墮胎罪也有這一組誤植。

00:27:18 - 00:27:20
289跟291，我們就會講到，當時蔡老師在講墮胎罪的互斥構成要件。

00:27:24 - 00:27:25
如果發生誤類的時候，蔡老師提出了一個解方。

00:27:27 - 00:27:29
我當時聽到覺得好高興，啊原來是這樣解。

00:27:30 - 00:27:34
下課我就問蔡老師，那如果放火遇到這個問題的話也是嗎？

00:27:34 - 00:27:36
蔡老師說對，沒有錯，也是這樣解。

00:27:37 - 00:27:37
就覺得好感動。

00:27:38 - 00:27:41
這個沉寂在腦中幾個月的問題，終於獲得解答。

00:27:41 - 00:27:44
所以過了幾年之後，蔡老師發表這篇文章。

00:27:45 - 00:27:47
我記得他是現在一個研討會發表。

00:27:47 - 00:27:49
那個研討會在嘉義，我還特別去聽。

00:27:49 - 00:27:50
原來是這樣處理的。

00:27:50 - 00:27:51
所以

00:27:52 - 00:27:55
這個問題啊，我以前大學的時候對它特別有感。

00:27:55 - 00:27:59
因為我是自己先想到，那想到覺得無解，後來才知道原來是這樣解。

00:28:00 - 00:28:00
所以這邊呢就來跟各位分享一下

00:28:02 - 00:28:09
如果行為人對這種互斥的構成要件發生誤認的話，應該怎麼去做處理？

00:28:10 - 00:28:11
好。

00:28:11 - 00:28:12
其實問題是這樣。

00:28:12 - 00:28:15
這種互斥的構成要件在刑法上會產生的問題

00:28:16 - 00:28:21
就無論行為人對事實的誤認之外，還會發生另外兩個面向的狀況

00:28:22 - 00:28:24
第一個叫做誤想防衛，第二個叫做共犯的預約

00:28:25 - 00:28:28
第三個叫做事實不明

00:28:29 - 00:28:31
這個是臺大許老師的整理

00:28:31 - 00:28:34
所有這種互斥的構成要件

00:28:35 - 00:28:37
在刑法上可能會造成的三大問題

00:28:38 - 00:28:39
除了像我們剛剛講第一個

00:28:39 - 00:28:42
構成要件之外,還會產生什麼問題呢

00:28:43 - 00:28:46
共犯預約的問題跟事實不明的問題

00:28:47 - 00:28:51
而這個東西啊，有些同學可能第一次學刑法會覺得很陌生

00:28:51 - 00:28:53
我先跟各位講一個基本的觀念

00:28:54 - 00:28:55
什麼叫共犯預約？

00:28:56 - 00:28:57
我們以教唆為例

00:28:57 - 00:28:58
各位

00:28:58 - 00:29:00
我叫你去殺人

00:29:00 - 00:29:04
結果你看到被害人之後你不忍心，你把他打傷人就走了

00:29:05 - 00:29:06
你改變犯意

00:29:06 - 00:29:07
打傷人就走了

00:29:07 - 00:29:08
這個叫共犯預約，知道嗎

00:29:08 - 00:29:09
或者反過來

00:29:10 - 00:29:11
我叫你去毆打被害人

00:29:12 - 00:29:15
結果你卻另行起義，把那個被害人給殺了

00:29:15 - 00:29:15
這個叫共犯預約

00:29:16 - 00:29:17
當然還有一種情況是

00:29:18 - 00:29:19
我叫你去毆打被害人

00:29:19 - 00:29:21
結果呢,你竟然對他性騷擾了

00:29:22 - 00:29:23
這也是有可能的

00:29:23 - 00:29:25
各位,共犯預約怎麼辦

00:29:26 - 00:29:28
有學過當複習,沒學過當預習啊,沒關係

00:29:28 - 00:29:29
共犯預約怎麼辦？

00:29:30 - 00:29:33
我們講共犯預約的處理方式就是，

00:29:33 - 00:29:34
就，

00:29:34 - 00:29:36
行為人所教唆

00:29:36 - 00:29:39
跟正犯所犯的罪之間有包含的部分。

00:29:39 - 00:29:41
成立教唆犯，知道嗎

00:29:41 - 00:29:44
就這兩者之間有包含的部分成立教唆犯

00:29:44 - 00:29:45
所以啊

00:29:45 - 00:29:46
我叫你去傷害

00:29:46 - 00:29:46
而你卻轉念做

00:29:46 - 00:29:47
殺人

00:29:47 - 00:29:47
殺人

00:29:47 - 00:29:49
殺人跟傷害包含的部分叫什麼呢

00:29:49 - 00:29:49
傷害

00:29:49 - 00:29:50
對不對

00:29:50 - 00:29:50
傷害是基本的吧

00:29:50 - 00:29:50
同學啊

00:30:00 - 00:30:05
那個，成立殺人罪的人，一定也會同時成立傷害罪，知道嗎？

00:30:05 - 00:30:07
因為我這個觀念喔。

00:30:07 - 00:30:10
同學你不要有一個很白爛的想法覺得說，想殺人的人怎麼會想傷害。

00:30:11 - 00:30:12
不對啦，不會有人這樣說啦。

00:30:12 - 00:30:15
想殺人的人當然也會想傷害人。

00:30:15 - 00:30:17
人不傷害人這個事，對不對？

00:30:18 - 00:30:21
所以啊，殺人跟傷害包含的是傷害。

00:30:21 - 00:30:22
傷害嘛。

00:30:22 - 00:30:24
因為傷害比較輕，殺人比較重嘛，對不對？

00:30:24 - 00:30:25
所以包含的部分是傷害。

00:30:26 - 00:30:30
因此，我叫你殺人，你去傷害，我叫你傷害，你去殺人。

00:30:31 - 00:30:34
殺人跟傷害間包含的部分叫做傷害，對吧？

00:30:34 - 00:30:37
所以我論什麼呢？傷害罪的教唆犯。

00:30:38 - 00:30:38
好，再來。

00:30:39 - 00:30:44
那我叫你傷害，而你卻對被害人實施那個性騷擾的犯罪行為。

00:30:45 - 00:30:46
這樣的話我怎麼論罪？

00:30:48 - 00:30:48
我無罪。

00:30:48 - 00:30:49
為什麼？

00:30:49 - 00:30:51
傷害跟性騷擾有什麼關聯？

00:30:51 - 00:30:52
沒有嘛，對不對？

00:30:52 - 00:30:53
所以我不會覺得任何的犯罪，瞭解喔。

00:30:54 - 00:30:58
所以如果我們遇到這種過犯的問題的話，學理上怎麼處理呢？

00:30:59 - 00:30:59
就看啊。

00:31:00 - 00:31:06
我所教唆的犯罪跟正犯所犯的罪之間有沒有包含的關係。

00:31:07 - 00:31:09
有的話，我們就包含的部分成立共犯。

00:31:09 - 00:31:11
沒有的話，行為人無罪，OK喔。

00:31:11 - 00:31:12
好，於是我們來看到。

00:31:15 - 00:31:18
互斥共犯條件，如果發生過犯餘的問題怎麼辦呢？

00:31:19 - 00:31:20
我舉個很簡單的例子啊。

00:31:22 - 00:31:27
我叫陸伯言去跟一個15歲的國中女生合意性交。

00:31:28 - 00:31:32
結果陸伯言卻去跟一個13歲的國中女生合意性交。

00:31:34 - 00:31:36
對啊，我講這樣簡單的例子就好嘛。

00:31:36 - 00:31:39
雖然陸伯言可能對小妹妹沒興趣嘛，因為他喜歡姊姊嘛，對不對？

00:31:40 - 00:31:41
你有上課嘛，對不對？

00:31:41 - 00:31:41
沒有啊。

00:31:43 - 00:31:44
當然有趣啊。

00:31:44 - 00:31:46
有空應該你們應該有機會上課。

00:31:47 - 00:31:51
來，我叫陸伯言跟15歲的女生合意性交。

00:31:51 - 00:31:55
結果他卻跑去跟一個13歲的國中女生合意性交。

00:31:56 - 00:31:57
這時候我怎麼論罪？

00:31:57 - 00:31:59
這樣這時候我怎麼論罪？

00:32:00 - 00:32:01
你們看227的規定。

00:32:02 - 00:32:03
是用司法條規的問題,我來看到227。

00:32:25 - 00:32:27
227條，27。

00:32:29 - 00:32:34
27第一項講什麼呢？跟未滿14歲的人性交猥褻，性交有沒有看到？第一項嘛，未滿14。

00:32:36 - 00:32:39
第三項是什麼呢？14以上未滿16。

00:32:40 - 00:32:42
看到了嗎？一個是未滿14嘛。

00:32:44 - 00:32:46
一個是14以上未滿16。

00:32:47 - 00:32:53
所以你想喔，我教唆陸博言跟15歲的國中女生合意性交，我教唆他犯什麼。

00:32:53 - 00:32:55
第三項，對吧，第三項。

00:32:55 - 00:32:58
結果陸博也去找一個13歲的。

00:32:58 - 00:33:00
那他犯的是第幾項？

00:33:00 - 00:33:01
第一項。

00:33:01 - 00:33:02
OK吧，沒問題吧。

00:33:03 - 00:33:04
那我們說共犯約怎麼辦？

00:33:05 - 00:33:06
包含啊。

00:33:07 - 00:33:08
那你看一跟三有包含嗎？

00:33:09 - 00:33:12
沒有，一個是未滿14，一個14以上未滿16，所以我無罪喔。

00:33:14 - 00:33:15
怪，對吧，怪。

00:33:15 - 00:33:19
所以互斥條件，如果發生在共犯約定，會有問題，最後是事實不明。

00:33:21 - 00:33:22
我們以剛剛那個放火為例。

00:33:24 - 00:33:26
我放火去燒一個分析的工廠。

00:33:27 - 00:33:27
再來啊。

00:33:28 - 00:33:29
我是引燃之後，警示器啟動。

00:33:31 - 00:33:35
有個流浪漢在工廠附近瘋狂地逃竄。

00:33:35 - 00:33:37
可是法院所無法證明的是，

00:33:38 - 00:33:42
這個流浪漢，他其實在工廠的周邊睡覺。

00:33:42 - 00:33:43
在逃竄。

00:33:44 - 00:33:47
還是其實是在我放火的當下，那個流浪漢人在工廠的裡面？

00:33:48 - 00:33:49
你說有差嗎？有啊，當然有差。

00:33:50 - 00:33:52
因為流浪漢人在工廠裡面的話，

00:33:53 - 00:33:54
那是什麼？

00:33:54 - 00:33:55
一期三，對不對？

00:33:55 - 00:33:58
那如果人不在工廠裡面呢,那是一期四啊。

00:33:59 - 00:33:59
對啊。

00:34:00 - 00:34:00
所以你說這個怎麼辦?

00:34:02 - 00:34:04
是是不明，我們講罪疑惟輕嘛。

00:34:05 - 00:34:08
那可是173跟174你怎麼罪疑惟輕?

00:34:09 - 00:34:10
問題是這樣喔。

00:34:11 - 00:34:15
因為我們無法證明放火或失火的當下，

00:34:15 - 00:34:20
流浪漢到底是在工廠裡面或工廠外面。

00:34:20 - 00:34:22
所以第一個173你不能用,為什麼?

00:34:22 - 00:34:24
不能證明那是欠缺有人在的建築物,對吧?

00:34:24 - 00:34:26
所以173罪疑惟輕嘛,不能用。

00:34:27 - 00:34:28
那174總可以吧?

00:34:29 - 00:34:31
那可是174寫要沒有人呢。

00:34:32 - 00:34:33
那你也不能證明沒有人啊。

00:34:34 - 00:34:35
這是不是很兩難?

00:34:35 - 00:34:38
不能用173，因為不能證明沒有人。

00:34:38 - 00:34:39
那罪疑惟輕用174呢？

00:34:40 - 00:34:41
那可是你也不能證明裡面沒有人啊。

00:34:42 - 00:34:43
所以行為人就無罪了。

00:34:44 - 00:34:44
超怪，對吧？

00:34:45 - 00:34:46
來，所以怎麼辦喔。

00:34:47 - 00:34:51
聽到這裡，你會發現互斥更像是一種很愉悅的地方。

00:34:51 - 00:34:52
對，沒有錯。

00:34:52 - 00:34:54
所以我這邊跟同學講喔。

00:34:54 - 00:34:57
以後我們在學習的時候，我會跟同學講一個觀念。

00:34:58 - 00:35:00
各組條文之間。

00:35:01 - 00:35:04
如果它們的文義上沒有互斥。

00:35:04 - 00:35:06
能詮釋成包含的話。

00:35:06 - 00:35:08
我們要盡量把它們解釋成有包含。

00:35:09 - 00:35:10
不要把它們解釋成排斥，知道嗎？

00:35:11 - 00:35:15
像比如說有些傳統的見解會把竊盜跟強盜都認為是排斥。

00:35:16 - 00:35:19
說竊盜要被害人不知，強盜要當著被害人的面之類的。

00:35:20 - 00:35:21
這個見解就不要採。

00:35:22 - 00:35:23
因為經過我們剛剛說明很清楚。

00:35:24 - 00:35:27
你把一組原本可以包含的條文解釋成排斥。

00:35:27 - 00:35:28
那個沒有好處。

00:35:29 - 00:35:30
那請問圖什麼，知道嗎？

00:35:31 - 00:35:33
同樣的道理，殺人跟遺棄罪。

00:35:33 - 00:35:38
傳統進起也會說，殺人跟遺棄是排斥的，有殺人故意就沒有遺棄故意。

00:35:39 - 00:35:39
那個說法沒有意義。

00:35:40 - 00:35:42
你把他們解釋成排斥，是真的沒有任何的好處。

00:35:43 - 00:35:45
就讓他們一起協力在競合比較好了，對不對？

00:35:45 - 00:35:46
所以我先說啊。

00:35:48 - 00:35:50
這種互斥動想要怎麼處理？

00:35:51 - 00:35:54
有些互斥動想見是透過解釋而來的。

00:35:55 - 00:35:57
那這種好辦嘛，你就不要這樣解釋嘛，問題就解決了，對不對？

00:35:58 - 00:36:00
可是難就難在說，有

00:36:00 - 00:36:02
起訴的條件，像放火罪1734。

00:36:03 - 00:36:06
或者像墮胎罪289291，那個等一下我會帶各位看到。

00:36:07 - 00:36:13
這種立法上就已經明確規定它是互斥的啊，這種立法上已經明確規定為互斥的構成要件。

00:36:13 - 00:36:15
你要怎麼去阻止他啊。

00:36:16 - 00:36:17
再老師在文章裡面說啦。

00:36:18 - 00:36:18
第一個啊。

00:36:19 - 00:36:24
如果能修法把這個互斥構成要件全部修掉,這個當然是最好的做法。

00:36:25 - 00:36:26
可是事實上不可能。

00:36:26 - 00:36:27
你不要期待我的立法院。

00:36:28 - 00:36:30
真的啊，你不要有任何的期待。

00:36:30 - 00:36:33
互斥構成要件所會造成的問題。

00:36:33 - 00:36:35
我們講一下現在的立法委員啊。

00:36:36 - 00:36:37
沈伯洋一定知道。

00:36:38 - 00:36:39
真的啦。

00:36:39 - 00:36:41
你們說沈伯陽以前是這邊的名師嗎？

00:36:41 - 00:36:44
十幾年前的時候，我大學的商學院學生沈伯陽嗎，在這邊最紅嗎？

00:36:45 - 00:36:46
沈伯陽一定知道，他上課應該有教過。

00:36:48 - 00:36:49
你覺得富坤情知道嗎？

00:36:50 - 00:36:51
那個人怎麼可能會知道啊。

00:36:52 - 00:36:55
你覺得黃國昌，因為黃國昌應該知道。

00:36:55 - 00:36:56
但他可能也忠誠不知道。

00:36:57 - 00:36:59
然後，然後還有那個誰？

00:37:00 - 00:37:01
你覺得嚴寬很會知道嗎？

00:37:02 - 00:37:03
嚴寬很呢。

00:37:03 - 00:37:04
不會吧。

00:37:04 - 00:37:05
我不是羞辱他喔。

00:37:06 - 00:37:07
我不想變成小莫怪，我的意思是嚴寬很不是讀法律的，他怎麼會知道？

00:37:11 - 00:37:13
對吧，所以你要立法院修這個東西不可能啊。

00:37:14 - 00:37:16
雖然有些委員具有法律的專業，他們可能知道。

00:37:17 - 00:37:18
可是很多沒有。

00:37:18 - 00:37:21
而且這個東西無關藍綠意識，因為修了又不會有票。

00:37:21 - 00:37:22
你不要期待立法院去修這個東西。

00:37:23 - 00:37:24
所以怎麼辦？

00:37:25 - 00:37:27
立法帶動，我們只好用解釋的嘛，對啊，所以我們翻過來，118頁。

00:37:30 - 00:37:32
我們怎麼解釋啊，來我這邊畫圖。

00:38:00 - 00:38:01
Hello.

00:40:00 - 00:40:01
Hello.

00:42:09 - 00:42:11
我們接著要說，

00:42:11 - 00:42:14
要怎麼透過解釋的方式，

00:42:14 - 00:42:18
把一組原本外觀上看起來是排斥的構成要件，

00:42:18 - 00:42:20
解釋成它們是包含的關係呢？

00:42:20 - 00:42:24
我們要怎麼透過解釋的方式來做這樣的解釋？

00:42:25 - 00:42:27
我們就來看到這一組條文。

00:42:28 - 00:42:29
我們這邊放三組。

00:42:29 - 00:42:30
173,

00:42:30 - 00:42:32
289還有227,

00:42:32 - 00:42:34
我們來放這三組不同的條文。

00:42:35 - 00:42:36
我們先講法理,

00:42:36 - 00:42:39
接著呢，再來操作實際的個案。

00:42:41 - 00:42:43
我們先以左上方的放火罪為例。

00:42:44 - 00:42:46
放火罪啊，我們現在來看到173這個條文。

00:42:47 - 00:42:52
173條說，放火燒毀現有人所在的建築物。

00:42:53 - 00:42:56
173跟174共同包含的是哪一個部分？

00:42:57 - 00:42:58
放火燒毀建築物。

00:42:59 - 00:43:19
ABC，

00:43:19 - 00:43:40
對不對？

00:43:41 - 00:43:42
他們用什麼要素做分界？

00:43:42 - 00:43:43
裡面有沒有人？

00:43:44 - 00:43:46
所以有人，我們寫P。

00:43:47 - 00:43:49
沒有人，就是有人的反面。

00:43:49 - 00:43:51
所以我們寫非P。

00:43:51 - 00:43:54
他們的邏輯關係變這樣，OK吧，很明顯。

00:43:54 - 00:43:56
好，那我們接著想喔，

00:43:58 - 00:44:00
房子裡面有人，

00:44:00 - 00:44:00
人他並不是一個建構工廠的要素的話

00:44:02 - 00:44:05
那麼我們在構成要件該當性的審查上就怎麼樣

00:44:06 - 00:44:07
不用看他

00:44:07 - 00:44:08
知道嗎，就不用看他

00:44:09 - 00:44:11
所以其實174這個條文

00:44:11 - 00:44:14
要構成要件審查的東西只剩什麼

00:44:16 - 00:44:16
只剩ABC

00:44:17 - 00:44:19
放火燒毀建築物

00:44:19 - 00:44:20
只剩這個東西

00:44:20 - 00:44:23
所以透過這樣的解釋，他們不就包含了嗎

00:44:24 - 00:44:28
變成怎麼樣,174是基本,173是條強重

00:44:28 - 00:44:29
變成這樣,對吧

00:44:29 - 00:44:32
174是基本,173是條強重

00:44:32 - 00:44:34
所以透過這種解釋方式

00:44:34 - 00:44:36
P是有人,是建構不法的要素

00:44:37 - 00:44:39
非P是沒有人，不是這個不法的要素

00:44:40 - 00:44:45
犯罪審查上，不用去看這一個非建構不法的非P

00:44:45 - 00:44:47
所以174只剩下ABC

00:44:47 - 00:44:51
進而啊，如果行為人發生構成要件錯誤的話

00:44:53 - 00:44:57
我們雖然沒有辦法對行為人一三的歸責，可是至少可以對他一條歸責

00:44:58 - 00:44:59
啊

00:44:59 - 00:45:00
像我剛剛說的

00:45:01 - 00:45:03
我以為這個是廢棄的廠房,沒有人在

00:45:03 - 00:45:05
我去放火燒它

00:45:05 - 00:45:07
結果裡面竟然有一個流浪漢逃出來了

00:45:08 - 00:45:10
我沒辦法論173

00:45:10 - 00:45:11
因為我沒有認知

00:45:11 - 00:45:13
可是我可不可以論174的毀棄罪

00:45:14 - 00:45:15
當然可以

00:45:15 - 00:45:17
為什麼,因為我確實知道我在放火燒毀建築物

00:45:18 - 00:45:19
有嗎，對不對

00:45:19 - 00:45:19
證據都毀失了嗎

00:45:19 - 00:45:21
所以這樣處理的話，我至少可以論什麼

00:45:21 - 00:45:23
174毀損罪啊，對不對

00:45:23 - 00:45:24
這樣問題不就解決了

00:45:26 - 00:45:26
所以這個是

00:45:27 - 00:45:29
其中的第一種條文，173跟

00:45:29 - 00:45:30
174

00:45:30 - 00:45:35
所以套到我們課本上那個罪疑惟輕原則，一樣可以解決的

00:45:36 - 00:45:37
我這個罪疑惟輕原則講的是失火

00:45:38 - 00:45:40
行為人失火燒毀一個廢棄的工廠

00:45:41 - 00:45:42
後來有流浪漢逃出來

00:45:42 - 00:45:46
可是我們卻不知道在失火的當下那個流浪漢人在廠房裡面還是外面

00:45:47 - 00:45:48
我在想的是我剛剛講的難題是什麼

00:45:49 - 00:45:51
照原本條文的規定

00:45:51 - 00:45:52
你不能論述173

00:45:53 - 00:45:55
因為不能證明流浪漢在裡面

00:45:56 - 00:45:57
所以以為這個結果

00:45:57 - 00:45:59
你也不能論述174

00:45:59 - 00:46:00
因為你也不能證明

00:46:00 - 00:46:02
那個工廠去沒有人在

00:46:02 - 00:46:03
兩難嘛對不對

00:46:03 - 00:46:05
那如果他會這個解釋呢

00:46:05 - 00:46:07
174海報看他沒有人

00:46:07 - 00:46:09
不用啊,只要看ABC啊

00:46:09 - 00:46:11
那隻開BC的話好，我們說嘛

00:46:11 - 00:46:13
不短過173，因為不能證明裡面有人

00:46:14 - 00:46:17
但行為人總是放火燒毀的建築物，沒有失火燒毀的一個建築物，沒有錯嘛

00:46:18 - 00:46:19
是否可以起訴

00:46:19 - 00:46:21
可以啊，我們就起訴了，對不對

00:46:22 - 00:46:24
來，289到291結束問題也是一樣吧

00:46:24 - 00:46:26
只是這裡各位腦筋要稍微轉一下

00:46:27 - 00:46:29
我們來看喔，這一組條文同學可能以前沒有看過

00:46:30 - 00:46:31
非常的根本的條文

00:46:31 - 00:46:33
墮胎罪，289還有291

00:46:33 - 00:46:34
289是什麼呢？

00:46:35 - 00:46:38
受囑託而承諾的墮胎

00:46:38 - 00:46:41
289號，受囑託而承諾的墮胎

00:46:41 - 00:46:45
291是未受囑託，未得承諾的墮胎

00:46:46 - 00:46:47
各位可能會想這個在罰什麼

00:46:48 - 00:46:53
我先說啦，現在的人工流產行為絕大多數都依照優生保健法，卻違法了

00:46:54 - 00:46:56
所以會實際上被判這兩條的

00:46:57 - 00:46:59
通常是一些很奇怪很奇怪的狀況

00:47:00 - 00:47:03
比如說如果有一個孕婦他懷孕已經七八個月都快要生了

00:47:03 - 00:47:06
那個孕婦突然跟我說，我不想生了啦

00:47:06 - 00:47:08
你讓我把小孩拿掉好不好

00:47:08 - 00:47:09
我說好啊，你要我怎麼做

00:47:09 - 00:47:10
說都可以，於是呢

00:47:11 - 00:47:12
我就拿鐵鎚去槌他肚子

00:47:13 - 00:47:14
後來他胎兒就沒了這樣

00:47:14 - 00:47:15
那我犯的是什麼呢

00:47:16 - 00:47:17
好吧

00:47:17 - 00:47:18
受囑託得承諾墮胎，那所以291在罰什麼呢

00:47:20 - 00:47:22
未受囑託未得承諾，我在路上看到一個孕婦

00:47:22 - 00:47:25
我就過去就狂踹她肚子，讓她流產，這樣的話我犯的就是

00:47:26 - 00:47:28
291，就是291

00:47:30 - 00:47:32
好，這一組條文的話，我們來看喔

00:47:35 - 00:47:36
AB的話比較沒有疑問

00:47:37 - 00:47:38
289、291共同的要件是什麼

00:47:39 - 00:47:40
懷胎婦女

00:47:40 - 00:47:42
還有墮胎，這是他們共同的嘛，對不對？

00:47:43 - 00:47:45
289跟291用什麼來做分界？

00:47:46 - 00:47:48
用孕婦的意願，用這個東西來做分界。

00:47:49 - 00:47:50
那你看喔

00:47:51 - 00:47:56
為什麼291的未受囑託未得承諾是P？

00:47:57 - 00:48:00
然後289的受囑託得承諾

00:48:00 - 00:48:01
反而是非P。

00:48:02 - 00:48:05
有沒有感覺，你們可能想是不是我寫錯了，

00:48:05 - 00:48:06
沒有，我沒有寫錯。

00:48:06 - 00:48:10
對啊，為什麼有個位的反而是P，啊沒有個位的反而是非P。

00:48:10 - 00:48:11
很簡單啊。

00:48:12 - 00:48:14
你覺得，289跟291哪個嚴重？

00:48:14 - 00:48:15
當然291嚴重啊，

00:48:16 - 00:48:19
因為291這個行為它除了侵害到胎兒之外，

00:48:19 - 00:48:22
它也侵害到了懷胎婦女的身體自主權。

00:48:23 - 00:48:24
懂這個意思吧?

00:48:24 - 00:48:26
289沒有這個問題啊,289那個孕婦是同意的啊,

00:48:27 - 00:48:27
對不對?

00:48:28 - 00:48:34
所以291的話呢,未受囑託未得承諾,因為它同時侵害了懷胎婦女的身體自主權,

00:48:35 - 00:48:36
所以這個東西是一個P。

00:48:37 - 00:48:38
構成不法的要素。

00:48:39 - 00:48:42
既然未受囑託未得承諾是一個構成不法的要素的話,

00:48:42 - 00:48:45
那它的反面,受囑託得承諾,

00:48:45 - 00:48:46
是不是這個不法的要素?

00:48:47 - 00:48:47
就不是啦,

00:48:48 - 00:48:48
對不對？就不是啦。

00:48:49 - 00:48:50
所以犯罪的審查的時候要不要看它？

00:48:51 - 00:48:51
不用。

00:48:53 - 00:48:56
於是我們回來看之前東吳法律所這一題。

00:48:57 - 00:48:57
117頁。

00:48:58 - 00:48:59
這一題好久了

00:48:59 - 00:49:18
哇塞，

00:49:18 - 00:49:42
13年前

00:49:42 - 00:49:44
對，那個是蔡老師還在東吳的時候

00:49:45 - 00:49:46
的題目。

00:49:47 - 00:49:48
我覺得這一題很有趣

00:49:48 - 00:49:52
這一題，我是一百年考上嘛，我一百年畢業嘛。

00:49:52 - 00:49:56
那101年的時候，我班上有一個同學，他突然想考研究所。

00:49:57 - 00:49:59
然後，那個同學他就打電話來問我，說，

00:50:02 - 00:50:03
289，客觀上或符合，對不對？

00:50:05 - 00:50:07
那個女生不想流產嘛，客觀上不符合嗎？

00:50:08 - 00:50:11
但那個行為人主觀上是不是以為那個被害人想墮胎，對不對？

00:50:12 - 00:50:13
所以主觀上就有故意，客觀導上主觀導都變什麼？

00:50:16 - 00:50:17
未遂。

00:50:17 - 00:50:18
那289有法未遂嗎？

00:50:19 - 00:50:20
沒有啊，對不對，沒有啊。

00:50:21 - 00:50:23
好，再來右邊，那291這邊呢？

00:50:24 - 00:50:25
291這邊，客觀上是不是有符合？

00:50:27 - 00:50:30
有啊，客觀上那個孕婦沒有想墮胎啊。

00:50:30 - 00:50:31
客觀上符合。

00:50:31 - 00:50:35
在主觀上這個行為人有知道孕婦不想墮胎嗎？

00:50:35 - 00:50:35
沒有。

00:50:36 - 00:50:37
所以291變什麼？

00:50:38 - 00:50:38
變過失。

00:50:39 - 00:50:40
291有過失嗎？

00:50:40 - 00:50:41
沒有。

00:50:41 - 00:50:45
所以你會發現，整體你如果照原本的法條去推導。

00:50:45 - 00:50:47
你未遂，你過失。

00:50:48 - 00:50:52
但289不罰未遂，291不罰過失，從行為人有罪了，對吧？

00:50:53 - 00:50:54
來，那如果照蔡老師這樣解法呢？

00:50:55 - 00:50:56
我們再看一次喔。

00:50:58 - 00:51:00
291的未受主託,未

00:51:00 - 00:51:01
得承諾。

00:51:01 - 00:51:04
他是非,他是建構不法的要素。

00:51:04 - 00:51:09
所以289的受主託得承諾,他不是建構不法的要素。

00:51:10 - 00:51:12
不是,他不是這個不法的要素。

00:51:12 - 00:51:13
所以呢,

00:51:14 - 00:51:16
我們在審查289的時候,

00:51:16 - 00:51:20
不用看暴力，不用看有沒有行為人受囑託得承諾，不用。

00:51:20 - 00:51:22
因此結論是什麼?

00:51:22 - 00:51:24
289是基本，291是加重。

00:51:26 - 00:51:28
我們在做的時候，只要看什麼呢？

00:51:29 - 00:51:32
行為人有沒有為一個懷胎婦女墮胎。

00:51:33 - 00:51:34
所以回到這一題。

00:51:35 - 00:51:37
我們行為人都不到291，沒有錯。

00:51:37 - 00:51:39
因為他沒有291的故意。

00:51:40 - 00:51:42
可是他至少可不刻意的故意計算。

00:51:42 - 00:51:42
可以啊。

00:51:43 - 00:51:46
客觀上他為懷胎婦女墮胎，主觀上他也知道嘛。

00:51:46 - 00:51:47
刻意就計算啦，對不對，所以透過這個方式呢，

00:51:49 - 00:51:51
可以讓行為人改論，故意計算。

00:51:52 - 00:51:52
好。

00:51:53 - 00:51:54
最後我們來看刑法條文，227。

00:51:56 - 00:51:58
227這個年齡，我們就用這個長條圖。

00:52:00 - 00:52:01
這樣會比較明確。

00:52:02 - 00:52:04
227的第一項是未滿14。

00:52:04 - 00:52:06
所以就0到13嘛。

00:52:06 - 00:52:09
227的第三項是14以上未滿16,

00:52:09 - 00:52:10
那就14到15嘛。

00:52:11 - 00:52:12
所以各位,

00:52:13 - 00:52:15
227這一組條文,

00:52:17 - 00:52:19
嗯,這樣寫同學怕會誤會,

00:52:20 - 00:52:21
我就乾脆照法條來寫。

00:52:22 - 00:52:24
就0到14,14到16,

00:52:25 - 00:52:26
未滿了。

00:52:28 - 00:52:29
我這樣寫同學比較不會誤會。

00:52:31 - 00:52:33
227這個條文,

00:52:34 - 00:52:36
乍看之下,

00:52:36 - 00:52:38
第一項是所有未滿14，就0到13嘛。

00:52:38 - 00:52:41
第二項是14以上，未滿16。

00:52:42 - 00:52:44
那就是14、15嘛，這個年紀。

00:52:45 - 00:52:46
原本看起來兩個條文是排斥的,

00:52:46 - 00:52:49
可是我們剛說啦，如果你把它解釋成排斥的,

00:52:50 - 00:52:51
那發生錯誤怎麼辦，對不對？

00:52:52 - 00:52:56
所以學者會認為說，我們要把它解釋成包含的關係，

00:52:56 - 00:52:57
來怎麼解釋呢？

00:52:58 - 00:52:59
這個思考一樣很簡單。

00:53:01 - 00:53:02
你要把一跟三項合在一起看。

00:53:03 - 00:53:06
你把一三項合在一起看的時候你就會發現，

00:53:07 - 00:53:10
其實227這一組條文，

00:53:11 - 00:53:13
他們所要處理的是什麼？

00:53:14 - 00:53:17
所有跟未滿16歲的人發生性關係,

00:53:17 - 00:53:19
立法者都想罰，對吧？

00:53:20 - 00:53:22
然後呢，為什麼會有一個第一項而且還更重？

00:53:23 - 00:53:24
因為立法者覺得，

00:53:25 - 00:53:31
性關係的年紀如果太小的話，會對那個幼年人的身心形成更強烈的傷害。

00:53:32 - 00:53:34
所以各位,我們兩項對照之下可以知道,

00:53:35 - 00:53:36
我再講一次喔,

00:53:36 - 00:53:38
立法者透過227這個條文想怎麼樣?

00:53:39 - 00:53:45
他想罰的是所有跟未滿16歲發生性關係的行為。

00:53:46 - 00:53:47
所以其實誰是根本?

00:53:47 - 00:53:48
第三項是基本。

00:53:49 - 00:53:52
第三項他雖然說14以上未滿16，

00:53:52 - 00:53:54
但其實第三項立法者是要罰什麼？

00:53:54 - 00:53:55
所有跟未滿16有關的。

00:53:56 - 00:53:59
然後呢，未滿14，因為身心傷害更大嘛。

00:54:00 - 00:54:01
這第一項就講究。

00:54:01 - 00:54:03
這是立法者背後真正的意涵，知道嗎？

00:54:03 - 00:54:06
所以兩項都要直下，我們就會發現誰基本誰加重。

00:54:07 - 00:54:07
第三項基本。

00:54:08 - 00:54:09
第一項加重。

00:54:09 - 00:54:12
於是啊，我們剛講的問題過犯理論。

00:54:13 - 00:54:15
火燒路伯言跟15歲的國中生性交。

00:54:15 - 00:54:17
路伯言繼續找一個13歲的。

00:54:18 - 00:54:19
這時候我至少可以論什麼？

00:54:19 - 00:54:20
第三項啊。

00:54:20 - 00:54:22
因為第三項是基本，知道嗎？

00:54:22 - 00:54:24
所以這個是互斥條件的警備方式哈。

00:54:24 - 00:54:27
透過警示的方式找出誰是基本，誰是加重。

00:54:28 - 00:54:30
這個叫互斥條件。

00:54:30 - 00:54:33
好，所以這個整體處理方式大概是這樣子哈。

00:54:34 - 00:54:35
這個東西啊。

00:54:36 - 00:54:37
有些同學。

00:54:38 - 00:54:39
嗯，我這樣問哈。

00:54:40 - 00:54:44
我們在學錯誤論的時候，有沒有同學以前聽過什麼「所知所犯」這個處理方式？

00:54:44 - 00:54:45
有聽過嗎？

00:54:45 - 00:54:46
沒聽過很棒。

00:54:46 - 00:54:47
有聽過的話把它忘記。

00:54:48 - 00:54:49
真的，沒聽過很棒。

00:54:50 - 00:54:51
這是過學的處理方式。

00:54:51 - 00:54:52
所知所犯，我真的沒聽過是好的。

00:54:54 - 00:54:57
所知所犯是從唐律來的公式。

00:54:57 - 00:54:58
聽起來我們覺得很可怕。

00:54:59 - 00:54:59
唐律。

00:54:59 - 00:55:00
知道嗎？

00:55:00 - 00:55:02
這樣早期有學者會用。

00:55:02 - 00:55:04
現在沒有人在用了。

00:55:04 - 00:55:08
現在你寫的話,別人會覺得像是古代穿越來的人,怎麼會寫這種東西？

00:55:09 - 00:55:10
沒聽過是好事,有聽過把它忘記,知道嗎？

00:55:11 - 00:55:13
所以我們遇到錯誤的問題。

00:55:14 - 00:55:15
我們請到新的處理方式。

00:55:16 - 00:55:17
不要用什麼「所知所犯」。

00:55:17 - 00:55:22
因為「所知所犯」那一套公式操作下來，很多結論會違反我們刑法的體系。

00:55:24 - 00:55:27
那有學者說，那我們就把「所知所犯」修成符合三階論。

00:55:29 - 00:55:30
那把「所知所犯」修成符合三階論的話，

00:55:31 - 00:55:33
那就不要「所知所犯」，拿三階論處理就好了啦，對不對？

00:55:33 - 00:55:35
所以那個東西,沒聽過很好,有聽過把它忘記。

00:55:36 - 00:55:38
這個是上個世代的東西了,我們現在刑法學者不會這樣處理錯誤的問題了。

00:55:41 - 00:55:44
好,所以這個是我們所講到的。

00:55:44 - 00:55:47
選擇要素的錯誤,還有這個互斥條件的錯誤。

00:55:47 - 00:55:49
我們就看到這邊。

00:55:49 - 00:55:51
OK，11點了哈，我們中場休息一下。

00:55:52 - 00:55:55
等一下我們再來看一個難題，因果一chains的偏離。

00:55:55 - 00:55:56
我們這邊先休息一下。

00:56:00 - 00:56:05
那我們今天來看118頁這邊第二大點關於因果歷程的偏離。

00:56:05 - 00:56:07
在因果歷程偏離什麼意思啊？

00:56:07 - 00:56:08
概念上是這樣吧。

00:56:08 - 00:56:12
行為人想做一個犯罪，所以也實現了犯罪的結果。

00:56:12 - 00:56:19
只是犯罪實現的過程跟行為人的想像有點不太一樣，這個東西我們叫做因果歷程的偏離。

00:56:20 - 00:56:27
我以前在網路上看過一個動畫，這個動畫用手機放可能太小，我大概就形容一下這個過程。

00:56:30 - 00:56:30
呃

00:56:30 - 00:56:31
就是這樣子。

00:56:31 - 00:56:35
就是有個人啊，他頭上頂了一顆球。

00:56:36 - 00:56:37
這個我們就講這個叫A。

00:56:38 - 00:56:40
A的頭上頂了一顆球。

00:56:40 - 00:56:45
甲呢，要持棒球把A頭上那顆球打下來。

00:56:45 - 00:56:51
結果假丟的時候，沒有丟到A頭上那顆球。

00:56:51 - 00:56:51
丟到了A的頭。

00:56:51 - 00:56:56
A的頭被打到之後，A很痛，頭就歪了，然後他頭上的球也掉了。

00:56:56 - 00:56:57
因果歷程偏離啊。

00:56:58 - 00:56:58
不是嗎？

00:56:58 - 00:57:00
原本要丟那個球。

00:57:00 - 00:57:03
結果沒丟到啊，丟到頭啊，丟到頭之後那個人痛，頭痛啊。

00:57:04 - 00:57:05
那個球還掉下來了。

00:57:05 - 00:57:08
這種東西就怎麼去講啊，因果歷程的偏離。

00:57:09 - 00:57:11
那不管是哪一種情況。

00:57:11 - 00:57:13
不管是哪一種果的歷程偏離。

00:57:13 - 00:57:15
我們首先在定義上來講是這樣子。

00:57:16 - 00:57:18
因為啊，從日常生活觀點來講。

00:57:19 - 00:57:23
我們想做一件事情，跟我們最後實現這件事的中間。

00:57:24 - 00:57:28
那個過程本來就不可能百分之百絕對一樣。

00:57:29 - 00:57:30
這是不可能的。

00:57:30 - 00:57:36
我們日常生活的事情也是啊，你決定去做一件事，跟你最後去實現了這件事。

00:57:36 - 00:57:40
中間的過程真的不可能百分之百會完全一樣。

00:57:40 - 00:57:44
所以我們會說呢，如果只是一個中間的細節性的偏差。

00:57:45 - 00:57:48
這個偏差在日常生活觀點來說不重要的話。

00:57:49 - 00:57:50
那那個不會叫偏離喔。

00:57:50 - 00:57:51
知道嗎？

00:57:51 - 00:57:51
那個不會叫偏離喔。

00:57:52 - 00:57:52
所以比如說。

00:57:54 - 00:57:57
你要去開槍射擊被害人的頭部。

00:57:58 - 00:58:00
結果你打歪了，打到鄰裡

00:58:00 - 00:58:00
的脖子。

00:58:01 - 00:58:04
然後被害人因為頸動脈出血，人還是死了。

00:58:05 - 00:58:06
我們不會講那個叫偏離。

00:58:06 - 00:58:07
那個不重要，知道嗎？

00:58:07 - 00:58:08
那個不重要。

00:58:09 - 00:58:15
或者比如說，行為人要毒殺被害人，行為人以為這一種毒藥

00:58:16 - 00:58:18
會對被害人的肝臟

00:58:18 - 00:58:19
造成傷害。

00:58:19 - 00:58:20
被害人會肝衰竭而死。

00:58:21 - 00:58:25
結果這個毒藥呢,其實是傷腎,被害人腎衰竭死掉了。

00:58:25 - 00:58:26
那個不重要,知道吧?

00:58:26 - 00:58:27
這不重要啊。

00:58:27 - 00:58:33
因為你要想啊,如果我們對的要求是所有的因果歷程都要認知的話。

00:58:33 - 00:58:35
那個基本上不可能。

00:58:35 - 00:58:37
所有因果歷程都要認知的話，那行為人認知一定會有偏差。

00:58:39 - 00:58:41
所以現在不是每個都被因果歷程錯誤了，不會這樣認定，知道嗎？

00:58:41 - 00:58:42
所以

00:58:44 - 00:58:46
我們講，如果是細節性而不重要的話，這個不能認為因果歷程的偏離啊。

00:58:49 - 00:58:56
好，那如果是一般的因果歷程偏離，也是我們前面所講到的醫院案、救護車車禍案。

00:58:56 - 00:58:58
如果是那一期案例的話，其實我們前面都講過了。

00:59:00 - 00:59:03
像醫院案、救護車車禍這些案例。

00:59:03 - 00:59:05
我們最後會怎麼處理？

00:59:06 - 00:59:07
就客觀規則嘛，對不對？

00:59:08 - 00:59:09
我們複習一下啊。

00:59:09 - 00:59:10
救護車車禍案。

00:59:10 - 00:59:12
我們先開計稅犯嗎？

00:59:12 - 00:59:13
計稅犯不成立，為什麼？

00:59:13 - 00:59:15
因為結果客觀上不可歸責。

00:59:15 - 00:59:16
那我們再開偽稅犯。

00:59:16 - 00:59:18
未遂犯會成立，會啊。

00:59:18 - 00:59:20
所以那一種案例，我們最後的結論認為是未遂犯。

00:59:20 - 00:59:22
這個情境的方式也都跟各位示範過了。

00:59:24 - 00:59:28
接著我們來看下面這個經濟問題，故意對因果歷程的認知。

00:59:29 - 00:59:30
這個

00:59:30 - 00:59:30
這個

00:59:30 - 00:59:31
這個

00:59:31 - 00:59:31
這個

00:59:31 - 00:59:31
這個

00:59:31 - 00:59:32
這個

00:59:32 - 00:59:32
這個

00:59:32 - 00:59:32
這個

00:59:32 - 00:59:32
這個

00:59:32 - 00:59:33
這個

00:59:33 - 00:59:33
這個

00:59:33 - 00:59:33
這個

00:59:33 - 00:59:34
這個

00:59:34 - 00:59:34
這個

00:59:34 - 00:59:34
這個

00:59:34 - 00:59:35
這個

00:59:35 - 00:59:35
這個

00:59:35 - 00:59:35
這個

00:59:35 - 00:59:35
這個

00:59:35 - 00:59:36
這個

00:59:36 - 00:59:36
這個

00:59:36 - 00:59:36
這個

00:59:36 - 00:59:37
這個

00:59:37 - 00:59:37
這個

00:59:37 - 00:59:37
這個

00:59:37 - 00:59:38
這個

00:59:38 - 00:59:38
這個

00:59:38 - 00:59:38
這個

00:59:38 - 00:59:38
這個

00:59:38 - 00:59:39
這個

00:59:39 - 00:59:39
這個

00:59:39 - 00:59:39
這個

00:59:39 - 00:59:40
這個

00:59:40 - 00:59:40
這個

00:59:40 - 00:59:40
這個

00:59:40 - 00:59:41
這個

00:59:41 - 00:59:41
這個

00:59:41 - 00:59:41
這個

00:59:41 - 00:59:41
這個

00:59:41 - 00:59:42
這個

00:59:42 - 00:59:42
這個

00:59:42 - 00:59:42
這個

00:59:42 - 00:59:43
這個

00:59:43 - 00:59:43
這個

00:59:43 - 00:59:43
這個

00:59:43 - 00:59:44
這個

00:59:44 - 00:59:44
這個

00:59:44 - 00:59:44
這個

00:59:44 - 00:59:44
這個

00:59:44 - 00:59:45
這個

00:59:45 - 00:59:45
這個

00:59:45 - 00:59:45
這個

00:59:45 - 00:59:46
這個

00:59:46 - 00:59:46
這個

00:59:46 - 00:59:46
這個

00:59:46 - 00:59:47
這個

00:59:47 - 00:59:47
這個

00:59:47 - 00:59:47
這個

00:59:47 - 00:59:47
這個

00:59:47 - 00:59:48
這個

00:59:48 - 00:59:48
這個

00:59:48 - 00:59:48
這個

00:59:48 - 00:59:49
這個

00:59:49 - 00:59:49
這個

00:59:49 - 00:59:49
這個

00:59:49 - 00:59:50
這個

00:59:50 - 00:59:50
這個

00:59:50 - 00:59:50
這個

00:59:50 - 00:59:50
這個

00:59:50 - 00:59:51
這個

00:59:51 - 00:59:51
這個

00:59:51 - 00:59:51
這個

00:59:51 - 00:59:52
這個

00:59:52 - 00:59:52
這個

00:59:52 - 00:59:52
這個

00:59:52 - 00:59:53
這個

00:59:53 - 00:59:53
這個

00:59:53 - 00:59:53
這個

00:59:53 - 00:59:53
這個

00:59:53 - 00:59:54
這個

00:59:54 - 00:59:54
這個

00:59:54 - 00:59:54
這個

00:59:54 - 00:59:55
這個

00:59:55 - 00:59:55
這個

00:59:55 - 00:59:55
這個

00:59:55 - 00:59:56
這個

00:59:56 - 00:59:56
這個

00:59:56 - 00:59:56
這個

00:59:56 - 00:59:56
這個

00:59:56 - 00:59:57
這個

00:59:57 - 00:59:57
這個

00:59:57 - 00:59:57
這個

00:59:57 - 00:59:58
這個

00:59:58 - 00:59:58
這個

00:59:58 - 00:59:58
這個

00:59:58 - 00:59:59
這個

00:59:59 - 00:59:59
這個

00:59:59 - 00:59:59
這個

00:59:59 - 00:59:59
這個

00:59:59 - 01:00:00
東西啊。

01:00:00 - 01:00:02
總而言之，文章不管多久，

01:00:02 - 01:00:03
都要看。

01:00:03 - 01:00:04
這個是十幾年前的文章，

01:00:05 - 01:00:06
一直都會存在，

01:00:06 - 01:00:07
這個是很常見的現象。

01:00:09 - 01:00:10
我們來看下面這個東西喔。

01:00:10 - 01:00:11
來，案例思考習題，

01:00:12 - 01:00:13
第一個這裡說啊，

01:00:13 - 01:00:16
甲拿刀要刺殺仇人A的胸腔，

01:00:17 - 01:00:19
結果正好這個A一個下蹲的動作，

01:00:19 - 01:00:21
刀子刺進那個脖子。

01:00:21 - 01:00:22
A死掉了。

01:00:23 - 01:00:24
這個案例我們說什麼呢？

01:00:24 - 01:00:25
不重要嘛，對不對？

01:00:25 - 01:00:26
其實這種案例，

01:00:27 - 01:00:30
我們把它從客觀跟主觀兩個面向來看。

01:00:31 - 01:00:32
你看第一個案例喔,

01:00:33 - 01:00:34
原本要刺胸腔,

01:00:34 - 01:00:36
結果刺到脖子。

01:00:37 - 01:00:38
第一個啊,客觀的面向。

01:00:40 - 01:00:43
你覺得刺到胸腔跟脖子之間的差異,

01:00:44 - 01:00:46
算不算是反常的因果歷程？

01:00:47 - 01:00:48
還好，

01:00:48 - 01:00:48
對不對？

01:00:48 - 01:00:49
沒有太意外嘛，

01:00:49 - 01:00:50
沒有很反常。

01:00:50 - 01:00:52
再來,就主觀來講,

01:00:52 - 01:00:53
那我們也說啦,

01:00:54 - 01:00:58
故意本來就不需要對因果歷程有巨細靡遺的認知。

01:00:59 - 01:01:25
有一個大學上的認知,

01:01:25 - 01:01:41
那就是有故意

01:01:42 - 01:01:43
所以這邊的故意有,

01:01:44 - 01:01:45
所以這個叫什麼？

01:01:45 - 01:01:46
故意既遂，

01:01:46 - 01:01:46
對不對？

01:01:47 - 01:01:48
好，

01:01:48 - 01:01:49
第二個案例，

01:01:49 - 01:01:50
我們剛說的,

01:01:50 - 01:01:51
舊物之毀壞,

01:01:51 - 01:01:52
認為一歲嘛,

01:01:52 - 01:01:52
對不對?

01:01:52 - 01:01:53
這個沒有疑問。

01:01:53 - 01:01:55
再來會有疑問的是第三個案例

01:01:55 - 01:01:57
你看喔，第三個案例。

01:01:58 - 01:01:59
甲誤以為磨菇會中毒

01:02:01 - 01:02:02
我們來看第三點。

01:02:03 - 01:02:05
案例三這一種情形。

01:02:06 - 01:02:06
我們說呢,

01:02:06 - 01:02:09
客觀構成要件相對比較不會有疑問。

01:02:10 - 01:02:10
行為,

01:02:11 - 01:02:11
結果,

01:02:12 - 01:02:12
條經果

01:02:12 - 01:02:13
客觀規則。

01:02:14 - 01:02:14
都具備啊，

01:02:15 - 01:02:15
對不對？

01:02:15 - 01:02:16
都沒有疑問啊。

01:02:16 - 01:02:17
有沒有條經果關係？

01:02:17 - 01:02:17
有啊。

01:02:18 - 01:02:19
客觀可不可以規則？

01:02:19 - 01:02:20
當然可以啊。

01:02:21 - 01:02:22
給小朋友吃腐敗的蘑菇，

01:02:23 - 01:02:24
有沒有製造法所不容許的風險？

01:02:24 - 01:02:25
有啊。

01:02:25 - 01:02:26
那風險有沒有實現？

01:02:26 - 01:02:27
當然也有啊。

01:02:28 - 01:02:28
被害人自我負責？

01:02:29 - 01:02:30
人家他還是小孩啊。

01:02:30 - 01:02:31
這怎麼會是被害人自我負責,

01:02:31 - 01:02:31
對不對？

01:02:32 - 01:02:32
所以就解（釋）的話,

01:02:33 - 01:02:35
客觀構成要件都具備沒有問題喔。

01:02:36 - 01:02:37
會有問題的是什麼呢？

01:02:38 - 01:02:39
行為人的主觀

01:02:39 - 01:02:40
主觀。

01:02:41 - 01:02:42
在這種案例當中

01:02:43 - 01:02:46
行為人的主觀到底有沒有滿足？

01:02:46 - 01:02:47
為什麼？

01:02:48 - 01:02:50
因為行為人客觀上所製造的風險，

01:02:51 - 01:02:52
他的主觀有認知嗎？

01:02:53 - 01:02:53
其實沒有，

01:02:53 - 01:02:54
對不對？

01:02:54 - 01:02:56
所以這裡會不會因此而阻卻故意？

01:02:56 - 01:02:58
所以我們就要來看一下129頁這邊喔。

01:02:58 - 01:03:00
故意對因果歷程的認知,

01:03:01 - 01:03:03
要認知到什麼樣的程度呢?

01:03:03 - 01:03:05
傳統上有三說,

01:03:05 - 01:03:07
第一說是最早期的說法,

01:03:07 - 01:03:08
叫重要性理論。

01:03:08 - 01:03:09
重要性理論認為呢,

01:03:10 - 01:03:13
行為人只需要認知到因果歷程的重要部分就夠了。

01:03:13 - 01:03:15
這個說法是傳統的說法沒有錯,

01:03:16 - 01:03:18
但這個說法現在比較少人採。

01:03:18 - 01:03:20
因為這個說法的問題在於說,

01:03:20 - 01:03:21
那什麼叫重要？

01:03:21 - 01:03:22
很模糊嘛。

01:03:22 - 01:03:24
再來第二個極端叫否定說。

01:03:24 - 01:03:25
否定說是覺得說呢,

01:03:26 - 01:03:28
那個因果歷程根本不是故意所要認識的對象。

01:03:29 - 01:03:30
也有這樣的說法。

01:03:31 - 01:03:32
所以採否定說的話，

01:03:32 - 01:03:33
這種案例根本就不是問題。

01:03:34 - 01:03:35
那就直接論傷害罪。

01:03:35 - 01:03:36
這也是少數說。

01:03:37 - 01:03:38
這裡的話,

01:03:38 - 01:03:39
括號三,

01:03:39 - 01:03:43
蔡聖偉老師跟許玉安老師他們比較傾向的是第三說,

01:03:43 - 01:03:46
叫做風險認識說。

01:03:46 - 01:03:46
好,

01:03:47 - 01:03:47
所以風險認識說,

01:03:48 - 01:03:50
你來看它圈圈一的後面。

01:03:51 - 01:03:51
他說呢,

01:03:53 - 01:03:57
有認為所行為人要認知到風險是否達到,

01:03:58 - 01:04:00
適合導致結果發生的程度。

01:04:00 - 01:04:02
要如何知道這個有效傷害的方法？

01:04:02 - 01:04:04
也有認為說呢，

01:04:04 - 01:04:05
行為人的主觀想像，

01:04:05 - 01:04:07
跟客觀事實呢，

01:04:07 - 01:04:09
兩者只要在製造法

01:04:09 - 01:04:11
所不允許的風險的範圍之內

01:04:11 - 01:04:13
一致就夠了。

01:04:13 - 01:04:17
這一種說法，最簡單的理解來對有助益。

01:04:18 - 01:04:20
蔡老師在文章裡面有提一個比較簡單的理解方式。

01:04:21 - 01:04:24
蔡老師的意思就是說，照風險意識的說法。

01:04:24 - 01:04:33
只要行為人怎麼樣呢，對於他的行為，在客觀上所製造的風險有所認知。

01:04:34 - 01:04:35
那就是有故意。

01:04:35 - 01:04:37
瞭解嗎？風險意識說法。

01:04:37 - 01:04:46
只要行為人對自己在客觀上所製造的那個風險，有認知的話，他就是具有故意。

01:04:47 - 01:04:47
所以。

01:04:48 - 01:04:48
所以。

01:04:49 - 01:04:50
回到那個蘑菇案。

01:04:51 - 01:04:53
蘑菇案的行為人有故意。

01:04:54 - 01:04:55
恐怕沒有。

01:04:55 - 01:04:55
為什麼？

01:04:56 - 01:04:58
他沒有發現這個蘑菇壞掉了。

01:04:58 - 01:04:58
對不對？

01:04:59 - 01:05:04
想像上，蘑菇案當中，行為人客觀上製造什麼風險？

01:05:05 - 01:05:07
小朋友吃到壞掉的蘑菇而死的風險，對不對？

01:05:08 - 01:05:10
行為人有發現這個蘑菇壞掉嗎？

01:05:10 - 01:05:11
沒有。

01:05:11 - 01:05:13
所以這時候啊，行為人怎麼論罪？

01:05:14 - 01:05:15
這是我們法規故意罪喔。

01:05:16 - 01:05:17
自首怎麼論，你知道嗎？

01:05:18 - 01:05:19
分論未遂跟過失。

01:05:20 - 01:05:23
真的,這件事情只能分論未遂跟過失,為什麼?

01:05:24 - 01:05:25
你說未遂是針對什麼?

01:05:26 - 01:05:29
想像中小孩會死於蘑菇中毒的那個部分。

01:05:30 - 01:05:32
事實上沒有嘛,對不對?所以那個叫未遂。

01:05:34 - 01:05:36
而過失是對哪一個部分？

01:05:36 - 01:05:39
實際上小孩的死亡結果。

01:05:40 - 01:05:42
我們錯誤不是一貫都是這樣處理的嗎？

01:05:42 - 01:05:45
想像中的部分，實際上沒有實現嘛，所以叫未遂。

01:05:46 - 01:05:49
而實際上真的實現卻不在行為人所預料之內的。

01:05:50 - 01:05:51
那個叫主觀故意罪過失。

01:05:51 - 01:05:52
有沒有，我們都這樣處理嘛，對不對？

01:05:53 - 01:05:54
所以這個東西也是蘑菇案當中。

01:05:55 - 01:05:56
再講一次喔，為什麼會分故意跟過失？

01:05:59 - 01:06:00
故意。

01:06:00 - 01:06:03
針對的是行為人原本以為，

01:06:03 - 01:06:09
這個小孩會死於蘑菇對幼童的一般毒性，那個想像中的結果。

01:06:09 - 01:06:10
瞭解吧？

01:06:10 - 01:06:10
沒有實現嘛。

01:06:11 - 01:06:11
所以我們只能論，

01:06:12 - 01:06:12
未遂。

01:06:13 - 01:06:17
那實際上這個小朋友吃到壞掉的蘑菇死掉的結果呢，

01:06:18 - 01:06:19
這不是行為人原本想像的啊。

01:06:20 - 01:06:20
所以論什麼，

01:06:20 - 01:06:21
論過失。

01:06:21 - 01:06:22
OK嗎？

01:06:22 - 01:06:23
所以這種情況，

01:06:23 - 01:06:24
因為行為人沒有認知到那個部分，

01:06:25 - 01:06:27
所以我們只能分論未遂跟過失，

01:06:27 - 01:06:27
然後最後呢？

01:06:28 - 01:06:30
再用55條去想像競合處理。

01:06:31 - 01:06:31
好,

01:06:31 - 01:06:34
所以這個是我們看到的,

01:06:34 - 01:06:35
這一個問題,

01:06:35 - 01:06:37
今年北大法律所考到的。

01:06:39 - 01:06:40
所以我說,

01:06:40 - 01:06:41
這一塊啊,

01:06:41 - 01:06:43
故意對因果歷程的認知。

01:06:44 - 01:06:46
這個東西真的比較偏司律跟法研所。

01:06:47 - 01:06:48
這個比較偏司律跟法研所。

01:06:48 - 01:06:50
三等的同學就看情況

01:06:50 - 01:06:52
這個真的我覺得一般三等就看情況。

01:06:53 - 01:06:54
如果覺得太難的話

01:06:55 - 01:06:56
一般三等的同學就算了

01:06:56 - 01:06:57
沒有關係。

01:07:03 - 01:07:04
然後這一塊的部分，

01:07:05 - 01:07:06
就是這個東西啊。

01:07:07 - 01:07:09
如果有臺大的同學的話，

01:07:09 - 01:07:14
臺大的周漾儀老師對這個部分有提出一個說法叫主觀規則理論。

01:07:15 - 01:07:17
這個東西考臺大刑法組。

01:07:17 - 01:07:18
一定要會。

01:07:18 - 01:07:19
因為周老師會出題嘛，

01:07:19 - 01:07:21
周老師很喜歡出這個東西，

01:07:21 - 01:07:21
主觀規則。

01:07:22 - 01:07:24
但是如果用在一般國考的話，

01:07:24 - 01:07:25
這個不會,

01:07:25 - 01:07:26
沒有關係。

01:07:26 - 01:07:28
因為這個是周老師個人比較獨門的看法。

01:07:29 - 01:07:32
國內應該比較沒有其他學者用這一套理論。

01:07:32 - 01:07:33
所以我說,

01:07:33 - 01:07:34
像主觀規則這個理論,

01:07:35 - 01:07:36
考臺大法研所一定要會,

01:07:37 - 01:07:38
你不會就考不上。

01:07:38 - 01:07:40
但如果你是考一般的國考的話,

01:07:41 - 01:07:42
不用寫到這麼深。

01:07:42 - 01:07:43
沒關係。

01:07:44 - 01:07:44
我舉個例子，

01:07:45 - 01:07:47
呃，這個是哪一個年度啊？

01:07:47 - 01:07:48
四年前。

01:07:50 - 01:07:52
四年前就是110年的律師高考。

01:07:52 - 01:07:53
周老師出的。

01:07:54 - 01:07:57
周老師在題目裡面出了一段敘述是這樣子：

01:07:59 - 01:07:59
因為

01:08:00 - 01:08:01
課本還沒有出來，

01:08:01 - 01:08:01
我就口頭講。

01:08:01 - 01:08:02
它那個沒有很難。

01:08:03 - 01:08:05
反正題目裡的是我講一個簡化版啊。

01:08:05 - 01:08:07
就是行為人他為了殺被害人，

01:08:07 - 01:08:09
所以行為人放火去燒被害人的住宅。

01:08:10 - 01:08:12
題目裡面特別講了一段話。

01:08:12 - 01:08:15
說行為人在放火燒被害人的住宅的時候,

01:08:17 - 01:08:19
行為人的腦袋當中,

01:08:19 - 01:08:21
只浮現出一個圖像,

01:08:21 - 01:08:23
是被害人被烈火焚燒而死。

01:08:24 - 01:08:25
題目裡面特別要強調了,

01:08:26 - 01:08:29
行為人的腦中只有被害人被烈火焚燒而死的想像,

01:08:29 - 01:08:30
而別無其他。

01:08:30 - 01:08:32
他甚至有這樣的想像，

01:08:32 - 01:08:33
結果最後啊，

01:08:33 - 01:08:35
被害人沒有被燒死。

01:08:35 - 01:08:37
被害人是被火逼到頂樓,

01:08:37 - 01:08:38
最後跳樓逃生失敗,

01:08:39 - 01:08:40
人墜地而死。

01:08:40 - 01:08:41
周老師這樣出,

01:08:42 - 01:08:43
他出了一個這樣的題目啊。

01:08:44 - 01:08:44
周老師的題目啊，

01:08:45 - 01:08:45
那用語很明顯。

01:08:46 - 01:08:48
跟他在臺大法研所出的題目，

01:08:48 - 01:08:49
那個用語幾乎一模一樣。

01:08:50 - 01:08:51
這一題，

01:08:51 - 01:08:52
主觀規則怎麼處理，

01:08:52 - 01:08:53
就不說了，

01:08:53 - 01:08:54
因為這個國考不會用到。

01:08:54 - 01:08:56
我們就講用一般的理論會怎麼處理。

01:08:57 - 01:09:23
這一題如果照一般的

01:09:23 - 01:09:40
理論來看的話

01:09:40 - 01:09:41
我們可以怎麼說呢？

01:09:42 - 01:09:44
你看到前面的幾種說法。

01:09:45 - 01:09:46
就前面的幾種說法來講，

01:09:47 - 01:09:47
通說會怎麼看？

01:09:48 - 01:09:49
客觀上來說，

01:09:49 - 01:09:50
這個因果歷程有沒有反常？

01:09:51 - 01:09:52
沒有啊。

01:09:53 - 01:09:54
你放火燒別人家，

01:09:54 - 01:09:55
被害人沒有被燒死，

01:09:56 - 01:09:57
而是逃生失敗而死。

01:09:58 - 01:09:58
不意外啊,

01:09:58 - 01:09:58
對不對?

01:09:59 - 01:09:59
這個不意外啊,

01:10:00 - 01:10:00
周老師的理論小抄怎麼比這個問題，知道吧，但不管怎麼樣，理論上來說啦，就算檢方的想法，這件事情為人是什麼呢？

01:10:08 - 01:10:10
故意殺人既遂，知道吧，故意殺人既遂，傳統的刑法就會說中心的偏差和重要。

01:10:13 - 01:10:15
所以我說，國考就是這樣，國考你不用去鑽研一些特別少見的學說。

01:10:19 - 01:10:22
周老師的理論有他的道理，他有一定道理，沒有錯。

01:10:23 - 01:10:24
但國考不用鑽研這個東西啦。

01:10:25 - 01:10:27
當年我有學生，他也不會主觀歸責啊。

01:10:28 - 01:10:29
但他其他部分寫得不錯。

01:10:30 - 01:10:32
刑法100分，他拿70幾分啊。

01:10:32 - 01:10:33
有啊，臺中局辦的學生，有啊。

01:10:33 - 01:10:36
所以我們這個時候通說怎麼處理就OK了。

01:10:37 - 01:10:42
好，接下來我們來看121頁，第三點，結果的提前發生。

01:10:44 - 01:10:46
我們來看一下，結果的提前發生。

01:10:47 - 01:10:51
這個東西啊,我們要對照的對象是事前故意、非故意。

01:10:52 - 01:10:57
如果我們之前在講事前故意、非故意的內套理論,你都聽得懂的話。

01:10:58 - 01:11:01
結果提前發生，就是它的延伸。

01:11:01 - 01:11:03
你就覺得它很簡單。

01:11:03 - 01:11:05
我再講一次我們前面講過的案例喔。

01:11:06 - 01:11:08
來，我設定案例是這樣。

01:11:09 - 01:11:12
我計畫晚上要射殺我家對面的鄰居。

01:11:14 - 01:11:19
下午我在客廳保養手槍，確認晚上的行兇計畫可以萬無一失的時候啊。

01:11:19 - 01:11:21
不知道為什麼槍枝突然走火。

01:11:22 - 01:11:25
很巧，槍枝走火的時候。

01:11:25 - 01:11:30
我的鄰居剛好在我客廳門外的梯廳等電梯。

01:11:30 - 01:11:34
就這麼巧，子彈穿越門板，打死了這個鄰居。

01:11:35 - 01:11:38
我們上次跟各位講到這個案例的時候。

01:11:38 - 01:11:39
我們說結論像這個叫什麼呢？

01:11:40 - 01:11:41
事前故意，非故意，為什麼？

01:11:43 - 01:11:47
因為啊，雖然我腦袋中有一個我好想殺死鄰居的想法。

01:11:48 - 01:11:54
可是問題在於我在客廳保養手槍的那個階段。

01:11:54 - 01:11:56
你會說這個叫殺人的行為嗎？

01:11:56 - 01:11:57
不會，對不對？

01:11:57 - 01:12:00
那既然這個階段不叫殺人的行為。

01:12:00 - 01:12:04
的話，那麼我腦中這一個好想殺死鄰居的想法，可不可以在法律上被評價成是殺人故意？

01:12:07 - 01:12:08
不可以，不可以。

01:12:09 - 01:12:18
所以啊，雖然行為人腦中有想殺人的想法，有這個事實，沒有錯，可是從法律評價的觀點來講，這個想法還不叫做殺人故意。

01:12:19 - 01:12:20
所以我只能認什麼？

01:12:20 - 01:12:22
我尋釁滋事，OK，可以理解，對吧？

01:12:22 - 01:12:26
所以我上次是不是已經一起跟各位強調，事前故意非故意。

01:12:26 - 01:12:27
他不是敘述面的問題。

01:12:28 - 01:12:33
如果你用敘述面的問題去理解，一起在糾結說，可是我就想殺鄰居啊。

01:12:33 - 01:12:36
你當然想不通啊，因為那個不是事實的問題啊。

01:12:36 - 01:12:37
那個是法律評價的問題。

01:12:37 - 01:12:42
如果這個你get到的話，結果提前發生，就是它的延伸。

01:12:43 - 01:12:51
我們在處理所謂結果提前發生的問題的時候，那些案例，也都跟事前故意或非故意的案例很像。

01:12:52 - 01:12:53
來，大家有個共識。

01:12:54 - 01:12:55
什麼叫結果提前發生？

01:12:56 - 01:13:02
最後的犯罪時，最後的犯罪結果在實現的時間上。

01:13:03 - 01:13:08
比行為人的想像要來得早，就叫做結果提前發生。

01:13:08 - 01:13:11
那不管在哪一說，大家的共識就像我剛所說的。

01:13:12 - 01:13:22
如果這一個過早實現的結果，他是實現在行為人著手之前的的話，那就是什麼呢？

01:13:23 - 01:13:24
事前故意或非故意。

01:13:25 - 01:13:25
OK吧，沒有疑問啊。

01:13:26 - 01:13:28
如果是發生在行為人著手之前的話，那著手前行為人

01:13:30 - 01:13:32
腦中那個想殺人的想法，我們能叫故意嗎？

01:13:32 - 01:13:34
所以實現在著手前的話，那個我們就說呢

01:13:34 - 01:13:37
他叫做事前故意，非故意行為人沒辦法成立

01:13:38 - 01:13:43
故意殺人既遂的犯罪，OK吧？

01:13:44 - 01:13:45
所以體多論過失犯。

01:13:46 - 01:13:46
好。

01:13:47 - 01:13:48
那所以反過來啊。

01:13:48 - 01:13:49
著手之後就是故意嗎?

01:13:51 - 01:13:52
來，我們來看到下面這邊。

01:13:53 - 01:13:56
案例1234，我們等下會分別去看。

01:13:56 - 01:13:59
德國通說的看法（二），就叫做

01:14:00 - 01:14:02
左手標準說。

01:14:02 - 01:14:03
在德國通說的看法。

01:14:04 - 01:14:06
如果這個過早時間的結果在左手前的話。

01:14:06 - 01:14:09
好，OK，是故意非故意，行為人你過失犯。

01:14:10 - 01:14:15
但如果這個過早時間的結果是發生在行為人左手之後的話呢？

01:14:15 - 01:14:19
發生在左手之後的話，因為已經到故意行為時的時點了。

01:14:20 - 01:14:25
所以行為人腦中那個想殺人的想法，可不可以被評價成是故意啊？

01:14:26 - 01:14:28
就可以囉，因為在左手之後，就可以囉。

01:14:29 - 01:14:31
所以這個是左手標準說的說法。

01:14:32 - 01:14:32
所以你來看啊。

01:14:33 - 01:14:37
以左手標準來說，來看上面這幾個案例。

01:14:38 - 01:14:38
比如說你看啊。

01:14:39 - 01:14:41
案例三跟案例四，這兩個最簡單。

01:14:42 - 01:14:46
要射殺以瞄準的時候槍枝突然走火，以就被打死了。

01:14:47 - 01:14:50
這個案例，假若沒有進到左手的階段。

01:14:50 - 01:14:52
瞄準開始殺，一般認為算嘛，對不對。

01:14:53 - 01:14:55
所以有沒有殺人故意，有啊，殺人既遂啊。

01:14:56 - 01:14:59
案例四也是啊，分五次下毒，結果下到第二次人就死了。

01:15:00 - 01:15:02
那開始下毒是不是左手，是嗎？

01:15:02 - 01:15:07
所以這一切如果照左手標準說的話，一樣也是故意計歲犯，OK嗎？

01:15:07 - 01:15:08
也沒有疑問啊。

01:15:09 - 01:15:11
案例二啊，有沒有左手？

01:15:11 - 01:15:12
這個會有問題。

01:15:13 - 01:15:14
這個以後有機會再說。

01:15:14 - 01:15:16
因為那個會牽涉到不同的左手理論。

01:15:17 - 01:15:19
現在講會講到太花，不適合。

01:15:19 - 01:15:21
案例一的話，有沒有討論的空間？

01:15:21 - 01:15:22
一樣有討論的空間。

01:15:22 - 01:15:24
所以我們就先暫且不論啊。

01:15:24 - 01:15:26
我們接著來翻到後面。

01:15:27 - 01:15:28
我們來看幾個問題。

01:15:29 - 01:15:32
結果提前發生的不同理論。

01:15:34 - 01:15:35
我們講啊。

01:15:36 - 01:15:38
關於結果提前發生，會有下面幾種不同的說法。

01:15:38 - 01:15:44
左手標準說是，不管考什麼考試你一定要會的，因為左手標準說這個是傳統他們說的看法。

01:15:44 - 01:15:49
反正這個說法很簡單，有左手，那就是故意既遂。

01:15:52 - 01:15:56
因為有左手的話，那個想殺人的想法就是想法上的殺人故意。

01:15:57 - 01:16:00
而沒有左手的話，這裡就頂多

01:16:00 - 01:16:01
我舉的那個行為概念，這個過失的情說，正是左手標準說，那我要強調喔。

01:16:05 - 01:16:08
下面你看喔，括號一括號二還有括號三。

01:16:09 - 01:16:17
哎，那個括號一跟括號二忘了標粗體字，你們自己標一下，因為原本照理說標題都應該標粗體字，括號一可能我這邊忘了把它標粗體字喔。

01:16:19 - 01:16:20
這個你們就自己稍微注意一下。

01:16:21 - 01:16:25
我要講喔，括號一的計畫完成標準說。

01:16:25 - 01:16:28
括號二的主觀決定的說。

01:16:28 - 01:16:32
還有括號三的典型構成要件標準說。

01:16:33 - 01:16:36
這三說啊，其實沒有反對同說的一件事。

01:16:37 - 01:16:38
同學講什麼？

01:16:38 - 01:16:41
還沒有到著手的話，那這叫事前故意或非故意。

01:16:42 - 01:16:44
這件事下面來說沒有反對喔。

01:16:45 - 01:16:46
知道吧，這一定的吧，廢話。

01:16:47 - 01:16:52
還沒有到左手的話，這個人想殺人的想法，怎麼會是殺人故意，對不對？

01:16:52 - 01:16:57
所以如果是還沒有左手的話，最多就論過失犯，這件事大家沒有反對喔，知道嗎？這是大家的共識。

01:16:59 - 01:17:00
大家會有疑問的是什麼？

01:17:01 - 01:17:05
欸，那所以你跨到左手，就一定要論行為人故意的罪犯嗎？

01:17:06 - 01:17:07
大家反對的事情是，知道嗎？

01:17:07 - 01:17:08
大家有討論這件事啊。

01:17:09 - 01:17:13
真的你到左手階段，就要論行為人故意的罪嗎？

01:17:13 - 01:17:19
還是左手之後，要再加上其他條件，才可以論行為人故意的罪。

01:17:19 - 01:17:21
瞭解吧，他們在爭執這件事啊。

01:17:22 - 01:17:22
來。

01:17:23 - 01:17:24
下面的一跟二。

01:17:25 - 01:17:27
我都跟同學講，一跟二的標準真的非常非常像。

01:17:27 - 01:17:29
就成說案例可能都會一樣。

01:17:29 - 01:17:31
所以一跟二這兩說，我們就姑且當作它們是一樣的。

01:17:36 - 01:17:38
一跟二這兩說啊，它們的想法是這樣子。

01:17:39 - 01:17:44
它們會認為說結果提前發生案例，要論行為人故意既遂犯啊。

01:17:45 - 01:17:47
必須要行為人怎麼樣呢？

01:17:48 - 01:17:48
好。

01:17:48 - 01:17:49
必須要為人。

01:17:49 - 01:17:50
對於。

01:17:52 - 01:17:53
必須要為人啊。

01:17:53 - 01:17:55
他在主觀上覺得他該做的事都做完了。

01:17:59 - 01:17:59
剩下的。

01:18:00 - 01:18:00
聽天由命的

01:18:02 - 01:18:03
要回頭也來不及的

01:18:04 - 01:18:06
要使行為人腦中出現這樣的想法

01:18:07 - 01:18:08
這個想法出現之後啊

01:18:09 - 01:18:10
然後那個結果還提早發生

01:18:11 - 01:18:13
這樣子才能論及為人故意

01:18:13 - 01:18:14
既遂

01:18:15 - 01:18:17
什麼這種情況才能認行為人故意既遂

01:18:18 - 01:18:22
否則在其他情況的話，都只能分論未遂跟過失

01:18:24 - 01:18:26
我再講一次這個括號一括號的例子

01:18:27 - 01:18:28
他的要求超嚴格

01:18:28 - 01:18:29
那怎麼樣

01:18:30 - 01:18:37
行為人腦袋當中出現一個想法，覺得該做的事情我都做完了，剩下事會不會成，聽天由命

01:18:38 - 01:18:40
我想回頭，我也來不及了，就這樣吧

01:18:41 - 01:18:43
要有這樣的想法出現的時候

01:18:44 - 01:18:45
然後結果還提早發生

01:18:46 - 01:18:47
這樣才能任意既遂

01:18:48 - 01:18:51
反過來說,如果沒有這樣的想法出現的話

01:18:51 - 01:18:56
而又在左手之後,自成行為頂多論什麼,過失加未遂

01:18:56 - 01:18:58
我們就以前面的案例三跟案例四來講

01:18:59 - 01:18:59
來了

01:18:59 - 01:19:03
案例三，一跟二可能會有所謂左手與否的爭執

01:19:03 - 01:19:03
我們就用三跟四來講

01:19:04 - 01:19:07
三是那個瞄準的時候走火，四是要下五次毒，第二次人就死掉了

01:19:09 - 01:19:10
對

01:19:10 - 01:19:12
案例三,案例四

01:19:13 - 01:19:16
如果照剛剛我們講的不同的學說進起

01:19:17 - 01:19:19
對啦,行為人左手有沒有錯

01:19:21 - 01:19:22
可是案例三,你看哦

01:19:22 - 01:19:25
案例三的行為人,會覺得他已經回不了頭了嗎

01:19:26 - 01:19:29
不會啊，他想放棄把槍放下就好了啊，對不對？

01:19:30 - 01:19:31
案例四是不是也是？

01:19:32 - 01:19:33
在他的想法才第二次

01:19:34 - 01:19:37
那不想再殺人的話，就不要再碰槍嘛

01:19:37 - 01:19:39
頂多通報一戶，問題不是解決了，對不對？

01:19:39 - 01:19:44
所以案例三案例四，行為人根本沒有出現那樣的想法

01:19:44 - 01:19:45
所以各位啊

01:19:45 - 01:19:49
如果案例三案例四照少數說來看的話

01:19:50 - 01:19:50
怎麼論罪

01:19:52 - 01:19:54
聽訟人，照少數說怎麼論罪

01:19:54 - 01:19:56
我說分論未遂跟過失

01:19:56 - 01:19:58
為什麼又是未遂跟過失

01:19:59 - 01:20:00
過失針對哪裡

01:20:00 - 01:20:00
的部分。

01:20:01 - 01:20:03
實際上人死在哪裡。

01:20:04 - 01:20:05
而未遂針對的一個部分。

01:20:06 - 01:20:12
想像中,原本人會在,比較後面的時間死掉的那個結果,知道嗎?

01:20:13 - 01:20:14
所以案例三來說,

01:20:16 - 01:20:17
過失針對什麼?

01:20:18 - 01:20:20
人實際上被打死那個結果。

01:20:21 - 01:20:22
而未遂針對什麼呢？

01:20:22 - 01:20:25
想像中人一下才會被打死那個結果。

01:20:26 - 01:20:26
知道吧？

01:20:27 - 01:20:28
案例四更明顯。

01:20:29 - 01:20:32
實際上第二次就死掉了。

01:20:32 - 01:20:35
我說這個如果這樣少數說只能分論未遂跟過失，再講一次為什麼？

01:20:36 - 01:20:37
過失針對什麼？

01:20:38 - 01:20:39
第二次實際死亡的結果。

01:20:40 - 01:20:44
而未遂針對什麼呢？想像中第五次才會死掉的結果。

01:20:45 - 01:20:45
懂我的意思吧？

01:20:46 - 01:20:52
所以這裡這樣少數說的話，因為行為人還沒有出現那個跟法律終局牴觸的意思。

01:20:52 - 01:20:53
所以這裡只能怎麼樣？

01:20:53 - 01:20:56
事情情分論未遂跟過失。

01:20:57 - 01:21:00
未遂針對的是想像中將來要實現的結果。

01:21:00 - 01:21:04
過失針對的是實際上真正實現的結果，OK啊？

01:21:06 - 01:21:08
好，所以這個是二跟三，一跟二好，我們共解當作一樣的。

01:21:09 - 01:21:13
學者第三說叫做典型構成要件行為標準說。

01:21:14 - 01:21:17
（三）這一說同學就加減聽。

01:21:17 - 01:21:20
因為這個是臺大謝安老師所提出個人的看法。

01:21:20 - 01:21:22
有要考臺大法研所的話，這一說注意。

01:21:22 - 01:21:23
那如果沒有的話，

01:21:25 - 01:21:26
這一說我們就加減學。

01:21:26 - 01:21:29
因為這一說在國內沒有那麼多人才。

01:21:29 - 01:21:31
這個算是許老師個人的看法。

01:21:31 - 01:21:34
呃，這個東西已經在臺大法研所考過。

01:21:34 - 01:21:36
應該是許老師三年前出的。

01:21:37 - 01:21:40
但考過不見得將來不會再考。

01:21:41 - 01:21:41
真的啊？

01:21:41 - 01:21:42
因為

01:21:42 - 01:21:44
我曾經聽說過這樣的事啊。

01:21:44 - 01:21:45
就是

01:21:45 - 01:21:47
如果你們學過刑訴的話,

01:21:47 - 01:21:51
刑訴上有一個很傳統議題叫做那個，律師搜索權限的具體，你們有沒有聽過啊？

01:21:51 - 01:21:53
就是說,

01:21:54 - 01:21:55
現在大家有共識了，就是說這個

01:21:57 - 01:22:00
警察，或者拿檢察官開的拘票。

01:22:00 - 01:22:02
行為人著手執行，可是實際上沒有這個問題。

01:22:02 - 01:22:04
這個東西最早是王兆鵬老師提出的。

01:22:05 - 01:22:06
那我聽說以前是這樣啦，

01:22:06 - 01:22:09
就是以前一直有學生想，哎呀，那個王老師，

01:22:09 - 01:22:11
去年出過，今年就不會再出。

01:22:12 - 01:22:13
以前有學生這樣講。

01:22:14 - 01:22:15
後來這句話被王老師聽到，

01:22:15 - 01:22:16
王老師就不爽，

01:22:17 - 01:22:18
他就故意再出一次。

01:22:18 - 01:22:19
看他有沒有讀書。

01:22:19 - 01:22:21
聽說以前有過這麼一段，

01:22:21 - 01:22:23
所以考過不見得不會再考喔，

01:22:23 - 01:22:24
知道嗎，這個

01:22:25 - 01:22:27
有些時候老師就會拿準同學這種心態。

01:22:27 - 01:22:28
就會測驗同學，

01:22:28 - 01:22:29
這真的會。

01:22:29 - 01:22:32
當然啦，王趙鵬老師後來出家當和尚了。

01:22:33 - 01:22:33
你們知道嗎？

01:22:34 - 01:22:35
刑訴那個王老師啊，對啊。

01:22:35 - 01:22:37
後來叫陳慈法師。

01:22:37 - 01:22:38
真的他出家啦。

01:22:38 - 01:22:40
他當然不會再出給我錯。

01:22:40 - 01:22:42
可是我就說，有些時候老師也會站在同學立場想，

01:22:43 - 01:22:45
同學想投機，然後我就故意做跟同學相反的事。

01:22:45 - 01:22:47
看有沒有同學真的投機

01:22:47 - 01:22:48
真的會喔。

01:22:48 - 01:22:51
好，徐老師這篇文章，你們看喔

01:22:52 - 01:22:54
他的典型構成要件標準說

01:22:54 - 01:22:56
他的標準更細緻

01:22:56 - 01:22:59
他認為在這種結果提前發生的案例當中，

01:23:41 - 01:23:43
行為人如果要用故意既遂，

01:23:43 - 01:23:45
我們要審查兩個面向。

01:23:46 - 01:23:47
第一個是客觀面，

01:23:48 - 01:23:49
客觀面看什麼呢？

01:23:50 - 01:23:56
行為人除了著手之外，有沒有做到典型構成要件行為的階段？

01:23:57 - 01:23:59
各位你可能會想什麼叫典型構成要件行為？

01:24:00 - 01:24:01
在主觀上呢，

01:24:01 - 01:24:05
主觀上，也必須行為人對這一個提早實現的結果，

01:24:06 - 01:24:07
已經有所預認。

01:24:08 - 01:24:09
已經有未必故意，

01:24:09 - 01:24:12
才可以論行為人故意既遂的犯罪。

01:24:13 - 01:24:16
所以啊，典型構成要件行為的標準就是這樣喔！

01:24:16 - 01:24:18
我們一樣用這個案例來看前面那幾說。

01:24:18 - 01:24:21
前面那幾個，我們一樣用這一說來看前面幾個案例。

01:24:21 - 01:24:23
一樣我們看案例三跟案例四。

01:24:25 - 01:24:26
就案例三跟案例四來講，

01:24:27 - 01:24:29
我們講嘛，一個是瞄準的時候走火，

01:24:30 - 01:24:32
一個是下毒的案例。

01:24:33 - 01:24:37
來，用徐老師的說法來看，到瞄準走火的那個案例。

01:24:38 - 01:24:40
行為人可不可以論故意既遂？

01:24:42 - 01:24:42
不可以。

01:24:43 - 01:24:44
不可以，為什麼？

01:24:44 - 01:24:48
因為瞄準還不是典型構成要件行為。

01:24:49 - 01:24:50
懂嗎？

01:24:50 - 01:24:50
瞄準還不是啊。

01:24:51 - 01:24:52
所以只能怎麼樣？

01:24:52 - 01:24:54
一樣嘛，分論未遂跟過失，

01:24:54 - 01:24:55
對吧？

01:24:56 - 01:24:58
那如果用徐老師的看法，

01:24:59 - 01:25:41
來看下毒案呢,

01:25:42 - 01:25:43
可不可以論故意既遂？

01:25:44 - 01:25:45
可以喔,

01:25:45 - 01:25:45
為什麼？

01:25:46 - 01:25:49
計畫毒五次，結果第二次人就死了。

01:25:49 - 01:25:50
來兩個標準嘛,

01:25:51 - 01:25:55
第一個，下毒本身是不是殺人的典型構成要件行為？

01:25:56 - 01:25:56
是，

01:25:56 - 01:25:57
對不對？

01:25:57 - 01:25:58
再來，

01:25:58 - 01:25:59
他計劃毒五次，結果毒第二次人就死了。

01:26:01 - 01:26:03
哪個隊伍對行為有利？

01:26:03 - 01:26:04
當然是一跟二啊。

01:26:05 - 01:26:06
一跟二超嚴格欸。

01:26:07 - 01:26:08
我補充一下哈。

01:26:08 - 01:26:08
有人會問,

01:26:09 - 01:26:12
那照一跟二要怎麼樣才能夠進去?

01:26:12 - 01:26:13
我跟你說,

01:26:13 - 01:26:16
照一跟二結果提前發生的故意計稅超難。

01:26:17 - 01:26:22
照一跟二這兩說，結果提前發生要的那個故意計稅，大概是這種情形喔。

01:26:23 - 01:26:24
好，舉例。

01:26:26 - 01:26:28
行為人想毒殺被害人。

01:26:29 - 01:26:32
照行為人的認知，這個毒藥，

01:26:33 - 01:26:38
應該是在被害人吃下去之後，兩個小時，藥效才會發作，

01:26:38 - 01:26:39
人才會死掉。

01:26:40 - 01:26:41
好，行為人給被害人吃下毒藥了。

01:26:42 - 01:26:45
結果被害人吃下這個毒藥之後，被害人的體質稍微特殊一點，

01:26:46 - 01:26:48
半個小時就成了植物人，人就沒了。

01:26:50 - 01:26:53
這種案例，照一跟二才會論故意既遂。

01:26:54 - 01:26:54
為什麼？

01:26:55 - 01:27:03
因為這種案例，

01:27:03 - 01:27:12
照行為人的想法，

01:27:12 - 01:27:26
有沒有已經到既遂的階段，

01:27:26 - 01:27:41
要回頭也不太可能來不及了。

01:27:41 - 01:27:42
有嗎？

01:27:42 - 01:27:42
對不對？

01:27:42 - 01:27:47
所以如果照一跟二的說法，要這種案例才有可能論故意既遂喔。

01:27:47 - 01:27:48
所以一跟二怎麼樣？

01:27:48 - 01:27:49
最嚴格，

01:27:49 - 01:27:49
對不對？

01:27:49 - 01:27:50
對行為人最有利。

01:27:50 - 01:27:53
那許恆達老師這個說法呢，剛好在兩者之間。

01:27:54 - 01:27:56
他不像一跟二那麼嚴格。

01:27:57 - 01:28:00
他也不像左手標準說得那麼寬鬆。

01:30:10 - 01:30:15
好，我們親自看到了結果的延後發生，不明所以啊。

01:30:15 - 01:30:22
提前發生指的是這個結果在時間的時間點上，比起人想的要來得早。

01:30:22 - 01:30:24
所以反過來什麼叫延後發生呢？

01:30:25 - 01:30:26
延後發生就是說，這個犯罪結果時間的時間點呢，

01:30:29 - 01:30:32
比起為人所想的要來得晚，好吧，這個叫延後發生，比起人所想的要來得晚，

01:30:36 - 01:30:37
這個叫做延後發生。

01:30:38 - 01:30:39
延後發生，我這邊可以舉一個電影的案例。

01:30:43 - 01:30:46
十幾年前，有一部日本的經典電影叫做《告白》。

01:30:47 - 01:30:50
這部你們可以去看，有點久了，2010左右吧，那個時候的電影，這部你們可以去看。

01:30:52 - 01:30:57
因為結果延後發生，就像那一部電影當中的情節。

01:30:58 - 01:30:59
我講一下發生了什麼事啊。

01:31:00 - 01:31:01
我講改變版。

01:31:01 - 01:31:04
因為那部電影的情節更複雜，出現兩個人，我講一個基本的版本這樣。

01:31:07 - 01:31:07
好。

01:31:07 - 01:31:08
這個

01:31:09 - 01:31:09
來。

01:32:00 - 01:32:00
中獎

01:32:00 - 01:32:02
是名高中生

01:32:02 - 01:32:04
這個高中生精通電機

01:32:05 - 01:32:08
但這個高中生啊討厭他的女班導

01:32:08 - 01:32:11
所以高中生計畫對女班導復仇

01:32:12 - 01:32:14
女班導有個女兒

01:32:15 - 01:32:21
這個女兒啊,當時大概是在唸幼稚園年紀,大概目測大概三四歲左右

01:32:21 - 01:32:21
大概是這個年紀的小朋友

01:32:22 - 01:32:26
高中生為了要報復女班導，為了要殺死女班導的女兒

01:32:27 - 01:32:33
所以這高中生他在一個小兔子的玩偶當中，設置了電機的機關

01:32:34 - 01:32:39
只要摸到這個小兔子玩偶裡面的機關，摸到的人就會觸電而死

01:32:39 - 01:32:41
高中生做了一個這樣的玩偶

01:32:41 - 01:32:48
接著高中生把這一個設有電機機關的兔子玩偶呢，交給班導女兒去玩耍

01:32:49 - 01:32:50
班導的女兒看到這個兔子很高興

01:32:51 - 01:32:53
於是在那個情形下玩這個玩偶

01:32:54 - 01:32:57
玩著玩著，小朋友摸到電機機關

01:32:57 - 01:32:59
觸電了

01:32:59 - 01:33:00
小孩瞬間倒在地上

01:33:01 - 01:33:01
高中生

01:33:02 - 01:33:06
高中生看到心滿意足，想說這個小朋友終於被電死了，很高興

01:33:07 - 01:33:14
於是高中生就把這個小女孩丟到游泳池當中去溺水

01:33:15 - 01:33:18
結果後來屍體被撈起來，驗屍之後

01:33:19 - 01:33:20
這個法醫才發現

01:33:21 - 01:33:25
原來這個女童被丟入游泳池的時候根本還沒有死

01:33:26 - 01:33:28
也就是她當時只有被電暈

01:33:28 - 01:33:29
她根本還沒有死

01:33:30 - 01:33:34
這個女童的死因是被電暈之後丟入游泳池，溺水而死

01:33:35 - 01:33:36
這個電影是這樣演的

01:33:37 - 01:33:41
當時我在看這部電影的時候，我心想，這不是「結果」以後發生嗎？

01:33:42 - 01:33:43
我無法投入劇情。

01:33:43 - 01:33:44
我想說哇塞那麼難喔。

01:33:44 - 01:33:47
多數行為的結果以後發生，我那時候還想說編劇是不是有讀過刑法？

01:33:47 - 01:33:51
不然怎麼會想到這種案例，「結果」以後發生，其實這個東西在食物上真的會發生啊。

01:33:52 - 01:33:56
除了電影《告白》這個案例之外，上個月在花蓮也發生過，不知道你們記不記得那個案例

01:34:00 - 01:34:00
新聞

01:34:00 - 01:34:05
就是有個做酒店的女生被男的框出去之後

01:34:05 - 01:34:07
好像雙方有發生了一些爭吵

01:34:07 - 01:34:11
男生就拿鈍器重擊這個酒店女的頭部

01:34:11 - 01:34:13
然後把他丟到海裡面去浸濕

01:34:14 - 01:34:18
後來屍體被撈上來之後發現其實那個女生被打的時候根本沒有死

01:34:19 - 01:34:20
他只是昏過去

01:34:21 - 01:34:24
後來是因為昏過去的時候才被丟入海中

01:34:24 - 01:34:24
最後溺水而死

01:34:24 - 01:34:25
一模一樣啊

01:34:25 - 01:34:26
上個月才發生啊

01:34:26 - 01:34:28
所以這個結果的延後發生

01:34:29 - 01:34:32
原本我們一定會來講

01:34:32 - 01:34:36
原本在行為人的想像當中人應該在這個階段死

01:34:37 - 01:34:39
可是實際上在這個階段人根本沒有死

01:34:39 - 01:34:41
反而人是在什麼時候才死

01:34:41 - 01:34:43
後面浸濕的階段

01:34:45 - 01:34:48
這個浸濕的時候，我應該特別一靠起來

01:34:50 - 01:34:51
因為其實沒有在浸濕

01:34:52 - 01:34:54
懂我的意思吧，這時候還活著嘛

01:34:54 - 01:34:56
所以人在這個階段才死的

01:34:57 - 01:34:58
來，這種案例怎麼處理呢

01:34:59 - 01:35:00
我們來看

01:35:00 - 01:35:04
其實所有的錯誤的處理，無非都是兩個面向啊

01:35:04 - 01:35:06
客觀上風險有沒有實現啊

01:35:07 - 01:35:09
主觀上行為人的故意啊

01:35:09 - 01:35:12
所有的錯誤其實都不脫這兩個面向

01:35:12 - 01:35:13
所以我們來看喔

01:35:14 - 01:35:16
以訂購白的情形來講

01:35:16 - 01:35:17
各位你看

01:35:19 - 01:35:20
被害人死亡的結果

01:35:20 - 01:35:23
跟前面的電人的那個行為

01:35:24 - 01:35:25
有沒有因果關係

01:35:26 - 01:35:27
有啊，當然有啊

01:35:28 - 01:35:30
因為以內定的情況來講

01:35:30 - 01:35:34
內向女童其實原本很常在泳池玩耍

01:35:34 - 01:35:35
這個泳池不深

01:35:36 - 01:35:37
小女孩根本就不會淹死

01:35:38 - 01:35:40
如果他有意識的話，根本就不會淹死

01:35:40 - 01:35:41
那就是個兒童泳池

01:35:42 - 01:35:44
所以有沒有因果關係,有啊

01:35:44 - 01:35:46
因為如果女孩沒有被電暈的話,他被電暈在泳池

01:35:47 - 01:35:49
他就遊游上岸啊,他不會死啊,對不對

01:35:49 - 01:35:52
所以這兩者間確實有條因果關係,OK,這個沒有問題

01:35:53 - 01:35:54
再來

01:35:54 - 01:35:59
那結果的發生可不可以歸責給前面電人的那個行為呢

01:35:59 - 01:36:00
那我們

01:36:00 - 01:36:00
講呢

01:36:00 - 01:36:05
送給小女孩是一個帶有電擊機關的玩具，有沒有製造條款不確定的風險

01:36:05 - 01:36:06
有，絕對有

01:36:07 - 01:36:08
那你說風險有沒有實現

01:36:09 - 01:36:12
這算不算是一個反常的因果歷程呢，這就是重點了

01:36:14 - 01:36:15
兩種不同的看法

01:36:16 - 01:36:18
傳統上會覺得說，有，風險會實現

01:36:19 - 01:36:26
因為傳統見解會覺得，這個小女孩到底是被電死，還是被電暈之後溺斃而死？

01:36:27 - 01:36:28
傳統上說那不重要。

01:36:29 - 01:36:36
傳統上會覺得，就好像你開槍打人，那個槍到底是重傷腦、重傷小腦、重傷腦袋還是重傷脖子一樣。

01:36:36 - 01:36:38
所以那個叫不重要的偏差。

01:36:38 - 01:36:40
瞭解吧，傳統上這樣說啊。

01:36:40 - 01:36:42
所以傳統見解會覺得

01:36:43 - 01:36:45
到底人怎麼死的

01:36:45 - 01:36:47
哎呀，沒什麼差啦，沒有很重要啦

01:36:47 - 01:36:52
他就是不重要的細節性的偏差，他不會影響規則的認定

01:36:52 - 01:36:54
所以傳統的看法認為這個叫什麼呢

01:36:55 - 01:36:57
不重要，因果論，故意積欠稅款

01:36:58 - 01:37:03
這個說法，就是我們課本上所寫的第一行為關鍵說

01:37:03 - 01:37:04
OK嗎？

01:37:04 - 01:37:05
就這樣我說法啊

01:37:05 - 01:37:07
所以傳統上覺得，人怎麼死也不重要嘛

01:37:08 - 01:37:11
總之故意積欠稅就好了,所以這個叫做第一行為關鍵說

01:37:12 - 01:37:14
再來我們來看另外一說,這個是比較少數的說法

01:37:15 - 01:37:17
另外一種說法叫做

01:37:19 - 01:37:20
叫做區分處理說

01:37:20 - 01:37:23
或者叫做數罪併罰說

01:37:24 - 01:37:26
另外一種說法的立場就不一樣了

01:37:27 - 01:37:28
好

01:37:28 - 01:37:28
我們看啊

01:37:28 - 01:37:30
另外一種說法的想法是這樣

01:37:30 - 01:37:34
另外一種說法覺得，人怎麼死的，當然重要

01:37:35 - 01:37:36
為什麼呢

01:37:36 - 01:37:39
因為另外一種想法的立場是覺得說，不對啊

01:37:40 - 01:37:43
原本被害人是怎麼死，想像中

01:37:44 - 01:37:45
被電死，對不對

01:37:46 - 01:37:49
實際上呢，卻是電暈之後溺血而死

01:37:50 - 01:37:52
另外一說會覺得，這兩個根本不是同一個風險啊

01:37:53 - 01:37:54
你怎麼說風險有實現，對不對

01:37:55 - 01:37:57
人怎麼死的，差太多了吧

01:37:57 - 01:37:58
根本不重要

01:37:58 - 01:38:00
所以第二種說法

01:38:00 - 01:38:01
反而會覺得,

01:38:01 - 01:38:03
被害人的死亡結果,

01:38:03 - 01:38:07
根本不可以規則給前面的殺人行為饒恕了,

01:38:07 - 01:38:09
因為風險根本沒有實現。

01:38:09 - 01:38:11
行為人所製造的風險,

01:38:11 - 01:38:13
跟客觀上真正實現的風險，

01:38:13 - 01:38:14
根本是兩件不同的事。

01:38:15 - 01:38:16
風險沒有實現，

01:38:16 - 01:38:16
好，

01:38:16 - 01:38:18
所以風險沒有實現的話，

01:38:18 - 01:38:19
這邊只能論

01:38:19 - 01:38:20
殺人未遂。

01:38:21 - 01:38:21
到這邊可以吧

01:38:22 - 01:38:22
只能論殺人未遂。

01:38:23 - 01:38:23
好

01:38:24 - 01:38:25
那你們再想喔,

01:38:25 - 01:38:27
只論殺人未遂是不是不夠？

01:38:28 - 01:38:28
對啊不夠啊,

01:38:28 - 01:38:30
因為殺人未遂,

01:38:30 - 01:38:32
只評價到前面的殺人行為啊。

01:38:33 - 01:38:35
他是不是沒有評估到後面死亡的結果？

01:38:35 - 01:38:36
對啊,

01:38:36 - 01:38:36
所以照,

01:38:37 - 01:38:38
客觀來說的看法,

01:38:39 - 01:38:40
只論殺人未遂不夠嘛。

01:38:41 - 01:38:41
不足以評價

01:38:41 - 01:38:42
你需要怎麼樣？

01:38:43 - 01:38:44
再論後階段

01:38:44 - 01:38:46
棄屍行為的部分。

01:38:47 - 01:38:47
好

01:38:47 - 01:38:49
棄屍行為的部分會涉及兩條犯罪。

01:38:50 - 01:38:52
第一個叫做棄屍未遂。

01:38:53 - 01:38:54
為什麼是棄屍未遂？

01:38:54 - 01:38:56
欸，他丟的又不是屍體，

01:38:56 - 01:38:57
活人欸。

01:38:57 - 01:38:59
他只是自以為他在棄屍嘛,

01:38:59 - 01:38:59
對不對？

01:38:59 - 01:39:00
對啊。

01:39:00 - 01:39:01
不然幹嘛在屍體引號引起來,

01:39:02 - 01:39:03
他自以為在棄屍而已啊。

01:39:03 - 01:39:04
實際上根本不是屍體啊。

01:39:05 - 01:39:05
所以，

01:39:06 - 01:39:06
這裡的話，

01:39:07 - 01:39:07
後半段，

01:39:08 - 01:39:09
第一個叫棄屍未遂。

01:39:09 - 01:39:10
第三項。

01:39:11 - 01:39:11
再來,

01:39:11 - 01:39:13
這裡除了棄屍未遂之外,

01:39:13 - 01:39:14
還有什麼呢?

01:39:15 - 01:39:16
過失致死。

01:39:17 - 01:39:19
如果行為人稍微注意一下,

01:39:19 - 01:39:21
就會發現那個人還活著。

01:39:22 - 01:39:23
這個死亡悲劇就可以避免，對不對？

01:39:24 - 01:39:25
所以後面還有什麼呢？

01:39:25 - 01:39:26
過失致死。

01:39:26 - 01:39:27
接著我們來看喔。

01:39:29 - 01:39:29
棄屍未遂，

01:39:30 - 01:39:31
跟過失致死，

01:39:31 - 01:39:33
這兩條罪，

01:39:34 - 01:39:36
我們會用55條想像競合。

01:39:38 - 01:39:39
第一次學習的同學啊,

01:39:39 - 01:39:41
我跟你們講一下什麼叫想像競合喔。

01:39:41 - 01:39:43
想像競合的意思就是,

01:39:43 - 01:39:43
行為人,

01:39:44 - 01:39:44
一行為,

01:39:45 - 01:39:46
觸犯多數罪名,

01:39:47 - 01:39:49
而且侵害多數法益的話,

01:39:49 - 01:39:52
這時候依照刑法55條的規定要從一重處斷,

01:39:52 - 01:39:54
這個叫想像競合。

01:39:54 - 01:39:56
所以像比如說打擊錯誤,

01:39:56 - 01:39:59
我要打A沒有打中，結果把B給打死了。

01:39:59 - 01:40:00
殺人

01:40:00 - 01:40:01
的未遂跟過失致死，

01:40:01 - 01:40:03
一行為違反、侵害兩個法益，

01:40:03 - 01:40:07
這時候也是怎麼樣，想像競合，從殺人未遂來處斷。

01:40:07 - 01:40:08
這個叫想像競合。

01:40:08 - 01:40:09
這邊也是。

01:40:10 - 01:40:12
企圖未遂跟過失致死，一行為所違反，

01:40:13 - 01:40:14
觸犯兩個罪名。

01:40:15 - 01:40:17
這兩個罪名的法益不一樣。

01:40:17 - 01:40:20
屍體這個犯罪是社會善良風俗的犯罪。

01:40:21 - 01:40:23
過失致死那個是生命的犯罪，兩個法益不一樣,

01:40:23 - 01:40:25
所以這裡要想像競合。

01:40:25 - 01:40:31
然後想像競合完之後呢，再去跟前面的殺人未遂，數罪併罰。

01:40:32 - 01:40:36
數罪併罰的意思就是，各論各的，通通抓來問。

01:40:36 - 01:40:37
簡單講是這個意思。

01:40:37 - 01:40:39
好，所以這個叫做區分處理說。

01:40:40 - 01:40:41
前面論殺人未遂，

01:40:41 - 01:40:45
後面論棄屍未遂，還有過失致死，

01:40:45 - 01:40:47
最後再用結合的關係去處理。

01:40:47 - 01:40:49
所以這個叫做數罪併罰說。

01:40:50 - 01:40:51
或者叫區分處理說。

01:40:52 - 01:40:56
最後啊，第三點，還有一個說法叫做概括故意說。

01:40:57 - 01:41:00
我必須跟各位說，概括故意說是一個比較奇怪的說法。

01:41:01 - 01:41:03
概括故意說的意思啊，你看喔，

01:41:04 - 01:41:11
他說啊，行為人前、後這兩個行為，都在同一個故意之下進行的，

01:41:11 - 01:41:15
所以行為人呢，這裡，我們就論他一個殺人罪就好了，

01:41:16 - 01:41:19
因為這兩件事啊，都是在同一個故意之下進行的，

01:41:20 - 01:41:21
所以中間的偏差呢，不重要，

01:41:21 - 01:41:23
這個叫概括故意說。

01:41:23 - 01:41:25
這一說幾乎是歷史上的說法啦,

01:41:25 - 01:41:27
現在幾乎沒有人採了,為什麼呢?

01:41:27 - 01:41:36
因為現在的學者會覺得說,這種說法混淆了故意跟犯罪計畫中間的差異。

01:41:37 - 01:41:38
嚴格來講啊,你們想一想,

01:41:39 - 01:41:41
行為人在後段的起勢階段,

01:41:41 - 01:41:43
他真的有殺人故意嗎?

01:41:44 - 01:41:45
沒有啊,怎麼會?

01:41:45 - 01:41:46
瞭解嗎?

01:41:46 - 01:41:49
後面的情勢階段行為人怎麼會有殺人故意?

01:41:49 - 01:41:52
因為在後面情勢的階段,他就覺得這個是屍體欸

01:41:53 - 01:41:54
他哪來的殺人故意，對吧？

01:41:55 - 01:41:58
那為什麼這一說會覺得說行為人前後都是同一個故意？

01:41:59 - 01:42:00
我就是。

01:42:00 - 01:42:02
他混淆了故意跟犯罪計畫的定義。

01:42:03 - 01:42:09
我們最多隻能說，他前面的殺人跟後面的性侵是出於同一個犯罪計畫。

01:42:10 - 01:42:13
那個頂多叫同一個計畫，你不能說那個叫同一個刑法上的故意，

01:42:13 - 01:42:14
知道嗎？

01:42:14 - 01:42:15
所以後面這一說，

01:42:16 - 01:42:17
第三說，我建議才，

01:42:18 - 01:42:18
歷史上的說法。

01:42:19 - 01:42:20
這說很怪，好像已經沒有人支持了。

01:42:21 - 01:42:22
因為這兩個真的不是同一個故意。

01:42:23 - 01:42:25
好，所以這個是三種不同的說法。

01:42:25 - 01:42:27
來，我們講一下解題的技巧。

01:42:29 - 01:42:31
結果延後發生。

01:42:32 - 01:42:34
我們在寫題目的時候，放三階論在哪裡？

01:42:35 - 01:42:37
這題說我們放三階論在哪裡？

01:42:37 - 01:42:38
應該看得出來吧。

01:42:39 - 01:42:40
風險實現啊。

01:42:40 - 01:42:41
對，風險實現啊。

01:42:41 - 01:42:42
為什麼?

01:42:43 - 01:42:46
你看主流的兩說，第一行為關鍵說跟區分處理說，

01:42:47 - 01:42:48
這兩說為什麼會有這樣的差異？

01:42:49 - 01:42:52
因為一個覺得人怎麼死的，不重要。

01:42:53 - 01:42:54
所以殺人既遂。

01:42:54 - 01:42:56
另外一個認為人怎麼死很重要,

01:42:56 - 01:42:59
所以變殺人未遂，再論後面這一串，有沒有？

01:42:59 - 01:43:01
所以這兩說的區分關鍵在哪裡？

01:43:01 - 01:43:02
風險有沒有實現？

01:43:03 - 01:43:06
所以結果延後發生所涉及的問題核心就是什麼呢？

01:43:07 - 01:43:10
就是客觀規則當中風險有沒有實現的問題

01:43:10 - 01:43:11
所以這個東西我們放哪裡？

01:43:12 - 01:43:15
放客觀規則的風險實現

01:43:15 - 01:43:17
OK吧？放客觀規則的風險實現。

01:43:17 - 01:43:18
好。

01:43:18 - 01:43:22
那相對的,這個是我們講延後發生喔。

01:43:23 - 01:43:24
提前發生我們放哪裡?

01:43:25 - 01:43:26
放主觀。

01:43:27 - 01:43:27
不一樣。

01:43:28 - 01:43:30
提前發生的個案,我們放在主觀,為什麼?

01:43:31 - 01:43:33
因為提前發生的重點，我們在確認什麼呢？

01:43:34 - 01:43:36
行為人有沒有故意。

01:43:36 - 01:43:38
對吧，他跟那個事情故意很像嘛。

01:43:39 - 01:43:42
我們都在確認行為人有沒有故意，能不能成立故意犯。

01:43:42 - 01:43:46
所以提前發生的各說，我們反而會放在主觀去論述。

01:43:47 - 01:43:49
所以其實這個東西不難，你不用刻意去背。

01:43:49 - 01:43:53
你就想想這些學說他們在討論在爭執什麼東西。

01:43:53 - 01:43:56
提前發生多半在爭執行為人有沒有故意。

01:43:56 - 01:43:57
所以那個東西放主觀。

01:43:58 - 01:44:00
而延後發生在爭執的是

01:44:00 - 01:44:00
結果的特殊性、風險的實現，所以這個東西我們放在客觀，我講話。

01:44:05 - 01:44:10
好，所以各種的構成要件說完，我們終於講完了，終於講到這邊。

01:44:11 - 01:44:17
好，所以第三講的構成要件跟性質，我們到這邊也做一個小節，我們就可以先上到這邊了。

01:44:18 - 01:44:21
接著我們休息10分鐘，再來看違法性。

01:44:21 - 01:44:24
違法性這邊，又會有錯誤，感謝各位。

01:44:24 - 01:44:26
所以今天是錯誤的大會，因為課程內容比較複雜一點。

01:44:28 - 01:44:30
我們先休息一下，等一下我們再來看

01:44:30 - 01:44:31
違法性的部分。

01:44:33 - 01:44:37
好，我們接著回來上課了，我們來看到130頁這邊，我們來看到違法性的部分。

01:44:39 - 01:44:40
我們知道啊，違法性看的是什麼呢？

01:44:41 - 01:44:47
這個行為正當或者是不正當，違法性看的是這個東西，這個行為正當或不正當。

01:44:47 - 01:44:54
那我們第一堂課也跟各位說過，構成要件該當時候，會產生一個效果，叫做推定違法。

01:44:54 - 01:45:04
為什麼呢？因為以經驗上來講，通常一個符合刑法構成要件分則規定的行為，往往在經驗上都是不正當的，我們想殺人嘛。

01:45:05 - 01:45:11
殺人的案件這麼多，會被認為是，會被認定成正當的殺人，少之又少。

01:45:11 - 01:45:13
可能100件裡面才一兩件而已。

01:45:13 - 01:45:17
所以呢,構成要件該當之後,會產生推定違法的效果。

01:45:19 - 01:45:20
因此呢,這個叫做違法性。

01:45:21 - 01:45:23
這個叫做，這個叫做違法性的功能。

01:45:23 - 01:45:24
推定違法，判斷這個行為到底正不正當。

01:45:27 - 01:45:30
那在違法性的基礎當中，在130頁這邊。

01:45:32 - 01:45:37
在違法性的基層當中啊，我們主要做的事情就是尋找阻卻違法事由。

01:45:37 - 01:45:38
我講了。

01:45:40 - 01:45:44
違法性是被推定而存在的，被推定而具備的。

01:45:44 - 01:45:48
所以在違法性這個階層，我們要做的事情是尋找有沒有阻卻違法事由。

01:45:48 - 01:45:50
那，在阻卻違法事由的類型當中。

01:45:52 - 01:45:54
其實我們翻到後面這邊。

01:45:55 - 01:46:00
阻卻違法事由，主要的來源有兩

01:46:00 - 01:46:02
種類在132頁這裡。

01:46:02 - 01:46:11
阻卻違法事由，第一個是法律有規定的，這個叫做法規的阻卻違法事由，法律有規定的類型。

01:46:11 - 01:46:15
再來，除了這種法律有規定的類型之外，

01:46:15 - 01:46:18
阻卻違法事由也存在另外一種

01:46:18 - 01:46:21
叫做超法規的阻卻違法事由，

01:46:21 - 01:46:22
也就是什麼呢？

01:46:23 - 01:46:30
法律沒有規定，但是事理上是有承認的，這個叫做超法規阻卻違法事由。

01:46:31 - 01:46:34
所以有些法律有規定，有些法律沒有規定。

01:46:34 - 01:46:36
事理上的觀點是這樣子。

01:46:37 - 01:46:42
我們承認超法規阻卻違法事由，並不會有違反罪刑法定的問題了，為什麼？

01:46:43 - 01:46:49
因為你想哦，多一種超法規阻卻違法事由，是不是讓行為人多一條無罪的空間。

01:46:50 - 01:46:53
對不對，那無罪的空間越多，對行為人越有利嘛。

01:46:53 - 01:46:58
所以超法規阻卻違法事由這個東西，只要在理論上說得過去。

01:46:58 - 01:47:02
它就OK，它不會有所謂違反罪刑法定的問題。

01:47:02 - 01:47:06
OK，知道嗎？因為那個是多一條無罪的空間，這個對行為人是有利的喔。

01:47:07 - 01:47:10
好，所以這個是我們講到阻卻違法事由的來源。

01:47:11 - 01:47:14
那接著我們在違法性這個階層。

01:47:14 - 01:47:14
我們講完什麼叫違法性之後啊。

01:47:14 - 01:47:17
我們來看到一個非常古老的爭議問題。

01:47:17 - 01:47:19
130頁第二點，違法性有沒有程度的高低。

01:47:22 - 01:47:25
這個東西啊，不是一個非常古老的爭議。

01:47:25 - 01:47:29
可是在近年來的考試，還是會一直出現。

01:47:29 - 01:47:32
這個前幾年的考試，還是有在出啊，所以這個東西我到現在來說呢。

01:47:32 - 01:47:35
還是有必須要，還是有需要來講，因為法律的爭議是這樣啦。

01:47:38 - 01:47:42
有些東西啊，可能就是那個時代的爭議。

01:47:43 - 01:47:44
過了，就沒有人要提了。

01:47:45 - 01:47:46
有些東西是這樣。

01:47:46 - 01:47:48
好像我記得有一次我在跟林懷民聊天。

01:47:48 - 01:47:49
林懷民就跟我講說，像行政法來講的話。

01:47:50 - 01:47:56
什麼交通標示的法律定性，那個到底是一般處分還是法規命令什麼的。

01:47:57 - 01:47:59
我說這個20年前現在沒有人在討論的啦。

01:48:00 - 01:48:00
所以像我們法律理論當中，有些問題卻學會隨著時間的經過而慢慢的凋零，但是可罰的違法性這個東西，因為去年的考試還是有在考，所以雖然它是一個很舊的問題了，我們還是要來說它。

01:48:15 - 01:48:22
這裡探討的是什麼呢？來，我的標題說，違法性有沒有程度的高低。

01:48:23 - 01:48:25
這個是日本人提出來的問題了。

01:48:25 - 01:48:32
他們的想法是說，如果有的行為，他是可以的，構成要件該當性。

01:48:32 - 01:48:35
可是這個行為本身，它是一個很輕微的行為。

01:48:36 - 01:48:39
他所造成的法益侵害的結果，也不嚴重。

01:48:40 - 01:48:43
那這個行為，真的要讓他成立犯罪嗎？

01:48:44 - 01:48:51
還是我們說呢，他會欠缺可罰的違法性，進而無罪呢？所以我們先搞清楚這個問題啊。

01:48:53 - 01:48:57
所謂可罰的違法性，要解決的是什麼呢？

01:48:59 - 01:49:05
這個行為，他的法益侵害數量非常的少。

01:49:05 - 01:49:11
他要解決的是這個問題，知道嗎？這個行為他所造成的法益侵害所量非常的少。

01:49:11 - 01:49:13
比如說。

01:49:13 - 01:49:16
偷吃別人一顆，一顆是什麼東西啊？

01:49:17 - 01:49:20
偷吃別人一顆，荔枝之類的。

01:49:20 - 01:49:21
偷吃別人一顆荔枝。

01:49:22 - 01:49:25
人不要說，如果你說偷吃別人一顆幹貝。

01:49:25 - 01:49:27
這恐怕不行，那幹貝一顆還蠻貴的。

01:49:27 - 01:49:29
偷吃別人一顆荔枝。

01:49:30 - 01:49:33
或者是偷用別人一張白紙。

01:49:33 - 01:49:38
這種情形，這個行為本身很輕，法益侵害的結果也很輕微。

01:49:38 - 01:49:42
這樣的情況，可不可以認為這個行為不具有違法性呢？

01:49:42 - 01:49:48
第一個括號一，日本學說跟我們的食物，有所謂可罰的違法性。

01:49:49 - 01:49:50
你看喔。

01:49:50 - 01:49:54
學者認為說，被害的法益是輕微的。

01:49:55 - 01:50:00
而且呢，行為與社會相當的程度。

01:50:00 - 01:50:02
隱性輕微的。

01:50:03 - 01:50:05
如果這兩個東西都輕微的話，那我們就說呢，這個行為欠缺可罰的違法性，會成立犯罪。

01:50:11 - 01:50:15
這是日本學說的看法，欠缺可罰的違法性不成立犯罪。

01:50:15 - 01:50:21
所以日本學說他們傾向會認為說把這一種情節顯然輕微的情形。

01:50:21 - 01:50:23
兩個都要輕。

01:50:24 - 01:50:27
行為輕，法益侵害的結果也輕。

01:50:27 - 01:50:30
在這兩個都輕微的

01:50:30 - 01:50:35
情況呢，日本學說傾向認為這個行為不具有違法性。

01:50:35 - 01:50:39
他們的名字叫做欠缺可罰的違法性。

01:50:39 - 01:50:45
所以也就是說，日本人覺得違法性會有程度的問題。

01:50:46 - 01:50:49
違法性不是純粹的有跟沒有啊，違法性會有程度的問題。

01:50:50 - 01:50:55
違法的程度如果太低的話，那個違法性會把它否定掉。

01:50:55 - 01:50:57
這個理由叫做可罰的違法性。

01:50:58 - 01:50:59
那我強調。

01:51:00 - 01:51:04
可罰的違法性必須兩個都輕。

01:51:05 - 01:51:06
欠缺可罰性有兩個東西。

01:51:07 - 01:51:08
行為本身是輕微的。

01:51:09 - 01:51:12
還有怎麼樣,法益侵害的結果也是輕微的。

01:51:13 - 01:51:15
這兩個都輕微的話。

01:51:16 - 01:51:19
才能說這個行為欠缺可罰的違法性。

01:51:19 - 01:51:20
兩個都要輕，知道嗎?

01:51:21 - 01:51:21
所以像我說的。

01:51:22 - 01:51:23
你偷同學一張筆記紙。

01:51:24 - 01:51:26
你偷吃同學一顆荔枝。

01:51:27 - 01:51:30
這樣的情況確實可以認為欠缺可罰的違法性。

01:51:30 - 01:51:31
可是啊。

01:51:32 - 01:51:33
如果是這樣啊。

01:51:33 - 01:51:34
你跟你同學說。

01:51:35 - 01:51:36
那個筆記紙給我一張，好不好？

01:51:37 - 01:51:38
你同學說不要。

01:51:39 - 01:51:43
這個時候，你亮出美工刀，眼神兇狠地問你同學。

01:51:43 - 01:51:46
真的不要嗎？我再問你一次，要還是不要？

01:51:46 - 01:51:48
你同學嚇死了，趕快給你一張信紙啊。

01:51:49 - 01:51:50
趕快給你一張白紙。

01:51:50 - 01:51:53
這種情形，你可以說欠缺可罰的違法性嗎？

01:51:53 - 01:51:57
不行啊,這個拿刀子去威嚇人家,那個叫加重強盜。

01:51:57 - 01:51:59
那個行為一點都不輕,哇。

01:51:59 - 01:52:00
所以兩個都要輕判。

01:52:00 - 01:52:00
才可以啊。

01:52:01 - 01:52:02
那實務見解的部分啊,

01:52:02 - 01:52:03
下面的註二,

01:52:03 - 01:52:06
74臺上4225這個判例。

01:52:08 - 01:52:09
我們講到判例,

01:52:09 - 01:52:10
跟同學講一下,

01:52:11 - 01:52:12
其實判例這個東西在六年前,

01:52:13 - 01:52:15
2019大法定新制施行之後，

01:52:15 - 01:52:17
判例就沒有了。

01:52:17 - 01:52:18
應該知道吧？

01:52:18 - 01:52:19
這同學應該聽過，

01:52:19 - 01:52:21
判例其實六年前就走入歷史了。

01:52:21 - 01:52:22
現在沒有什麼判例啦,

01:52:22 - 01:52:25
現在就是它的效力位階就是一般的判決而已。

01:52:26 - 01:52:26
不過,

01:52:26 - 01:52:27
我跟各位說,

01:52:28 - 01:52:30
雖然判例制度被終結了,

01:52:31 - 01:52:33
可是原本被選為判例的裁判，

01:52:34 - 01:52:36
還是有一定的參考價值。

01:52:37 - 01:52:37
問題是這樣啦，

01:52:38 - 01:52:41
因為其實很多判例所闡述的法律概念是對的，

01:52:42 - 01:52:44
它只是就最基本的概念而已。

01:52:44 - 01:52:46
並不會因為說判例制度不見,

01:52:47 - 01:52:49
食物就非得採一個跟他相反的立場。

01:52:49 - 01:52:50
不會,

01:52:50 - 01:52:50
知道嗎?

01:52:50 - 01:52:51
因為有些判例是對的啊,

01:52:51 - 01:52:52
判例是對的,

01:52:52 - 01:52:55
難道他不見得食物要採一個相反錯誤的立場嗎?

01:52:55 - 01:52:55
不可能嘛。

01:52:56 - 01:52:57
所以有些判例,

01:52:57 - 01:52:59
雖然它的價值可能稍微會低一點,

01:53:00 - 01:53:02
可是它依然是有代表性的食物見解,

01:53:02 - 01:53:03
像這一則就是。

01:53:05 - 01:53:06
這一則判例啊,

01:53:06 - 01:53:08
你們大概瀏覽一下它的文字,

01:53:09 - 01:53:10
它所講的內容,

01:53:11 - 01:53:13
是不是就是我們剛所說的可罰違法性？

01:53:14 - 01:53:14
對啊，

01:53:14 - 01:53:15
沒有錯啊，

01:53:15 - 01:53:15
就是嘛，

01:53:15 - 01:53:15
對不對？

01:53:16 - 01:53:17
可是你看喔,

01:53:17 - 01:53:19
這個判例的文字,

01:53:20 - 01:53:23
有沒有出現可罰違法性這幾個字？

01:53:24 - 01:53:24
沒有欸,

01:53:24 - 01:53:26
他反而講什麼？

01:53:26 - 01:53:28
實質違法性,

01:53:28 - 01:53:29
很奇怪,

01:53:29 - 01:53:29
對不對？

01:53:30 - 01:53:31
他沒有寫可罰違法性喔,

01:53:31 - 01:53:35
他反而寫的是實質的違法性這幾個字。

01:53:35 - 01:53:36
所以我跟各位說,

01:53:37 - 01:53:39
這就是學者罵他的地方。

01:53:40 - 01:53:42
以前我大學看林老師的教科書啊,

01:53:42 - 01:53:46
林老師教科書花了好幾頁在罵這個判例跟日本學說的看法。

01:53:46 - 01:53:46
為什麼?

01:53:47 - 01:53:49
因為學者認為說,

01:53:50 - 01:53:52
這是一個誤解。

01:53:52 - 01:53:55
判例的用語叫做實質違憲性。

01:53:55 - 01:53:56
各位,

01:53:56 - 01:54:00
實質違憲性的欠缺意思是指這個行為的

01:54:00 - 01:54:03
實質不違反一般的社會通念。

01:54:04 - 01:54:05
是指行為的本身喔。

01:54:06 - 01:54:07
而可罰的違法性是指什麼？

01:54:08 - 01:54:10
法益侵害的總量很少。

01:54:11 - 01:54:12
不一樣的意思，知道嗎？

01:54:12 - 01:54:14
一個是說這個行為本身是OK的。

01:54:15 - 01:54:20
另外一個是說，這個行為不太OK，可是因為總量很小啊，就算了，不想追究它。

01:54:20 - 01:54:21
那個想法是不一樣的喔。

01:54:22 - 01:54:25
所以我們講，可罰違法性理論上處理哪一塊？

01:54:25 - 01:54:27
行為本身不太OK。

01:54:27 - 01:54:31
但是法益侵害的總量很少，很少就算了，刑法不用去管它。

01:54:32 - 01:54:33
它處理的是這個東西，知道嗎？

01:54:33 - 01:54:37
可惜這個判例卻掛羊頭賣狗肉，講了實質違法性的概念。

01:54:37 - 01:54:41
我再講一次，實質違法性的意思是，這個行為本身就還好而已。

01:54:42 - 01:54:44
這個行為本身我們社會就可以容忍。

01:54:45 - 01:54:45
不是吧。

01:54:46 - 01:54:47
他講錯了吧。

01:54:47 - 01:54:51
所以判例的用語問題就在這邊。

01:54:51 - 01:54:54
他名目上講了實質違法性，

01:54:54 - 01:54:57
可是他實際上在講的卻是什麼呢？

01:54:57 - 01:54:58
可罰的違法性。

01:54:59 - 01:55:00
掛羊頭賣狗肉，懂嗎？

01:55:01 - 01:55:02
所以這個判例的問題在這邊。

01:55:02 - 01:55:06
所以其實如果你真的要說啦，你說實務上到底有沒有採可罰違法性理論？

01:55:07 - 01:55:08
我們只能說有接近的。

01:55:09 - 01:55:11
但是沒有真的精確使用名詞的，

01:55:11 - 01:55:12
只能這麼說。

01:55:12 - 01:55:14
相對的，括號二。

01:55:15 - 01:55:17
這個德國的學說啊，

01:55:18 - 01:55:21
多半不認為有可罰的違法性這個東西。

01:55:22 - 01:55:24
那個是日本人發明的理論啊。

01:55:25 - 01:55:27
留德的老師幾乎沒有承認這個理論。

01:55:28 - 01:55:30
這裡會牽涉到一個問題啊，什麼叫違法？

01:55:31 - 01:55:36
多數留德的老師會說，違法它就是有跟沒有的問題。

01:55:37 - 01:55:39
你們想想在中文的世界當中，

01:55:40 - 01:55:44
有一天你紅燈右轉，被警察攔下來了。

01:55:44 - 01:55:46
警察會說，同學，

01:55:46 - 01:55:48
你的行為有點違規喔。

01:55:48 - 01:55:49
會這樣講嗎？

01:55:49 - 01:55:50
有點違規。

01:55:51 - 01:55:52
超怪，對吧？

01:55:52 - 01:55:53
有就有，沒有就沒有嘛。

01:55:53 - 01:55:55
怎麼會有一點違法這種概念？

01:55:55 - 01:55:56
不會啊。

01:55:56 - 01:55:59
所以學者會跟你說，違法。

01:56:00 - 01:56:01
不法是兩個不同的概念。

01:56:02 - 01:56:04
違法就是這個行為有沒有抵觸法規範嘛。

01:56:04 - 01:56:06
有就有，沒有就沒有嘛。

01:56:06 - 01:56:08
那有什麼有一點點違法，沒有這種東西。

01:56:08 - 01:56:11
所以學者會認為違法與否。

01:56:12 - 01:56:13
它就是有跟沒有的問題。

01:56:14 - 01:56:16
只有不法。

01:56:16 - 01:56:17
才有程度的高低。

01:56:18 - 01:56:19
我們講，

01:56:19 - 01:56:21
最低的叫民事不法。

01:56:21 - 01:56:23
再來叫行政不法。

01:56:23 - 01:56:24
最高叫刑事不法。

01:56:25 - 01:56:27
不法才有高低的問題啦。

01:56:27 - 01:56:28
違法沒有啦。

01:56:29 - 01:56:30
違法有就有，沒有就沒有。

01:56:30 - 01:56:31
就沒有。

01:56:31 - 01:56:33
所以學者認為說這個可罰的違法性理論。

01:56:34 - 01:56:37
他混淆了違法跟不法的概念。

01:56:38 - 01:56:40
所以像林山田老師這種傳統流德的學者。

01:56:40 - 01:56:42
他們對這個理論很不屑。

01:56:42 - 01:56:43
他們覺得日本人搞錯了。

01:56:44 - 01:56:45
違法跟不法怎麼會是樣的東西？

01:56:46 - 01:56:47
他們把違法跟不法搞混了。

01:56:48 - 01:56:50
違法就違法，沒有什麼一點點違法，沒有這種東西。

01:56:51 - 01:56:53
所以像林山老師這種傳統流派的學者。

01:56:53 - 01:56:57
他們會覺得這種法益侵害量很低的行為。

01:56:58 - 01:56:59
那個無關犯罪的成立啊。

01:57:00 - 01:57:02
那個是行政的問題啊。

01:57:02 - 01:57:04
因為法益侵害量很低的話。

01:57:04 - 01:57:05
對不對？

01:57:06 - 01:57:09
個案給他一顆罰金，一服社會勞動。

01:57:10 - 01:57:11
要嘛程序上給他緩起訴。

01:57:12 - 01:57:14
這不是犯罪成立的問題啊。

01:57:14 - 01:57:17
所以傳統老師覺得說這個理論有問題。

01:57:17 - 01:57:20
所以在這個所謂可罰的違法性。

01:57:20 - 01:57:22
其實爭議點在什麼？

01:57:22 - 01:57:24
違法有沒有程度的高低？

01:57:24 - 01:57:25
爭議點在這邊，知道嗎？

01:57:26 - 01:57:27
肯定的學者覺得說對，違法的程度有高低。

01:57:28 - 01:57:29
而否定的學者覺得...

01:57:30 - 01:57:31
違法沒有高低，違法就是有跟沒有。

01:57:32 - 01:57:33
有程度高低的叫做不法。

01:57:34 - 01:57:36
而這個理論混淆了違法跟不法的差異。

01:57:37 - 01:57:38
他們的爭執差別在這邊。

01:57:39 - 01:57:41
好，我們接著翻過來看，132頁。

01:57:44 - 01:57:45
132頁這邊,這個經典試題。

01:57:45 - 01:57:49
多年前東吳轉學考,大二轉學考的考題。

01:57:50 - 01:57:51
真題當中啊。

01:57:52 - 01:57:53
你看啊。

01:57:55 - 01:57:59
甲在未經同意的情況之下,從路邊機車行的水龍頭。

01:58:00 - 01:58:04
取水,並且拿著一小搓洗衣粉用來洗手。

01:58:05 - 01:58:08
他偷了人家的水跟洗衣粉。

01:58:09 - 01:58:12
所以在考題當中,我們要怎麼判別這個考點?

01:58:13 - 01:58:16
當你看到有行為人,這個通常會展現在財產犯罪上面。

01:58:16 - 01:58:21
當有行為人做的很低度的財產犯罪,竊盜侵佔那一種啊,低度的財產犯罪。

01:58:22 - 01:58:26
而且他所竊盜或侵佔的東西，根本是毫無價值的東西。

01:58:27 - 01:58:29
像以前國考有考過啊。

01:58:29 - 01:58:31
偷摘人家一顆龍眼。

01:58:32 - 01:58:33
對，偷摘人家一顆龍眼。

01:58:33 - 01:58:34
你們這樣想啊。

01:58:35 - 01:58:38
你要去水果店買龍眼，你們會跟老闆說我要買一顆龍眼，一顆就好喔，你不要給我一串。

01:58:40 - 01:58:42
老闆傻眼了吧，一顆龍眼我請你吃好不好啊。

01:58:43 - 01:58:44
一顆龍眼怎麼算啊，不可能嘛。

01:58:45 - 01:58:47
所以一顆龍眼不值錢啊。

01:58:47 - 01:58:48
這裡的話也是啊。

01:58:49 - 01:58:51
偷用人家一小搓肥皂。

01:58:52 - 01:58:53
請問是什麼肥皂嗎？

01:58:53 - 01:58:55
洗衣粉，一小搓洗衣粉。

01:58:56 - 01:58:59
洗衣粉一小搓，就是用來洗手那個量，通常洗的。

01:59:01 - 01:59:03
其實我沒有買過洗衣粉，我都洗衣服。

01:59:03 - 01:59:04
那應該不值錢吧。

01:59:05 - 01:59:07
一大盒洗衣粉應該也要幾百塊吧，那應該不值錢吧。

01:59:08 - 01:59:09
還有一點點水。

01:59:10 - 01:59:11
用來洗手那個水，一點點水。

01:59:13 - 01:59:14
那一點點水多少錢？

01:59:15 - 01:59:16
可能連五塊錢都不到。

01:59:17 - 01:59:19
可以想像，對吧，應該連一塊錢都不到吧。

01:59:20 - 01:59:21
對啊，像

01:59:21 - 01:59:22
我想一下，我們

01:59:22 - 01:59:24
水費是不是兩個月繳一次，是吧？

01:59:24 - 01:59:26
對啊，兩個月繳一次，那我

01:59:26 - 01:59:29
自己住啊，我水費兩個月才200多塊啊。

01:59:29 - 01:59:31
洗澡啊，洗手沖馬桶這些啊。

01:59:31 - 01:59:33
所以你說洗一次澡水費多少錢？

01:59:34 - 01:59:35
超低的喔。

01:59:36 - 01:59:37
所以

01:59:37 - 01:59:37
我們

01:59:37 - 01:59:38
就說啊。

01:59:38 - 01:59:41
偷別人的水跟一小撮洗衣粉，真的沒有什麼錢啊。

01:59:42 - 01:59:44
所以在這樣的情況之下，可以說什麼呢？

01:59:45 - 01:59:47
欠缺可罰的違法性。

01:59:48 - 01:59:49
如果你採取肯定的看法的話。

01:59:49 - 01:59:51
這裡就會認為欠缺可罰的違法性，但相對的否定意見呢。

01:59:53 - 01:59:55
會說他犯罪還是成立啊。

01:59:55 - 01:59:59
那頂多是情法這個問題，或者程序上要不要緩起訴的問題，這反映給你。

02:00:00 - 02:00:01
是這樣子。

02:00:02 - 02:00:02
好,

02:00:03 - 02:00:07
接下來,下面的第三點,阻卻違法事由的來源,這個我們就講過了。

02:00:08 - 02:00:10
接下來第三點,違法性的判斷,

02:00:11 - 02:00:13
主觀跟客觀要合致。

02:00:14 - 02:00:16
這個東西，主跟客要合致。

02:00:23 - 02:00:27
這個第四點，其實一樣在複習的是我們第一堂課所講的概念。

02:00:28 - 02:00:29
又是打勾打叉。

02:00:29 - 02:00:30
所以我第一堂課就說嘛。

02:00:31 - 02:00:33
第一堂課我們畫三階論畫格子打勾打叉。

02:00:33 - 02:00:36
那一套如果同學能很熟，都可以倒背如流的話，

02:00:37 - 02:00:39
行走一般的問題，你都可以輕鬆地去面對。

02:00:40 - 02:00:41
我們在講違法性的時候還記不記得，

02:00:41 - 02:00:43
我們畫了三個格子，

02:00:43 - 02:00:46
如果印象模糊的話沒關係，我們拿出第一堂課的筆記來看一下。

02:00:47 - 02:00:47
我們講,

02:00:49 - 02:00:52
三階論當中，違法性的階層，三個格子。

02:00:53 - 02:00:55
第一格叫做前提事實。

02:00:56 - 02:00:58
第二格叫做手段適當。

02:00:59 - 02:01:02
第三格是主觀，叫做認知。

02:01:03 - 02:01:06
我們當時說了，要阻卻違法必須怎麼樣啊？

02:01:06 - 02:01:08
三格都打勾。

02:01:08 - 02:01:14
也就是要有前提事實，手段也要適當，而且行為人主觀上也要有對應的認知，

02:01:14 - 02:01:17
三格都打勾的情況，才可以阻卻違法。

02:01:18 - 02:01:20
反之有任何一個沒有打勾的話呢？

02:01:20 - 02:01:22
那就不能阻卻違法,

02:01:23 - 02:01:23
這個我們講過嘛。

02:01:24 - 02:01:25
好,所以你來看到下面這邊,

02:01:25 - 02:01:31
這裡我說啊,阻卻違法事由的主跟客,全部都要對應,

02:01:31 - 02:01:32
所以你來看我這邊寫的喔,

02:01:32 - 02:01:34
第一個，客觀欠缺而主觀具備，

02:01:35 - 02:01:38
那個叫容許構成要件錯誤，我們格子畫過。

02:01:38 - 02:01:39
誤想系列啊。

02:01:41 - 02:01:42
假設我晚上回家的時候，

02:01:43 - 02:01:46
有個男的，感覺他在尾隨我，

02:01:46 - 02:01:48
靠我靠得越來越近。

02:01:48 - 02:01:51
我覺得這個男的對我猥褻，我踹他一腳，把他踢倒受傷。

02:01:52 - 02:01:54
結果後來發現那個男的根本沒有要猥褻我，

02:01:54 - 02:01:57
那個男的想提醒我，我後揹包的拉鍊沒有拉。

02:01:57 - 02:01:58
我轉頭一看，還真的。

02:01:59 - 02:02:00
我拉鍊沒有拉。

02:02:00 - 02:02:02
原來我把好人當壞人了。

02:02:02 - 02:02:03
我想問問。

02:02:04 - 02:02:06
主觀上沒有現在的非法侵害。

02:02:06 - 02:02:10
可是我主觀上卻以為這個侵害是存在的。

02:02:10 - 02:02:12
所以這個叫做誤想侵略。

02:02:12 - 02:02:14
容許構成要件錯誤。

02:02:14 - 02:02:16
這個講詳細的，我們等下會說。

02:02:16 - 02:02:17
再來反過來呢。

02:02:18 - 02:02:23
那如果是客觀具備而主觀欠缺呢？

02:02:25 - 02:02:27
你基於報復的意思。

02:02:28 - 02:02:30
砸了你仇人家的窗戶。

02:02:31 - 02:02:34
結果這時候你正往死裡幫他出來。

02:02:34 - 02:02:37
原來你仇人家當時往死裡漏氣。

02:02:38 - 02:02:41
你把他們家的窗戶砸了,反而救了他們全家一命。

02:02:42 - 02:02:44
這個叫什麼呢？

02:02:45 - 02:02:45
偶然避難。

02:02:45 - 02:02:49
客觀上你仇人家的生命確實陷入迫切的危險,沒有錯。

02:02:50 - 02:02:54
而你把人家窗戶砸破,確實是避難的手段,適合的避難手段,也沒有錯。

02:02:55 - 02:02:59
可是你主觀上對他們一家陷入生命的危險。

02:02:59 - 02:03:00
根本一無所知。

02:03:01 - 02:03:04
所以就請其必然狀況就缺乏需要來說。

02:03:04 - 02:03:06
客觀上要件是欠缺的。

02:03:07 - 02:03:10
客觀上要件是具備的，可是你主觀上是沒有認知。

02:03:10 - 02:03:11
這個叫做偶然侵佔。

02:03:12 - 02:03:15
反面容許構成要件錯誤。

02:03:15 - 02:03:16
這個叫反面容許構成要件錯誤。

02:03:16 - 02:03:18
效果的話呢,我們等下也會來說啊。

02:03:19 - 02:03:23
來,下面這個進行問題,對應原理在違法性的適用。

02:03:25 - 02:03:26
這個是法理所考點。

02:03:27 - 02:03:29
一般的三等國考應該比較不會考。

02:03:30 - 02:03:31
這個是法理所考點。

02:03:32 - 02:03:33
我們先來看一下。

02:03:33 - 02:03:36
前幾年蔡老師真的把它出在北大刑法組。

02:03:36 - 02:03:37
真的有啊，這是法理所考點。

02:03:38 - 02:03:41
所以三等的同學，一般的三等，沒有考試力的話。

02:03:41 - 02:03:43
這貫就加減聽，太難就算了，沒關係。

02:03:46 - 02:03:46
我們看哦。

02:03:47 - 02:03:48
剛剛我們在講。

02:03:49 - 02:03:51
因果歷程偏離，構成要件錯誤的時候，當時我們就說了。

02:03:54 - 02:03:55
客跟主。

02:03:55 - 02:03:57
兩個單純的打工還不夠。

02:03:58 - 02:03:59
還要兩者有對應。

02:04:00 - 02:04:01
模糊萬就是嘛。

02:04:01 - 02:04:02
模糊萬的話

02:04:02 - 02:04:04
客觀上那個小朋友死掉了

02:04:05 - 02:04:06
主觀上這個人有殺人故意

02:04:07 - 02:04:08
可是卻沒有殺人既遂

02:04:08 - 02:04:08
為什麼

02:04:09 - 02:04:10
因為強者沒有故意啊

02:04:11 - 02:04:14
行為人認識到的風險跟實際上的風險不一樣嘛

02:04:14 - 02:04:14
對不對

02:04:14 - 02:04:16
所以構成要件的部分會有這個對應的問題

02:04:17 - 02:04:18
那違法性會不會有

02:04:19 - 02:04:20
違法性也會有類似的問題啊

02:04:21 - 02:04:23
違法性這邊，問題是這樣

02:04:23 - 02:04:27
如果行為人客觀上實現了A組織違法是有

02:04:28 - 02:04:33
可是行為人主觀上是出於B組織違法是有意思

02:04:33 - 02:04:35
兩者沒有對應還可不可以組織違法

02:04:35 - 02:04:36
你們看到下面這個案例

02:05:45 - 02:05:45
你們看喔

02:05:45 - 02:05:46
這個案例

02:05:46 - 02:05:49
A從國外搶先帶回臺灣還沒有開賣的新型手機

02:05:50 - 02:05:52
才用了幾天就在圖書館被偷走

02:05:53 - 02:05:56
數天之後呢，A在圖書館門口竟然見到B拿著同樣的手機

02:05:57 - 02:05:59
誤以為就是自己被偷的手機

02:05:59 - 02:05:59
隨即上去攔住

02:06:00 - 02:06:01
至少得進行判斷嘛，沒有問題嗎？

02:06:01 - 02:06:02
各位，突然上去攔住了這個。

02:06:03 - 02:06:05
可是他主觀上這個自己在做什麼？

02:06:06 - 02:06:07
自助行為。

02:06:07 - 02:06:09
民法151。

02:06:09 - 02:06:10
他覺得主觀上在做自助行為。

02:06:11 - 02:06:12
他覺得他自己在做自助行為。

02:06:13 - 02:06:14
所以這裡涉及到的問題就是這樣嘛。

02:06:15 - 02:06:17
客觀上實現的是A組卻法性的要件。

02:06:18 - 02:06:22
可是行為人主觀上卻是出於B，這個卻違法事由的意思。

02:06:23 - 02:06:25
所以這種A加B可不可以阻卻違法？

02:06:26 - 02:06:27
以量格來講。

02:06:28 - 02:06:29
是不是三個都擋功？

02:06:29 - 02:06:31
對,三個都擋功沒有錯。

02:06:31 - 02:06:33
可是客觀上是A的功。

02:06:33 - 02:06:34
主觀上是B的功。

02:06:34 - 02:06:35
沒有對應的,有沒有?

02:06:35 - 02:06:36
這樣還可以主張違法?

02:06:37 - 02:06:39
德國學說法，有兩種不同的說法。

02:06:39 - 02:06:41
結論上來說啦。

02:06:41 - 02:06:43
連接理論就覺得說好。

02:06:44 - 02:06:45
要對應。

02:06:45 - 02:06:47
要有對應才可以主張違法。

02:06:47 - 02:06:50
那累加理論就說不用，不需要對應。

02:06:51 - 02:06:54
更深的理由，其實蔡老師在文章也沒有特別去談，可能篇幅有限。

02:06:55 - 02:06:57
蔡老師身上有這兩種不同的理論。

02:06:58 - 02:07:00
而這兩種不同的理論呢。

02:07:00 - 02:07:02
國內沒有深入探討。

02:07:02 - 02:07:06
蔡老師在文章裡面，他採的是累加理論。

02:07:07 - 02:07:11
所以結論上來講，阻卻違法事由這邊，沒有對應的問題。

02:07:12 - 02:07:16
A的阻卻違法事由客觀加B的阻卻違法事由的主觀，OK沒問題。

02:07:17 - 02:07:18
可以阻卻違法。

02:07:19 - 02:07:20
構成要件才要對應。

02:07:20 - 02:07:21
違法性不用對應。

02:07:22 - 02:07:23
為什麼?

02:07:23 - 02:07:23
為什麼違法性不用對應?

02:07:24 - 02:07:26
蔡老師提到一個觀唸啊,你來看到。

02:07:28 - 02:07:29
括號二這邊。

02:07:29 - 02:07:30
括號小二。

02:07:31 - 02:07:35
這裡說啊，無主張違法事由，這部分。

02:07:35 - 02:07:37
我們會有認知歧異的空間。

02:07:38 - 02:07:39
所以就此來說呢。

02:07:39 - 02:07:43
不需要把對應的東西納入違法性的審查。

02:07:43 - 02:07:44
這句話什麼意思？

02:07:45 - 02:07:46
我們來說說啊。

02:07:46 - 02:07:48
在違法性這個階層。

02:07:49 - 02:07:51
一般在沒有阻卻違法事由的情況。

02:07:52 - 02:07:56
行為人只要犯的認知到說他的行為不正當。

02:07:56 - 02:07:57
這就夠了。

02:07:58 - 02:08:00
我們不用讓行為人去。

02:08:00 - 02:08:04
卻必須要認知到沒有哪一種主權違法是有。

02:08:04 - 02:08:06
因為沒有就是沒有。

02:08:06 - 02:08:07
你要行為人認知到沒有哪一種。

02:08:07 - 02:08:09
那個在邏輯上沒有意義。

02:08:10 - 02:08:13
我舉個例子，以前在一本哲學書上面看到的。

02:08:14 - 02:08:16
好像18、19世紀的時候吧。

02:08:16 - 02:08:18
當時有個哲學家，

02:08:19 - 02:08:22
他去一間咖啡館，點了一杯黑咖啡。

02:08:22 - 02:08:24
他跟咖啡店的服務生說：

02:08:24 - 02:08:26
「我要一杯黑咖啡，

02:08:27 - 02:08:28
不要加鮮奶油。」

02:08:29 - 02:08:31
那個服務生就說：「一杯黑咖啡不要鮮奶油。」

02:08:32 - 02:08:33
服務生聽得懂啊，就說：「好，沒問題。」

02:08:34 - 02:08:38
結果到了廚房之後，服務生又匆匆忙忙跑來，跟這個哲學家說：「先生不好意思，

02:08:38 - 02:08:41
我們的鮮奶油沒了，我們只剩熱牛奶。

02:08:41 - 02:08:44
那黑咖啡不要熱牛奶，您可以接受嗎？

02:08:44 - 02:08:46
哲學家說可以，可以接受。

02:08:47 - 02:08:48
你們覺得服務生問這個幹嘛？

02:08:49 - 02:08:50
應該沒有意義，對吧？

02:08:50 - 02:08:54
其實這個哲學家要的就是一杯純的黑咖啡，是什麼都不要加嘛。

02:08:54 - 02:08:58
黑咖啡不加熱牛奶跟黑咖啡不加鮮奶油，那個意思還不是一樣？

02:08:59 - 02:09:00
就是不要加東西啊。

02:09:01 - 02:09:03
所以學者就會講說，就是類似的概念。

02:09:04 - 02:09:05
沒有就是沒有。

02:09:05 - 02:09:09
我們不可能要求行為人認知到什麼樣的『沒有』。

02:09:10 - 02:09:11
這是違反禁止錯誤的本質。

02:09:12 - 02:09:14
所以從這個禁止錯誤的本質來講的話，

02:09:14 - 02:09:17
對應原理在違法性是不適用的。

02:09:18 - 02:09:20
因為它是反面判斷嘛，要認知到沒有嘛。

02:09:20 - 02:09:22
你不可能認知到什麼樣的沒有，不可能嘛。

02:09:22 - 02:09:25
所以由此來說呢，主觀違法是有這裡

02:09:26 - 02:09:28
不需要有對應的問題，不需要。

02:09:28 - 02:09:33
A的主觀違法事由的事實，加上B的主觀違法事由的認知。

02:09:33 - 02:09:35
OK喔，可能觸法喔。

02:09:36 - 02:09:40
好，所以這個是多年前，蔡老師的這一篇文章，我們大概就講到這邊。

02:09:40 - 02:09:42
這個法音所考過了。

02:09:42 - 02:09:46
這個國考要考的話，我覺得機率稍微低，要考頂多考在私律。

02:09:47 - 02:09:49
應該不會考在這個一般的山等。

02:09:49 - 02:09:51
所以我說這個東西一般的國考考生呢,就加減看。

02:09:52 - 02:09:54
好,接下來134頁,

02:09:54 - 02:09:55
又來看錯誤了。

02:09:56 - 02:09:59
好不容易講成構成，好不容易講完構成要件錯誤，

02:09:59 - 02:10:00
我們

02:10:00 - 02:10:02
就刑法來講，違法性這個層面的錯誤。

02:10:04 - 02:10:05
我還記得很多年前。

02:10:06 - 02:10:08
應該是2016還17年的時候吧，當時我在臺中，在康德給臺中辦教課。

02:10:12 - 02:10:13
也是在教這個進度。

02:10:14 - 02:10:15
在當時的下午。

02:10:16 - 02:10:17
整個下午都在講錯誤。

02:10:18 - 02:10:22
這個下午的上半堂，在講共展要件契約說。

02:10:22 - 02:10:24
下半堂在講違法性的錯誤。

02:10:25 - 02:10:29
那天讓我印象很深刻的一件事，是有一個要考關務的新生。

02:10:30 - 02:10:31
想來補習。

02:10:31 - 02:10:35
那補習班的人呢，竟然就讓他來試聽我這一段。

02:10:35 - 02:10:37
講錯這一段。

02:10:37 - 02:10:41
聽說啊，那個同學原本錢都帶好的準備要補習了。

02:10:41 - 02:10:45
結果來聽這一段的時候啊，因為他是新生，完全沒有學過法律。

02:10:45 - 02:10:50
來聽這一段的時候想說天啊，刑法怎麼那麼難，因為會讓人想說我覺得我聽不懂，我不要補了。

02:10:51 - 02:10:54
是真的啊，然後就是會談有種感覺，什麼煮熟的鴨子飛了啊。

02:10:55 - 02:10:57
我想說應該不是我的問題啊，因為這一段就這麼難啊。

02:10:57 - 02:10:58
所以。

02:10:59 - 02:11:00
這個沒有辦法。

02:11:00 - 02:11:00
怎麼辦？

02:11:01 - 02:11:05
這一段的內容，確實是在整個刑法當中。

02:11:05 - 02:11:06
偏難的一段。

02:11:06 - 02:11:08
你這一段撐過去都懂了，剩下的問題還好。

02:11:09 - 02:11:12
剩下我們大概就不會再教那麼艱深的東西了，應該還好啊。

02:11:13 - 02:11:15
所以學到現在各位你們有沒有發現？

02:11:17 - 02:11:18
我們學法律這個科目。

02:11:19 - 02:11:21
就是其實每部法律都一樣。

02:11:21 - 02:11:23
它跟你們國高中學的學科有兩大的不同。

02:11:24 - 02:11:26
就是你們國高中學的學科啊。

02:11:27 - 02:11:30
從第一單元到最後一個單元，它的難度是。

02:11:30 - 02:11:32
一成一成往上疊的。

02:11:32 - 02:11:33
尤其像英文數學那種東西，我發現。

02:11:34 - 02:11:35
數學就是啊。

02:11:35 - 02:11:37
從國小國中到高中，難度是慢慢往上疊的嘛。

02:11:38 - 02:11:40
你前面不會，後面也不會嘛。

02:11:41 - 02:11:43
對啊，就你不會加法，你怎麼可能會乘法？

02:11:44 - 02:11:45
數學英文是這樣子嘛。

02:11:45 - 02:11:46
但你有沒有發現，

02:11:46 - 02:11:48
人文社會的領域好像沒有這樣的問題。

02:11:49 - 02:11:50
就像你學歷史。

02:11:50 - 02:11:55
所以歷史是那個以前的歷史比較難、比較簡單，後面的歷史比較難嗎？沒有啊，對吧，法律也是啊。

02:11:57 - 02:12:00
法律你說前面簡單，後面難。

02:12:00 - 02:12:00
沒有啊。

02:12:00 - 02:12:01
法律沒有這樣的關係啊。

02:12:02 - 02:12:03
所以刑法也是喔。

02:12:03 - 02:12:06
同學不要想說好像才共學就這麼難的，

02:12:06 - 02:12:06
後面會不會更難？

02:12:07 - 02:12:07
不會。

02:12:07 - 02:12:08
我沒有這樣的觀念喔，

02:12:08 - 02:12:09
就跟我們講歷史一樣嘛。

02:12:10 - 02:12:11
歷史沒有說前面難,

02:12:11 - 02:12:12
前面簡單後面難，沒有啊。

02:12:12 - 02:12:14
法律這個東西也是一樣。

02:12:14 - 02:12:15
好,

02:12:15 - 02:12:16
我們這邊就來看個阻卻違法事由。

02:12:17 - 02:12:18
我來畫一個圖喔,

02:12:18 - 02:12:19
幫同學回復一下記憶。

02:12:51 - 02:12:51
好,

02:12:51 - 02:12:52
我們說了哈。

02:12:52 - 02:12:54
在主卻違法事由當中,

02:12:55 - 02:12:56
有客觀還有主觀要件。

02:12:57 - 02:12:59
客觀上要有這個事實，

02:12:59 - 02:12:59
手段要適當。

02:13:00 - 02:13:04
主觀上必須行為人對主觀違法事由的存在有所認知。

02:13:05 - 02:13:05
這樣的話呢，

02:13:06 - 02:13:07
才可以制裁違法。

02:13:08 - 02:13:11
我們這邊就用我剛剛講的案例為例。

02:13:12 - 02:13:14
晚上回家的路上,

02:13:14 - 02:13:18
有路人靠近想提醒我後揹包的拉鍊沒有拉,

02:13:19 - 02:13:21
而我卻以為這個路人要對我實行猥褻行為

02:13:21 - 02:13:22
所以我踹了他一腳,

02:13:22 - 02:13:24
造成他跌坐在地上,

02:13:24 - 02:13:26
屁股跟身體受到了擦傷。

02:13:26 - 02:13:27
好,

02:13:27 - 02:13:27
我們來看。

02:13:28 - 02:13:29
這樣的案例,

02:13:29 - 02:13:30
我該當什麼罪呢?

02:13:32 - 02:13:33
罪名的部分比較沒有疑問。

02:13:34 - 02:13:34
這樣的案例,

02:13:34 - 02:13:36
我該當的叫做傷害罪。

02:13:37 - 02:13:38
是刑法第一項的

02:13:38 - 02:13:39
故意傷害罪。

02:13:40 - 02:13:42
客觀構成要件有沒有符合？

02:13:43 - 02:13:43
當然有啊。

02:13:44 - 02:13:47
主體、行為、客體、結果、因果關係都具備。

02:13:47 - 02:13:47
對不對？

02:13:48 - 02:13:50
那主觀上我們有傷害故意？

02:13:50 - 02:13:51
有啊。

02:13:51 - 02:13:53
你不要跟我說我沒有傷害故意喔。

02:13:54 - 02:13:55
我再講一次，

02:13:55 - 02:13:58
刑法的故意跟日常生活我們講的故意不一樣喔。

02:14:00 - 02:14:02
你這樣串下去那個人會受傷。

02:14:02 - 02:14:03
有沒有人知道？

02:14:03 - 02:14:05
有啊，有沒有想要，有啊，一定容忍啊，對不對？

02:14:05 - 02:14:06
所以剛才有故意。

02:14:07 - 02:14:09
因為有些同學可能第一次學啊。

02:14:09 - 02:14:14
再次跟同學強調，刑法上的故意，就是指對對方的訊息的知還有意。

02:14:15 - 02:14:18
起初一點覺得，我這樣做可以吧，我這樣做正當吧。

02:14:18 - 02:14:21
那個不像故意的問題，那叫違法性的問題。

02:14:21 - 02:14:26
好，那麼請寫在違法性的層次，這裡你是涉及到正當防衛。

02:14:27 - 02:14:27
來。

02:14:27 - 02:14:28
這邊有沒有過？

02:14:30 - 02:14:32
這裡有沒有存在前提事實？

02:14:32 - 02:14:34
根本沒有，對不對？根本沒有。

02:14:34 - 02:14:39
可是我主觀上，卻有對應的認知。

02:14:40 - 02:14:41
所以可不可以主張違法？

02:14:41 - 02:14:43
不可以，不可以。

02:14:43 - 02:14:47
那不能主張違法的話，基於正當防衛的阻卻罪責。

02:14:48 - 02:14:50
這樣案例你覺得有什麼阻卻罪責的事由嗎？

02:14:51 - 02:14:54
如果照原本的理論，其實也沒有，對吧？

02:14:55 - 02:14:56
你總不會說我沒有責任吧？

02:14:57 - 02:15:00
不會吧，還是有什麼責任的，還是有什麼罪責是有的情形。

02:15:00 - 02:15:01
對不對？

02:15:01 - 02:15:02
沒有問題啊，對不對？

02:15:02 - 02:15:03
所以你會發現喔。

02:15:03 - 02:15:07
這種案例，如果你照現代版的三階段論，你不套用任何的學說的話。

02:15:08 - 02:15:10
最後得出來的結論就是：

02:15:10 - 02:15:12
過於印象太極端。

02:15:12 - 02:15:13
會得到這個結論。

02:15:14 - 02:15:15
可是學者不滿意。

02:15:16 - 02:15:17
因為學者會覺得。

02:15:18 - 02:15:21
這種情況之下的傷害，感覺那個行為人沒那麼壞耶。

02:15:23 - 02:15:24
怎麼樣？

02:15:24 - 02:15:24
這個行為人沒那麼壞啊。

02:15:25 - 02:15:27
因為這種情況之下的傷害。

02:15:27 - 02:15:30
行為人他覺得，他在做的是對的。

02:15:30 - 02:15:33
是人，他並沒有想跟法律抵對，對不對？

02:15:33 - 02:15:35
所以有學者就會認為說，

02:15:35 - 02:15:37
這種情況之下的傷害，

02:15:37 - 02:15:39
我們應該給他不同的處理。

02:15:40 - 02:15:41
畢竟行為人認為那麼壞嘛。

02:15:41 - 02:15:43
好，那怎麼給他不同的處理？

02:15:43 - 02:15:45
這就是下面學說探討的地方。

02:15:46 - 02:15:47
好。

02:15:47 - 02:15:49
我們這裡啊，一個一個來說。

02:15:50 - 02:15:52
最早以前有一個說法叫做故意理論。

02:15:55 - 02:15:58
故意理論這個東西你們自己看看不懂這個很正常。

02:15:59 - 02:16:00
因為這個東西。

02:16:00 - 02:16:02
並不是現代三階論的產物。

02:16:03 - 02:16:04
我這樣寫哦。

02:16:40 - 02:16:41
好，我們來看一下喔。

02:16:43 - 02:16:44
故意理論，

02:16:44 - 02:16:45
它的思考是這樣子。

02:16:47 - 02:16:50
故意理論是一個奠基於古典犯罪體系的理論。

02:16:51 - 02:16:53
古典犯罪體系。

02:16:53 - 02:16:55
就是100多年前的三階論。

02:16:55 - 02:16:57
跟現在的三階論長得不一樣。

02:16:57 - 02:16:59
我們左右對照一下。

02:16:59 - 02:17:41
現在的三階論，

02:17:41 - 02:17:43
構成要件分客觀、主觀。

02:17:44 - 02:17:46
違法性也分客觀、主觀。

02:17:47 - 02:17:48
故意過失在哪裡判斷？

02:17:48 - 02:17:49
在構成要件判斷。

02:17:50 - 02:17:50
OK吧？

02:17:50 - 02:17:51
這是現在的三階論。

02:17:51 - 02:17:52
但各位,

02:17:52 - 02:17:56
100多年前古典版的三段論不是長這個樣子。

02:17:57 - 02:18:00
100多年前古典版的三段論,

02:18:01 - 02:18:02
因為從現在的三段論來講,

02:18:03 - 02:18:05
殺手父母的生育行為,

02:18:05 - 02:18:08
跟殺手把被害人殺掉的這個行為之間,

02:18:08 - 02:18:09
各位有條件我沒有錯。

02:18:10 - 02:18:10
好,

02:18:10 - 02:18:12
就算你不講什麼規則什麼的,

02:18:13 - 02:18:14
可是主觀不該當啊。

02:18:14 - 02:18:16
殺手父母沒有殺人的故意過失啊,

02:18:16 - 02:18:16
對不對？

02:18:17 - 02:18:18
這現在的觀點,

02:18:18 - 02:18:19
所以我們會說，

02:18:19 - 02:18:20
從現在的觀點來講。

02:18:21 - 02:18:22
條件理論牽連過廣，

02:18:22 - 02:18:23
那不是問題，

02:18:23 - 02:18:25
因為刑法到德不法的層次，

02:18:25 - 02:18:26
本來就有其他篩選門檻，

02:18:27 - 02:18:28
比如說主觀下的故意。

02:18:28 - 02:18:28
對不對？

02:18:29 - 02:18:30
可是你們要看好喔，

02:18:31 - 02:18:32
100多年前的三階論，

02:18:33 - 02:18:34
當時故意在哪裡？

02:18:35 - 02:18:35
在罪責喔。

02:18:36 - 02:18:37
當時的故意過失在罪責喔。

02:18:38 - 02:18:38
所以你知道嗎？

02:18:39 - 02:18:40
在100多年前的三階段論,

02:18:42 - 02:18:44
當時只有條件理論的情況之下,

02:18:45 - 02:18:46
會變成怎麼樣？

02:18:47 - 02:18:49
殺手父母的生育行為，

02:18:50 - 02:18:52
該當了殺人罪的構成要件，

02:18:53 - 02:18:54
也不能阻卻違法。

02:18:55 - 02:18:56
然後到罪責，

02:18:56 - 02:18:57
再因為他沒有故意過失。

02:18:57 - 02:18:58
主卻罪責。

02:18:59 - 02:19:00
於是結論就變成什麼？

02:19:01 - 02:19:03
殺手父母那些年的生育行為，

02:19:04 - 02:19:05
在刑法上具有殺人的罪之不法，

02:19:06 - 02:19:07
只是沒有罪責而不成立犯罪。

02:19:08 - 02:19:09
這聽起來價值判斷上超怪,

02:19:09 - 02:19:10
對不對？

02:19:10 - 02:19:12
所以當時的人才會想盡辦法,

02:19:13 - 02:19:14
要在構成要件的層次,

02:19:15 - 02:19:16
把因果關係打掉。

02:19:17 - 02:19:18
免得說生小孩是不孝。

02:19:19 - 02:19:19
知道吧，

02:19:19 - 02:19:20
當時的背景是這樣喔。

02:19:21 - 02:19:23
所以為什麼以前的人會說條件理論牽連過廣，

02:19:24 - 02:19:25
是因為這個三階論。

02:19:25 - 02:19:25
知道嗎？

02:19:25 - 02:19:26
現在就沒這個問題啦。

02:19:27 - 02:19:28
所以我們回來。

02:19:29 - 02:19:31
當時的構成要件全客觀，

02:19:32 - 02:19:33
違法性也全客觀。

02:19:33 - 02:19:35
故意或過失在罪責判斷喔。

02:19:36 - 02:19:37
而且你們注意看,

02:19:38 - 02:19:42
當時的故意所要認知的對象跟現在也不一樣。

02:19:43 - 02:19:45
我們現在的故意只要認知到什麼?

02:19:46 - 02:19:48
構成犯罪事實。

02:19:48 - 02:19:49
對不對？

02:19:49 - 02:19:50
我們只要對事實有認知。

02:19:51 - 02:19:51
那是當時，

02:19:51 - 02:19:52
那是現在的故意。

02:19:52 - 02:19:53
那是現在的故意的。

02:19:53 - 02:19:55
可是當時的故意呢,

02:19:55 - 02:19:56
還要認知到一件事,

02:19:57 - 02:19:58
叫做不法意識。

02:19:59 - 02:20:00
所以當時的

02:20:00 - 02:20:06
人會覺得行為人除了要知道自己在做什麼之外,還要知道說我這個行為是犯法的。

02:20:06 - 02:20:08
這樣才具有故意。

02:20:09 - 02:20:11
接下來，各位就聽清楚這個論述。

02:20:12 - 02:20:14
當時在古典犯罪體系之下，

02:20:15 - 02:20:16
那個時候的學者覺得，

02:20:17 - 02:20:19
發生誤想的人，

02:20:20 - 02:20:22
我就有不法意識。

02:20:23 - 02:20:24
以我剛剛這個例子，

02:20:24 - 02:20:29
我的後揹包沒有拉，有人來提醒我，我以為那個人要對我猥褻，所以我反擊揍了他一拳，

02:20:29 - 02:20:31
踹了他一腳。

02:20:31 - 02:20:33
在整理當中你們看喔。

02:20:33 - 02:20:36
我確實具有傷害這個構成要件該當性,

02:20:36 - 02:20:38
客觀上行為結果因果都具備,

02:20:38 - 02:20:40
違法性也沒得阻卻也具備,

02:20:40 - 02:20:41
接著到了罪責呢,

02:20:42 - 02:20:43
你說我有沒有故意?

02:20:44 - 02:20:46
我對於構成犯罪事實的認識跟意欲,

02:20:46 - 02:20:46
有。

02:20:47 - 02:20:50
可是當時的人說啊，說我沒有不法意識。

02:20:50 - 02:20:51
為什麼？

02:20:51 - 02:20:54
我以為他要來打我。

02:20:55 - 02:20:57
進而我在這樣的認知之下反擊他

02:20:58 - 02:21:00
我是不是以為法律允許我做這件事情？

02:21:00 - 02:21:03
我以為我在做一件合法的事，對不對？

02:21:03 - 02:21:06
所以當時的人會覺得行為人沒有不法意識。

02:21:07 - 02:21:09
所以沒有不法意識的話呢，效果就是什麼？

02:21:10 - 02:21:11
主卻故意。

02:21:11 - 02:21:12
所以呢,

02:21:12 - 02:21:15
所以你看喔,135頁的中間,

02:21:15 - 02:21:18
古典犯罪體系之下的故意理論,

02:21:19 - 02:21:22
它是基於這個版本的三階論而來的。

02:21:23 - 02:21:26
所以如果你用我們現在三階論的版本去理解它，

02:21:27 - 02:21:28
你當然會覺得怪，

02:21:28 - 02:21:29
因為體系根本就不一樣，

02:21:29 - 02:21:31
知道嗎？是這樣來的。

02:21:31 - 02:21:34
我記得我大一的寒假，

02:21:35 - 02:21:39
因為要考轉學考嘛，所以自己在家看林山田老師的書看到這一段。

02:21:40 - 02:21:41
看不懂，覺得好痛苦。

02:21:42 - 02:21:45
就想說奇怪，這字都中文，為什麼都不懂那個在講什麼東西。

02:21:45 - 02:21:48
當時我還想說是不是我智商太低，不能理解。

02:21:48 - 02:21:52
後來學校老師教這一段的時候才理解，哦，原來這一段是這樣來的哦。

02:21:52 - 02:21:54
我才理解這個意思。

02:21:54 - 02:21:57
所以這一段以前同學，你們自己讀得懂不懂？

02:21:57 - 02:21:58
正常。

02:21:58 - 02:22:00
我大一自己讀我也讀不懂。

02:22:00 - 02:22:01
所以我跟各位說，

02:22:02 - 02:22:04
我記得我大一的時候老師講過一句話，

02:22:05 - 02:22:07
所以你看一本書如果你都看不懂的話，

02:22:08 - 02:22:09
不見得是你的問題，

02:22:10 - 02:22:11
有可能是作者的問題，

02:22:11 - 02:22:12
所以這是非常有可能的。

02:22:13 - 02:22:15
對啊，就是為什麼他會寫到讓你看不懂，

02:22:15 - 02:22:16
你不要覺得一定是你的問題。

02:22:17 - 02:22:17
好，

02:22:18 - 02:22:20
接下來135頁，我們來看到括號二。

02:22:21 - 02:22:25
那到了現在的犯罪體系之下呢，這個問題怎麼處理？

02:22:27 - 02:22:28
跟以前就不一樣了。

02:22:29 - 02:22:31
在現在的犯罪體系之下，

02:22:31 - 02:22:32
一樣，

02:22:32 - 02:22:34
救難的行為，跟我長線開刀，

02:22:35 - 02:22:36
也不能阻止違法。

02:22:37 - 02:22:39
接下來有一說，你來看看上面

02:22:40 - 02:22:41
嚴格罪責理論。

02:22:42 - 02:22:42
其實我跟你們說，

02:22:43 - 02:22:45
嚴格罪責理論的立場，

02:22:46 - 02:22:48
跟故意理論，

02:22:49 - 02:22:51
它基本的本質其實一樣。

02:22:52 - 02:22:56
這兩說都覺得容許構成要件錯誤，

02:22:57 - 02:22:59
是行為人的不法意識有欠缺。

02:23:01 - 02:23:02
他們的本質都一樣喔，

02:23:02 - 02:23:05
都認為容許構成要件錯誤是行為人的不法意識有欠缺。

02:23:06 - 02:23:11
只是你看喔，嚴格罪責理論它的說法是看能否避免，

02:23:11 - 02:23:13
能避免的話減輕，

02:23:13 - 02:23:15
不能避免的話無罪。

02:23:15 - 02:23:17
他不再提到故意的，為什麼？

02:23:18 - 02:23:20
因為在現在的三階論當中，

02:23:21 - 02:23:23
故意還要不要認識到不法意識？

02:23:23 - 02:23:24
不用喔。

02:23:25 - 02:23:30
現代的三階論當中，不法意識就只是一個純粹的罪責要素。

02:23:31 - 02:23:32
你看我們的刑法條最清楚。

02:23:33 - 02:23:34
刑法條怎麼說的？

02:23:35 - 02:23:41
除有正當理由而無可避免者外,不得因不知法律而免除刑事責任。

02:23:42 - 02:23:42
對啊,

02:23:42 - 02:23:48
所以在現代的三階論之下,欠缺不法意識,不再能阻卻故意了,

02:23:49 - 02:23:52
最多最多在不可避的情況,只能怎麼樣呢?

02:23:53 - 02:23:54
阻卻罪責。

02:23:55 - 02:23:55
所以我再講一遍,

02:23:56 - 02:24:00
嚴格罪責理論，其實它的想法是

02:24:00 - 02:24:00
什麼？

02:24:01 - 02:24:05
他一樣覺得容許構成要件錯誤是行為人不法意識的欠缺

02:24:05 - 02:24:06
但為什麼他不能再歸屬故意？

02:24:07 - 02:24:12
因為他搭配的三階論，不是右邊的模板，而是左邊這個現代的模板

02:24:12 - 02:24:16
現代版本的三階論之下，欠缺不法意識，當然不能舉故意

02:24:17 - 02:24:20
知道嗎，所以其實這兩個理論沒有那麼大的差異啦

02:24:20 - 02:24:24
是有兩個理論，都用不法意識的欠缺來解這個問題

02:24:25 - 02:24:28
只是因為他們搭配的三階論版本不一樣，所以結論才不一樣

02:24:28 - 02:24:29
簡單講是這個意思，知道嗎？

02:24:30 - 02:24:30
好

02:24:32 - 02:24:33
其實我想講

02:24:33 - 02:24:35
然後再過來版三階論

02:24:36 - 02:24:36
我想了

02:24:37 - 02:24:44
前面兩說的共同點,都是覺得容許構成要件錯誤,是不法意識的欠缺

02:24:45 - 02:24:49
可是這個共同點,也是他們共同的致命傷

02:24:50 - 02:24:57
因為後來的學者覺得,不對,容許構成要件錯誤,怎麼會是行為人不法意識的欠缺

02:24:58 - 02:24:59
我們看16條就知道

02:25:00 - 02:25:02
來,我們16條怎麼說的

02:25:03 - 02:25:06
除有正當理由而無可避免者外

02:25:07 - 02:25:09
不得因不知情而免除形式責任

02:25:10 - 02:25:11
不知法律,看到沒有

02:25:12 - 02:25:15
不得因不知法律而免除形式責任

02:25:17 - 02:25:20
同學,不想犯罪的人,他有不學法律嗎?

02:25:21 - 02:25:22
當然沒有啊

02:25:22 - 02:25:23
他是不知什麼？

02:25:23 - 02:25:24
事實，對吧？

02:25:24 - 02:25:26
他是不知事實，但他沒有不知法律啊。

02:25:27 - 02:25:30
那為什麼以前的人卻會覺得這個是非法意識的欠缺？

02:25:31 - 02:25:32
那個是誤認

02:25:33 - 02:25:36
我們講，嚴格來講，什麼叫不法意識的欠缺？

02:25:37 - 02:25:47
其實嚴格來講，不法意識的欠缺指的是，行為人因為對法規範有所誤解，所以才覺得這件事

02:25:47 - 02:25:47
法律允許

02:25:48 - 02:25:49
知道嗎？這個叫不法意識的欠缺

02:25:49 - 02:25:57
行為人對法規範有所誤解，而覺得這件事法律允許他這麼做。

02:25:58 - 02:26:00
比如說外國人，以為在泰國

02:26:00 - 02:26:01
違反吸毒的刑法。

02:26:02 - 02:26:05
那外國人想說奇怪，我吸毒又沒有傷害誰，為什麼你們臺灣的法律會禁止？

02:26:06 - 02:26:06
他完全沒有想過啊。

02:26:07 - 02:26:08
他覺得，我吸毒是我自己選的啊，

02:26:09 - 02:26:12
那就，那就跟拿刀割我自己不犯法一樣啊。

02:26:12 - 02:26:15
外國人基於這樣的想法，在臺灣吸毒，

02:26:15 - 02:26:16
但是怎麼樣？

02:26:16 - 02:26:17
對法規範的誤解。

02:26:18 - 02:26:20
然後覺得自己的行為是正當的。

02:26:21 - 02:26:23
這才是不法意識的欠缺喔，知道嗎？

02:26:24 - 02:26:25
所以是怎麼樣？再講一次。

02:26:25 - 02:26:28
行為人因為對法規範有所誤解，

02:26:29 - 02:26:31
然後覺得他的行為是正當的。

02:26:32 - 02:26:33
可是各位啊，

02:26:34 - 02:26:36
容許構成要件錯誤，

02:26:36 - 02:26:40
雖然行為人也覺得他的行為在法律上正當沒有錯，

02:26:40 - 02:26:42
可是他是因為對什麼的誤解才覺得正當？

02:26:43 - 02:26:44
對事實的誤解。

02:26:45 - 02:26:47
那個結果根本就不符合第16條。

02:26:48 - 02:26:50
我這樣不是更清楚嗎？第16條是要怎麼樣？

02:26:50 - 02:26:53
不得以不知法律而免除其責任啊。

02:26:53 - 02:26:54
對不對吧？

02:26:54 - 02:26:56
所以後來的學者就說了，

02:26:56 - 02:26:59
容許構成要件錯誤的不是不法意識的欠缺啦。

02:26:59 - 02:27:01
因為行為人沒有誤解法規範啊,

02:27:02 - 02:27:03
行為人是誤解事實啊,

02:27:03 - 02:27:06
所以來，那個132頁的第二點,

02:27:06 - 02:27:09
這個第三說，叫做限制罪責理論。

02:27:10 - 02:27:15
限制罪責理論，這個是來自德國一個還，在德國還蠻流行的一個說法。

02:27:16 - 02:27:18
限制罪責理論會覺得，

02:27:19 - 02:27:22
發生容許構成要件錯誤的行為人呢，

02:27:23 - 02:27:24
這樣的行為人，

02:27:26 - 02:27:28
他對事實有誤認。

02:27:29 - 02:27:29
那我們想喔,

02:27:30 - 02:27:34
一般的構成要件錯誤，也就是事實的誤認嘛。

02:27:34 - 02:27:37
那我獵山豬結果打到另外一個獵人的那一種，對不對？

02:27:37 - 02:27:38
行為人對事實的誤認。

02:27:38 - 02:27:39
那我們講嘛,

02:27:40 - 02:27:41
一般的構成要件錯誤，

02:27:42 - 02:27:44
行為人對事實誤認，效果是什麼？

02:27:45 - 02:27:49
阻卻故意，視其情況改論過失犯，對吧？

02:27:50 - 02:27:53
那容許構成要件錯誤，是不是也是對事實的誤認？

02:27:53 - 02:27:54
是啊。

02:27:54 - 02:27:55
一樣啊，

02:27:55 - 02:27:56
他也是對事實的誤認啊。

02:27:57 - 02:27:59
可是容許構成要件錯誤，

02:28:00 - 02:28:02
每代反正就去顧慮。

02:28:02 - 02:28:03
那所以反學長講很像怎麼辦？

02:28:05 - 02:28:07
A有B的法律效果。

02:28:08 - 02:28:10
AA卻沒有B的法律效果。

02:28:10 - 02:28:12
而AA跟A很像，怎麼樣？

02:28:12 - 02:28:14
就內推適用一下嘛，對不對？

02:28:14 - 02:28:16
所以限制罪責論的主張就是

02:28:17 - 02:28:22
因為容許構成要件錯誤跟構成要件錯誤很像，都是敘述面的誤認。

02:28:23 - 02:28:26
構成要件錯誤，可以阻卻故意。

02:28:26 - 02:28:29
那容許構成要件錯誤跟構成要件錯誤很像。

02:28:30 - 02:28:35
那應該也要讓他類推適用構成要件錯誤，讓他可以阻卻故意。

02:28:36 - 02:28:38
瞭解吧，這個是限制罪責論的說法。

02:28:39 - 02:28:46
也就是呢,讓容許構成要件錯誤,內推適用,內推適用構成要件錯誤,讓他阻卻故意。

02:28:47 - 02:28:52
限制罪責論,這個在德國很流行,但在國內很少人提。

02:28:52 - 02:28:53
為什麼?

02:28:54 - 02:28:56
因為他和跟我國學說不符。

02:28:56 - 02:28:57
簡單講是這樣。

02:28:58 - 02:28:59
他跟我學不合，怎麼說呢？

02:29:01 - 02:29:02
我們回想一下。

02:29:02 - 02:29:06
上一次上課，我們在講構成要件錯誤阻卻故意的時候。

02:29:07 - 02:29:10
我要列式是不是把大家給弄暈啊，構成要件錯誤阻卻故意的時候。

02:29:11 - 02:29:16
當時我們在講構成要件錯誤阻卻故意，我們有引用一個法條說構成要件錯誤會阻卻故意嗎？

02:29:17 - 02:29:19
沒有法律上的操作，對吧？

02:29:20 - 02:29:20
然後你再想。

02:29:21 - 02:29:22
所謂的內推適用。

02:29:23 - 02:29:25
內推適用的對象是什麼？

02:29:26 - 02:29:27
什麼條啊，對不對？

02:29:27 - 02:29:27
法條啊。

02:29:28 - 02:29:29
所以就卡在這邊了。

02:29:30 - 02:29:32
內推適用的對象是哪條？

02:29:33 - 02:29:37
可是我們說構成要件錯誤阻卻故意的時候。

02:29:37 - 02:29:38
我們有引用哪一個法條嗎？

02:29:39 - 02:29:39
沒有，那這一說所講的內推適用，內推適用什麼東西啊？

02:29:43 - 02:29:43
於是我跟各位說了。

02:29:44 - 02:29:46
限制罪責理論的內推適用。

02:29:47 - 02:29:49
它的內推適用對象是

02:29:49 - 02:29:52
德國刑法第16條第一項。

02:29:53 - 02:29:56
你們不知道條文的話,你們就用AI去查。

02:29:56 - 02:29:59
德國刑法第16條第一項,真正的意思在哪裡?

02:30:00 - 02:30:03
大概就是說構成要件故意可以做確認

02:30:03 - 02:30:04
德國有那種規定

02:30:05 - 02:30:06
可是很遺憾我沒用

02:30:07 - 02:30:10
所以我等這兄叫做跟我國水土不服的一兄

02:30:10 - 02:30:14
因為他的核心德國刑法條項的一需要

02:30:14 - 02:30:16
大家想我們一起考慮這樣規定

02:30:16 - 02:30:19
好嗎所以這說話恐怕跟我國水土不服的

02:30:20 - 02:30:25
我們通常是這樣說這個叫做限制法律效果的罪責理論

02:30:25 - 02:30:28
好，這一說提出一個概念，我寫一下

02:30:51 - 02:30:53
這個限制法律效果的罪論

02:30:54 - 02:30:57
他提出一個叫做罪責故意的概念

02:30:57 - 02:31:00
罪責故意看什麼呢？叫做良知

02:31:00 - 02:31:02
分際，有些人要問的，什麼叫良知分際？

02:31:03 - 02:31:07
白話的意思就是這個人的良知值不值得被譴責

02:31:07 - 02:31:10
那你說什麼叫良知值不值得被譴責呢

02:31:10 - 02:31:15
他看的其實就是行為人有沒有想跟法律敵對的意思

02:31:16 - 02:31:17
就在看這個東西,好嗎

02:31:18 - 02:31:21
好,所以我講了限制法律效果的罪責理論

02:31:22 - 02:31:24
他提出的所謂罪責故意的概念

02:31:25 - 02:31:27
罪責故意看的是良知評價

02:31:27 - 02:31:30
良知評價看的就是行為人的良知值不值得

02:31:30 - 02:31:30
被譴責

02:31:31 - 02:31:34
也就是看這個行為人有沒有想跟法律作對的意思

02:31:35 - 02:31:36
所以說的主張是這樣

02:31:36 - 02:31:37
你們看喔

02:31:39 - 02:31:41
通常有構成要件故意的人

02:31:42 - 02:31:43
會不會有罪責故意

02:31:43 - 02:31:44
這句話當然很瞎

02:31:45 - 02:31:47
我無故揍你一拳

02:31:47 - 02:31:48
我有構成要件故意

02:31:49 - 02:31:50
我的良知值不值得被譴責

02:31:50 - 02:31:51
當然值得，對吧

02:31:52 - 02:31:53
我有跟法律的意思，對吧

02:31:53 - 02:31:54
殺人也是嘛,我無故殺人

02:31:55 - 02:31:57
我確實有構成要件故意,我當然也會有罪責故意

02:32:00 - 02:32:02
那什麼樣的人會沒有罪責故意?

02:32:03 - 02:32:06
就是容許構成要件錯誤的行為人。

02:32:06 - 02:32:07
你們想不想反問?

02:32:08 - 02:32:13
我以為這個人要對我性騷擾，所以我反擊毆打他。

02:32:14 - 02:32:18
構成要件的成立，我確實有基於意思，有故意，OK，這個沒有疑問。

02:32:19 - 02:32:20
可是我罪責故意嗎？

02:32:21 - 02:32:22
我的良知值得被譴責嗎？

02:32:23 - 02:32:25
這一說的學者就說不值得，為什麼？

02:32:26 - 02:32:28
依照這一說法的學者來看,

02:32:28 - 02:32:30
我以為他要傷害我,

02:32:31 - 02:32:33
所以我才反擊他。

02:32:33 - 02:32:35
我也沒有想跟法律頂撞。

02:32:35 - 02:32:36
沒有。

02:32:36 - 02:32:41
在我的認知裡面，我覺得我是在防衛，我是站在法律這一邊的。

02:32:41 - 02:32:45
瞭解吧，所以這個叫做欠缺良知非難，所以是故意。

02:32:46 - 02:32:47
這個部分的論述，我們放在

02:32:50 - 02:32:51
大家可以看一下。

02:32:54 - 02:32:55
220頁。

02:32:56 - 02:32:59
這個部分的論述,我們放在220頁。

02:32:59 - 02:32:59
220頁。

02:33:00 - 02:33:00
就這裡。

02:33:03 - 02:33:06
所以講,我們可以說,罪責故意這個概念,

02:33:07 - 02:33:13
它是一個為容許構成要件錯誤所量身打造的說法。

02:33:14 - 02:33:19
有些人會問，那所以還有什麼情況會阻卻罪責故意，會讓行為人欠缺良知非難嗎？

02:33:19 - 02:33:20
我跟你講沒有。

02:33:21 - 02:33:25
它就是一個為容許構成要件錯誤所量身打造的概念。

02:33:26 - 02:33:28
所以以前我大學的老師嘲諷這一說，

02:33:29 - 02:33:31
說這個學說像是聖經在後面撐腰吧。

02:33:32 - 02:33:33
想想好像也沒錯對不對？

02:33:33 - 02:33:37
為了要解決這個問題，所以發明瞭罪責故意這個東西。

02:33:37 - 02:33:39
那其實確實有這個想法在，

02:33:39 - 02:33:39
確實這個想法在。

02:33:40 - 02:33:44
好，所以這個是目前的主流說法，叫做限縮法律效果的罪責理論。

02:33:45 - 02:33:49
好，最後下課前，我們要來講一個東西叫做二階倫。

02:33:50 - 02:33:52
二階倫這個東西，

02:33:52 - 02:33:54
我就講同學就姑且聽聽看。

02:33:55 - 02:33:58
如果你覺得很抽象聽不懂沒關係，你就記得結論。

02:34:50 - 02:34:53
好，我們來看一下，二階倫對這個問題怎麼看。

02:34:54 - 02:34:59
這個二結論啊，它並不是跟三結論完全獨立無關的理論，不是。

02:34:59 - 02:35:01
簡單講二結論什麼意思？

02:35:01 - 02:35:06
二結論就是跟你說，構成要件該當性跟違法性，不要分了，反正它們都會一樣。

02:35:08 - 02:35:11
構成要件該當性是不法的正面描述。

02:35:12 - 02:35:15
而違法性，就是不法的負面描述。

02:35:16 - 02:35:20
這兩個層，其實都是在處理不法的問題。

02:35:20 - 02:35:23
只是構成要件該當性的判斷是用正面表列的方式判斷。

02:35:24 - 02:35:27
違法性的判斷是用負面表列的方式判斷。

02:35:27 - 02:35:28
它們根本就是一樣的東西。

02:35:28 - 02:35:32
所以我們不要分了，都把它們當作同一階，這個叫二分法。

02:35:33 - 02:35:35
二結論之下，你看喔。

02:35:35 - 02:35:39
他把構成要件跟違法合在同一階段。

02:35:39 - 02:35:41
你有沒有發現啊，他那個主觀故意變大了。

02:35:42 - 02:35:44
對，沒有錯，故意變大了。

02:35:44 - 02:35:47
所以在二結論之下，行為人的故意要認識到什麼呢？

02:35:49 - 02:35:50
兩件事。

02:35:50 - 02:35:54
第一個是要認識到正面的不法事實。

02:35:54 - 02:35:55
也就是要知道，

02:35:56 - 02:35:58
他在做一個打人的行為。

02:35:58 - 02:36:00
打下去會受傷，但理念。

02:36:00 - 02:36:01
的故意一樣，對不對？

02:36:02 - 02:36:12
除了要認識到正面的不法訊息之外，二階理論底下，行為人還要認識到第二件事情，叫做無阻卻違法訊息。

02:36:12 - 02:36:20
也就是行為人要認識到他正在做事的正當性，他沒有正當防衛、沒有緊急避難、沒有依法行為等等。

02:36:21 - 02:36:24
兩個都有認識，才算是具有故意喔。

02:36:25 - 02:36:25
好。

02:36:26 - 02:36:29
所以同樣的，誤想防衛的案例。

02:36:29 - 02:36:37
我剛所說的，我以為這個人要攻擊我，所以我反擊對方，結果後來發現，對方只是想提醒我揹包亂了。

02:36:38 - 02:36:41
這樣的案例，可能觸犯傷害罪的部分，所以我們這邊來看一下。

02:36:43 - 02:36:45
以傷害罪的看法來說。

02:36:45 - 02:36:46
來來。

02:36:48 - 02:36:50
我們這邊一樣分客觀跟主觀。

02:36:56 - 02:36:56
好。

02:36:57 - 02:36:59
客觀不法的部分。

02:36:59 - 02:37:02
這邊有沒有負面不法訊息存在？

02:37:02 - 02:37:04
傷害的行為、結果、因果關係有沒有？

02:37:04 - 02:37:05
有，對不對？

02:37:05 - 02:37:07
所以正面不法訊息是存在的。

02:37:08 - 02:37:10
再來，這裡有沒有負面不法？

02:37:11 - 02:37:11
有，為什麼？

02:37:12 - 02:37:15
因為這裡確實不存在正當防衛的情境嘛。

02:37:16 - 02:37:17
所以負面不法是不是具備？有，也具備。

02:37:17 - 02:37:18
所以這邊打勾。

02:37:20 - 02:37:21
接下來，主觀上。

02:37:22 - 02:37:26
我有沒有認識到負面不法訊息的存在？

02:37:27 - 02:37:29
也就是行為結果因果規則的部分，有沒有認識到？

02:37:30 - 02:37:30
有，對不對？

02:37:31 - 02:37:33
所以主觀上呢，我確實對這個部分有認識。

02:37:34 - 02:37:37
那我主觀上有沒有認識到無阻卻違法事由？

02:37:38 - 02:37:40
沒有，因為我以為我在防衛，對不對？

02:37:40 - 02:37:42
所以主觀上，這邊打叉。

02:37:42 - 02:37:45
我對無阻卻違法訊息沒有認識。

02:37:46 - 02:37:47
所以變什麼？

02:37:47 - 02:37:50
客觀都打勾，可惜主觀卻打叉。

02:37:51 - 02:37:54
為什麼？主故意，過失。

02:37:54 - 02:37:55
對吧？

02:37:55 - 02:37:58
所以為什麼很多，為什麼有些學覺得二級論很棒？

02:37:59 - 02:38:00
因為你。

02:38:00 - 02:38:00
三區論在處理誤想防衛這種案例的時候

02:38:05 - 02:38:07
理論取的那些好像講得有點硬

02:38:07 - 02:38:09
那什麼理論推又構成影響，或者發明一個罪責的章主去

02:38:11 - 02:38:12
那講得有點硬嘛

02:38:13 - 02:38:14
二期論沒這個困擾啊

02:38:14 - 02:38:16
二期論就可以很自豪的說

02:38:16 - 02:38:19
你用我這個理論，根本不用套任何學說

02:38:19 - 02:38:22
用這個理論，本來就會得出正確的結論

02:38:23 - 02:38:24
對不對

02:38:24 - 02:38:26
所以為什麼黃老師是二結論,是這樣講

02:38:27 - 02:38:29
黃老師的理論,很有趣

02:38:30 - 02:38:32
黃老師不喜歡一直開例外

02:38:32 - 02:38:34
他希望一個理論要用就是從頭用到尾

02:38:35 - 02:38:38
不要在這邊因為什麼個案的考量，這邊例外，那邊又變一個例外

02:38:38 - 02:38:40
那個理論就無法貫徹啦

02:38:40 - 02:38:47
所以二期論就是好用在這邊，遇到容許構成的時候，它本來就會得到正確的結論，這個是二期論它的特色

02:38:49 - 02:38:52
我說啦，二期論的這套論述

02:38:52 - 02:38:53
聽得懂可以，你看不懂

02:38:54 - 02:38:55
聽不懂沒關係啦

02:38:55 - 02:38:57
歷史上的爭議啦

02:38:57 - 02:38:58
這個理論是這樣

02:38:58 - 02:38:59
我跟各位講

02:39:00 - 02:39:02
容許構成不是有五說嗎

02:39:02 - 02:39:02
你看嘛

02:39:04 - 02:39:06
古典犯罪體系下的理論

02:39:07 - 02:39:10
然後呢,現代犯罪的體系下的三說

02:39:11 - 02:39:12
嚴格罪責論

02:39:12 - 02:39:13
選取罪責論

02:39:13 - 02:39:16
限制法律效果的罪責論

02:39:16 - 02:39:20
還有二期論之下的負面構成要件理論

02:39:21 - 02:39:22
各位嘛

02:39:22 - 02:39:22
各位

02:39:23 - 02:39:24
這我說話

02:39:24 - 02:39:27
如果你都能記得他們的名字

02:39:27 - 02:39:30
而且也都能在考卷上用文字表述

02:39:30 - 02:39:31
這我說的話

02:39:31 - 02:39:31
那你很棒

02:39:32 - 02:39:33
可是以我的經驗

02:39:33 - 02:39:38
要用文字表述這五說，尤其是二期論那個說法，那個文字很難描述

02:39:39 - 02:39:43
所以如果你沒辦法記得它的實際內容的話

02:39:44 - 02:39:45
那我教同學

02:39:45 - 02:39:47
至少記得它們的名字

02:39:47 - 02:39:47
知道嗎

02:39:47 - 02:39:49
至少記得他們的名字

02:39:49 - 02:39:51
還有記得他們的結論

02:39:52 - 02:39:52
你看

02:39:52 - 02:39:55
各說當中哪一說最特別

02:39:57 - 02:40:00
其實每一說你們發現，大部分的學說最後的結論

02:40:01 - 02:40:01
阻卻故意,

02:40:01 - 02:40:03
視情況變更過失,對吧?

02:40:04 - 02:40:06
幾乎各說都是阻卻故意,視情況變更過失,

02:40:06 - 02:40:07
只有哪一說不是?

02:40:08 - 02:40:09
嚴格罪責論,

02:40:09 - 02:40:10
有沒有發現？

02:40:10 - 02:40:14
只有嚴格罪責論他主張用16條處理。

02:40:14 - 02:40:15
對，沒有錯。

02:40:15 - 02:40:18
所以如果你覺得各說很難記的話，

02:40:18 - 02:40:19
你至少記得。

02:40:20 - 02:40:26
大部分的學說，他們的操作都是阻卻故意，視情況改論過失犯。

02:40:27 - 02:40:28
只有哪一說不是？

02:40:28 - 02:40:30
只有嚴格罪責論不是，

02:40:31 - 02:40:33
他主張用16條去處理，

02:40:33 - 02:40:33
知道吧？

02:40:34 - 02:40:36
所以我說，各說你能記得名稱跟結論，

02:40:36 - 02:40:38
名稱跟內容當然最棒，

02:40:38 - 02:40:40
但如果你覺得這個記不起來，沒關係，

02:40:40 - 02:40:42
你至少記得各說的名稱，

02:40:43 - 02:40:45
跟各說的結論。

02:40:46 - 02:40:50
之前啊，有一位已經考上律師的同學，

02:40:50 - 02:40:53
他曾經做了一個很有趣的圖，

02:40:53 - 02:40:55
這個圖的話呢，

02:40:55 - 02:40:58
我看一下，這邊還有沒有存，印象中應該還在。

02:41:07 - 02:41:11
奇怪，我可能存太多哏圖，找不到那個圖在哪裡。

02:41:11 - 02:41:13
沒關係，等一下找到我再給各位看。

02:41:14 - 02:41:16
之前有一位考上律師的同學，

02:41:16 - 02:41:18
他為了要記得這五說的名稱，

02:41:18 - 02:41:21
他把這五說做成一個長輩圖，

02:41:21 - 02:41:23
背景有蓮花。

02:41:23 - 02:41:25
有很高彩度的配色,

02:41:26 - 02:41:28
然後寫了容許構成要件錯誤的謬說,

02:41:28 - 02:41:30
下面還寫認同請分享。

02:41:31 - 02:41:35
他準備考試那段時間就把這個圖做成他手機的解鎖畫面。

02:41:35 - 02:41:37
各位，他忘記的話就這麼做。

02:41:37 - 02:41:37
你就不會忘記了。

02:41:38 - 02:41:40
只要一打開手機的畫面，就是這五說,

02:41:40 - 02:41:42
還有個長輩圖，

02:41:42 - 02:41:43
印象超深刻對不對？

02:41:43 - 02:41:44
他忘記的話可以這麼做。

02:41:45 - 02:41:47
好，所以這五說呢，就跟同學講到這邊。

02:41:47 - 02:41:48
過當的阻力，一般會說啦，

02:41:49 - 02:41:51
誤想防衛如果過當的話，

02:41:51 - 02:41:55
就還是可以類推適用，還是可以去適用這個防衛過當或避難過當的規定，一般的說法是這樣子。

02:41:56 - 02:41:59
好，所以容許構成要件錯誤呢，我們就先跟各位講到這邊。

02:41:59 - 02:42:00
題目我們等一下。

02:42:00 - 02:42:00
來看，

02:42:01 - 02:42:02
那我們下午的話呢，

02:42:02 - 02:42:03
就一樣兩點上課，

02:42:04 - 02:42:04
我們再繼續看。

02:42:05 - 02:42:07
反面容許構成要件錯誤

02:42:07 - 02:42:09
同時可能心中會在那想說

02:42:09 - 02:42:10
還有反面的

02:42:11 - 02:42:11
沒有啦

02:42:11 - 02:42:12
正面的你會

02:42:13 - 02:42:14
反面的就一樣的結論,

02:42:14 - 02:42:15
顛倒過來而已,

02:42:15 - 02:42:16
沒有很難,

02:42:16 - 02:42:16
好嗎?

02:42:16 - 02:42:17
所以剩最後這個東西喔。